

관련 도산절차·재판	선후관계	항고법원의 처리
개인회생절차에서 금지명령	금지명령 효력발생 후 가압류·가처분결정	항고(이의)인용, 금지명령의 효과에 반하는 가압류·가처분 취소
	금지명령 효력발생 전 가압류·가처분결정	항고(이의)기각, 가압류·가처분결정 유효
회생절차·개인회생 절차개시결정, 파산선고결정 (동시폐지 제외)	개시결정 등 이후 가압류·가처분결정	항고(이의)인용, 개시결정 등의 효과에 반하는 가압류·가처분 취소
	개시결정 전 가압류·가처분결정	항고(이의)에 대한 재판정지, 이후 회생인가결정·변제계획인가결정 있으면 가압류·가처분 취소
	파산선고결정 전 가압류·가처분결정	항고(이의)인용, 파산선고결정의 효과에 반하는 가압류·가처분 취소
개인파산절차에서 면책신청	면책신청이 있고 파산선고 및 동시폐지결정의 확정 전 가압류·가처분결정	항고(이의)에 관한 재판 정지, 면책결정 확정되면 가압류·가처분 취소
	면책신청 및 파산폐지결정의 확정 또는 파산종결결정 이후 가압류·가처분결정	항고(이의)인용, 면책재판절차의 계속 효과에 반한 가압류·가처분결정 취소(이후 면책불허가결정이 확정되더라도 마찬가지)
	면책결정 확정 이후 가압류·가처분결정	항고(이의)인용, 가압류·가처분 취소(면책결정의 확정은 집행장애 사유는 아니나, 채권이 자연채무화 되어 보전의 필요성이 없어졌거나, 사정변경이 생겼음을 이유로)

제7장 보전집행

제1절 보전집행의 일반원칙

1. 강제집행 규정의 준용

가압류의 집행에 관하여는 민사집행법 292조 이하 몇 조문의 특칙이 있는 것을 제외하고는 강제집행에 관한 규정을 준용한다(민집 291조, 민집규 218조). 가처분의 집행에 관하여도 같다(민집 301조). 그러므로 보전처분의 성질에 반하지 않고 특칙에서 따로 규정되어 있지 않는 한 보전처분의 집행에 관하여는 강제집행에 관한 규정이 모두 준용된다고 보아도 좋다. 따라서 집행의 목적물, 집행기관, 집행의 방법, 위법집행에 대한 채무자 및 제3자의 구제절차 등은 강제집행에 관하여 설명한 바를 참고하면 된다.

그러나 집행권원의 집행력을 배제하기 위한 제도인 청구에 관한 이의의 소(민집 44조)의 규정은 준용되지 않고, 집행문부여에 대한 이의의 소(민집 45조)의 규정도 원칙적으로 준용되지 않는다(승계집행문이 있는 경우는 예외). 또한 임시의 지위를 정하기 위한 가처분 중 근로자지위보전가처분과 같은 가처분은 관념적인 법률상태의 조성만을 목적으로 하고 그 이상으로 집행기관의 집행처분은 필요하지 않으므로 강제집행에 관한 규정이 준용될 여지가 없다.

2. 보전집행의 특색

일반적으로 보전집행의 특색은 다음 네 가지로 설명된다.

- 238 ① 보전처분의 집행력은 그 명령 성립과 동시에 발생하고 그 명령의 확정을 기다릴 필요가 없다. 따라서 가집행선고를 불일 여지가 없으며, 보전처분 발령법원이 동시에 집행기관

인 경우에는 실무상 집행신청을 기다리지 않고 집행에 착수한다.

② 일반적으로는 집행문의 부여가 필요 없고 당사자의 승계가 있을 경우에 한하여 승계 집행문이 필요할 뿐이다(민집 292조 1항, 301조).

③ 집행권원을 채무자에게 송달하기 전에 집행할 수 있다(민집 292조 3항, 301조).

④ 보전처분의 집행력은 채권자에게 재판의 고지 후 2주일 내에 집행에 착수하지 않으면 상실된다(민집 292조 2항, 301조).

3. 집행기관

집행기관은 강제집행의 경우와 같다. 따라서 유체동산의 가압류, 동산 또는 부동산인도의 가처분, 채무자의 점유해제·집행관 보관의 가처분 등은 집행관이 이를 집행한다. 부동산, 선박·항공기(자동차 등 특정동산 저당법 3조 4호에 따른 항공기 및 경량항공기를 말한다)·자동차·건설기계·소형선박(자동차 등 특정동산 저당법 3조 2호에 따른 소형선박을 말한다), 채권과 그 밖의 재산권에 대한 가압류와 처분금지가처분 등은 집행법원이 집행기관이 된다. 다만 이 경우 강제집행과 다른 것은 선박·항공기의 경우 선박국적증서 등을 제출하는 방법에 의하여 집행하는 경우(민집 295조 2항)를 제외하고는 발령법원이 곧 집행법원이 된다는 점이다(민집 293조 2항, 296조 2항, 301조).

제3편
제7장
제1절

4. 집행신청의 요부

가. 원칙

원칙적으로 강제집행에서는 집행권원이 성립되었다고 하더라도 집행채권자의 집행신청 239 이 있기까지는 집행절차가 개시되지 않기 때문에(민집 4조, 39조), 위 규정이 준용되는 보전집행에서도 집행신청이 필요하다(민집규 203조 1항 6호). 따라서 보전집행기관이 집행관인 유체동산가압류 등의 경우에는 채권자가 보전처분 정보를 집행관에게 제시하고 집행위임을 하여야만 집행이 개시된다.

나. 실무상 태도

실무상으로는 보전처분은 판결절차와 달리 집행권원만 받아놓고 집행은 일단 보류하는 것을 예상할 수 없으므로, 신속한 집행을 위하여 발령법원이 동시에 집행법원이 되는 부동

산가압류, 채권가압류 등에서는 보전신청 시에 그 인용재판에 대한 보전집행신청도 함께 한 것으로 해석하여 별도의 보전집행신청이 없어도 보전처분발령과 함께 집행에 착수한다. 부동산에 관한 가압류, 가처분결정에 의한 등기를 촉탁하는 경우에는 원칙적으로 전자촉탁에 의하고 예외적으로 서면촉탁(부동산목록에 미등기 부동산이 포함되어 있을 때에 미등기 부동산에 한하여, 전자촉탁할 사건의 부동산 수가 500건을 초과하는 경우, 전산장애로 인하여 전자촉탁이 불가능한 경우)에 의하는데(재민 2013-1 3조) 채무자의 소유권변동이 임박하였음을 이유로 등기촉탁서를 채권자가 직접 관할등기소에 접수시키겠다고 신청하는 예가 있으나, 촉탁에 의한 등기인 점에 비추어 볼 때 채권자에게 촉탁서류를 교부하는 것은 허용되지 않는다.

다. 민사집행규칙의 개정

민사집행규칙은 위와 같은 실무상 태도를 반영하여 민사집행규칙 203조 1항 6호에서 원칙적으로 보전처분의 집행신청은 서면으로 하도록 하되, 2014. 7. 1. 개정 시에 단서를 신설하여 등기나 등록의 방법 또는 제3채무자나 이에 준하는 사람에게 송달하는 방법으로 집행하는 경우에는 보전집행신청서를 제출할 필요가 없도록 명문의 규정을 두었다.

240 5. 채무자에 대한 송달과 집행착수의 관계

보전처분의 집행은 채무자에게 재판을 송달하기 전에도 할 수 있는바(민집 292조 3항, 301조), 실무상은 가압류와 다툼의 대상에 관한 가처분은 집행착수 전에 채무자에게 재판서 정보를 송달하지 않는 것을 원칙으로 하고 있다. 채무자에게 강제집행을 면탈할 기회를 주지 않기 위함이다. 대다수 법원의 실무례는 다음과 같은 기준에 의하여 채무자에게 재판서 정보를 송달한다.

가. 집행법원이 집행기관인 경우

제3채무자에 대한 송달결과 정보, 부동산에 대한 등기완료통지 정보 등에 의하여 집행되었음을 확인한 후에 채무자에게 송달한다.

나. 집행관이 집행기관인 경우

(1) 발령법원 소속 집행관인 경우

채권자가 집행관에게 집행을 위임하면 그 집행관은 법원사무관등에게 자기가 위임받았음을 통지하고 법원사무관등은 그 집행관으로 하여금 채무자에 대한 재판서 정보를 송달하도록 한다(민소 176조 1항의 집행관송달방식에 의함).

이와 같이 집행관은 그 보전처분의 집행착수와 동시에 채무자에게 재판서 정보를 송달하게 된다. 만약 집행장소에서 집행관이 채무자를 만나지 못하였을 때에도 집행절차는 진행되므로 집행관이 송달현장상황탐지 등 결과통지서[전산양식 A1441]를 첨부한 송달사유 통지서[전산양식 A1440]를 작성하여 법원에 제출하면 법원은 우편에 의한 송달 등의 방법에 의하여 송달하게 된다.

(2) 집행관이 발령법원 소속이 아닌 경우

법규상 채권자나 집행관이 집행한 사실을 법원에 보고하여야 할 의무는 없으나 채권자 또는 집행관으로 하여금 집행하였음을 자발적으로 보고하도록 하여 그와 같은 보고가 있으면 채무자에게 재판서 정보를 송달한다. 그 통지가 없으면 집행기간의 경과 후에 채무자에 대한 송달을 실시한다. 241

제2절 집행기간

1. 의의 및 성질

민사집행법 292조 2항은 가압류에 대한 재판의 집행은 채권자에게 재판을 고지한 날부터 2주일을 넘긴 때에는 하지 못한다고 규정하고 있고 이 규정은 같은 법 301조에 의하여 가처분의 집행에도 준용된다. 이와 같이 보전처분을 집행할 수 있는 기간을 집행기간이라 한다. 이처럼 집행기간을 둔 취지는 보전처분은 발령 당시의 사정만을 고려하여 임시적·잠정적으로 집행하게 하는 것인데, 발령 후 오랜 시일이 경과함으로써 여러 가지 사정이 변경되었음에도 불구하고 언제까지라도 집행할 수 있도록 하는 것은 부당하기 때문이다.

집행기간은 법정기간으로서, 이는 채무자의 이익만을 위한 기간은 아니고 채권자의 권리 행사 확보와 채무자보호의 요청을 조화시키기 위하여 국가의 집행권을 제한하는 공익적 규

정이므로, 법원이 임의로 신장할 수 없고, 채무자도 그 기간경과의 이익을 포기할 수 없다.

또 채권자의 책임 없는 사유로 인하여 집행기간을 준수할 수 없었을 때(집행관의 해태, 법원사무관등의 등기촉탁 해태 등) 민사소송법 173조를 준용하여 추후보완할 수 있는가에 관하여도 견해는 나뉜다, 집행기간은 이를 위반한 자에게 제재를 가하려는 뜻이 아니고 시일의 경과에 따른 사정의 변경을 염려하여 채무자의 보호를 꾀한 규정이므로 부정함이 타당하다. 다만 채무자의 방해행위로 인하여 그 집행에 착수할 수 없었을 때에는 집행기간을 둔 취지에 비추어 볼 때 그 집행방해 행위의 종료 시까지는 집행기간이 진행되지 않는다.

242 2. 기산점

가. 원칙

집행기간은 집행이 가능한 때부터 진행하고, 기간의 계산은 민법에 의한다. 즉시 집행에 착수할 수 있는 보전처분(가압류, 부동산점유이전금지가처분 등)은 채권자에게 그 재판을 고지한 날부터 집행기간이 진행한다(민집 292조 2항, 301조). 보전처분 발령 후 경정결정이 이루어진 경우에는 통상적으로 집행기간이 새로 진행하지 않는다. 보전처분의 수통 또는 재도부여의 경우에도 집행기간의 기산점은 변하지 않고, 채권자가 임의로 보전집행을 취소하였더라도 집행기간 경과 전에는 다시 집행할 수 있다.

집행개시 전에 집행정지의 명령이 있으면 다시 집행이 가능한 때, 즉 그 정지명령의 효력상실 시에 다시 집행기간이 기산된다. 그러나 이의신청이 있다 하여 집행이 당연히 정지되는 것은 아니므로 이의사건의 결정에서 보전처분이 인가되었다고 하여 집행기간이 다시 갱신되는 것은 아니다.

나. 예외

가처분 중에는 재판의 고지와 동시에 즉시 집행에 착수할 수 없는 것이 있다. 이때에는 집행기간의 기산점을 별도로 살펴야 한다.

(1) 정기급부를 명하는 가처분

정기이행을 명하는 경우(매월 일정한 날에 금전의 지급을 명하는 가처분 등)에는 각 급부에 대하여 개별적으로 집행기간이 적용되므로, 매 이행기로부터 2주 이내에 집행에 착수하여야 한다.

(2) 대체적 작위를 명하는 가처분

일정한 작위를 명하는 가처분의 경우에 그 작위가 대체적인 경우에는 대체집행(민집 260조)에 의하고 부대체적인 경우에는 간접강제(민집 261조)에 의하게 되는데 이때의 집행기간은 대체집행신청이나 간접강제신청에 대한 인용재판이 있을 때부터 진행되는 것이 아니라 가처분재판의 고지일로부터 2주일 내에 대체집행 또는 간접강제의 신청이 있어야 한다(대결 2001. 1. 29. 99마6107). 243

(3) 부대체적 작위를 명하는 가처분

가처분에서 명하는 부대체적 작위의무가 일정 기간 계속되는 경우라면, 채무자가 성실하게 그 작위의무를 이행함으로써 강제집행을 신청할 필요 자체가 없는 동안에는 위 집행기간이 진행하지 않고, 채무자의 태도에 비추어 작위의무의 불이행으로 인하여 간접강제가 필요한 것으로 인정되는 때에 그 시점부터 2주일의 집행기간이 진행된다고 보아야 한다(대결 2010. 12. 30. 2010마985).

하지만 부대체적 작위채무의 이행을 명하는 가처분결정과 함께 그 의무위반에 대한 간접강제결정이 동시에 이루어진 경우에는 간접강제결정 자체가 독립된 집행권원이 되고 간접강제결정에 기초하여 배상금을 현실적으로 집행하는 절차는 간접강제절차와 독립된 별개의 금전채권에 기초한 집행절차이므로, 그 간접강제결정에 기한 강제집행을 반드시 가처분결정이 송달된 날로부터 2주 이내에 할 필요는 없다(대결 2008. 12. 24. 2008마1608).

(4) 부작위를 명하는 가처분

집행을 따로 요하지 아니하는 단순히 부작위를 명하는 가처분의 경우에는 원칙적으로 집행기간의 문제가 생기지 않으나 채무자가 명령위반행위를 하면 채권자는 그 제거 또는 방지를 구할 수 있는데(민집 260조, 민 389조 3항), 그 명령위반 행위 시로부터 그 제거나 방지를 위한 신청의 집행기간이 개시된다. 채무자에 대하여 단순한 부작위를 명하는 가처분은 그 가처분재판이 채무자에게 고지됨으로써 효력이 발생하는 것이지만, 채무자가 그 명령 위반의 행위를 한 때에 비로소 간접강제의 방법에 의하여 부작위 상태를 실현시킬 필요가 생기는 것이므로 그때부터 2주 이내에 간접강제를 신청하여야 함이 원칙이고, 다만 채무자가 가처분재판이 고지되기 전부터 가처분재판에서 명한 부작위에 위반되는 행위를 계속하고 있는 경우라면, 그 가처분결정이 채권자에게 고지된 날부터 2주 이내에 간접강제를 신청하여야 하고, 그 집행기간이 지난 후의 간접강제 신청은 부적법하다(대결 2010. 12. 30. 2010마985). 244

다. 일단 취소된 집행을 재집행하는 경우

(1) 의의

재집행은 보전처분이의·취소절차에서 보전처분을 취소하였으나 항고심에서 채권자가 승소하여 다시 집행을 하는 경우가 전형적인 예이다. 이 경우 재집행은 집행기간의 제약을 받지 않는다고 해석하는 견해도 있다. 그러나 이미 종전의 집행이 취소된 이상 재집행을 종전 집행의 속행이라고 보는 것은 무리이므로, 보전항고결정이 채권자에게 송달된 다음 날부터 새로운 집행기간이 진행된다고 해석하는 것이 타당하다.

(2) 항고법원이 집행법원이 되는 경우

상소법원에서 보전처분취소결정을 취소·변경함으로써 그 보전처분에 관하여 새로운 집행이 필요하게 된 때에는, 법원이 집행기관이 되는 경우에 한하여 절차의 신속을 위하여 취소의 재판을 한 상소법원이 직권으로 그 집행절차를 진행하여야 한다(민집 298조 1항, 301조). 이 경우 채권자가 1심법원에 보전집행신청을 한 것은 여전히 유효하므로 채권자는 다시 보전집행신청을 할 필요가 없다. 따라서 항고법원은 보전처분취소결정을 취소·변경함과 동시에 보전집행에 착수하여야 하고, 위 결정이 채권자에게 송달된 다음날부터 2주가 경과하면 보전집행을 할 수 없다. 이와 달리 집행관이 집행기관이 되는 경우에는 채권자는 다시 집행신청을 하여야 한다.

(3) 대법원이 보전처분취소결정을 취소·변경한 경우

245 대법원에서 보전처분취소결정을 취소·변경함으로써 그 보전처분에 관하여 새로운 집행이 필요하게 된 때에는 법원이 집행기관이 되는 경우에 한하여 채권자의 신청에 따라 1심 법원이 집행한다(민집 298조 2항, 301조). 채권자의 집행신청이 있으면 1심법원은 기록이 송부되기 전이라도 즉시 집행에 착수하여야 한다. 그러나 보전처분취소결정의 취소·변경결정이 채권자에게 송달된 다음날부터 2주가 경과하면 보전집행을 할 수 없다.

3. 집행의 의미

가. 집행의 착수

2주일 내에 집행하여야 한다는 의미는 원칙적으로 2주일 내에 집행에 착수하여야 하고 또 그것으로 족하다고 해석된다. 다만 판례는 예외적으로 간접강제에 의하여 보전처분을

집행하는 경우에는 간접강제의 신청만으로 집행기간을 준수한 것으로 보고 있다(대결 2010. 12. 30. 2010마985). 일단 집행에 착수하면 그에 당연히 수반되는 절차는 집행기간 경과 후에 이루어져도 좋다. 이미 실시된 집행에 관하여 그 보관방법을 변경하는 것은 집행기간 경과 후에도 할 수 있다(대결 1957. 10. 21. 4290민재항35). 그러나 집행의 일부에 착수하였더라도 그 집행행위와는 별개의 집행행위를 따로 할 때에는 역시 집행기간 내에 착수되어야 한다(예를 들어, 동산가압류에 있어 일부 동산에 대해 집행하고 집행기간 내에 집행의 착수가 없었던 별도의 동산에 대해 다시 집행하는 때).

나. 구체적인 예

(1) 유체동산의 집행은 집행관이 압류할 재산을 찾기 위하여 채무자의 가옥, 사무실, 창고 그 밖의 장소에 대한 수색에 나아가면 집행의 착수로 볼 수 있다. 일단 집행에 착수한 이상 같은 장소에서 집행을 마치지 못한 동산을 집행하는 것은 먼저의 집행을 속행하는 것으로 볼 수 있으므로 집행기간의 제약을 받지 않는다.

(2) 부동산가압류는 가압류재판에 관한 사항을 등기부에 기입하는 것으로 집행하고, 그 246
촉탁은 등기부에 기입하기 위한 수단이므로 등기촉탁서를 발송하면 집행의 착수가 있다고 볼 수 있다. 같은 맥락에서 등기 있는 선박과 등록된 항공기에 대하여는 등기 또는 등록촉탁서를 발송한 때 또는 집행관이 선박국적증서 등을 받기 위하여 수색하는 행동에 나아간 때에, 등록된 자동차와 건설기계에 대하여는 등록촉탁서를 발송한 때 또는 집행관이 그 인도명령의 집행을 위한 행동에 나아간 때에 각각 집행의 착수가 있다고 볼 수 있다. 그 외 광업권, 지식재산권에 대하여는 등록을 촉탁한 때가 된다.

(3) 채권가압류는 가압류명령을 제3채무자에게 발송한 때 집행의 착수가 있고 이 명령이 제3채무자에게 송달됨으로써 집행이 완료된다. 저당권이 붙은 채권에 대한 가압류도 가압류명령을 제3채무자에게 발송한 때 집행의 착수가 있고 이 명령이 제3채무자에게 송달됨으로써 집행이 완료된다. 저당권이 있는 채권에 대한 가압류의 경우에도 부동산소유자에 대한 송달이나 가압류등기는 가압류의 효력발생요건이 아니고, 가압류등기에 공시의 효력만이 있을 뿐이다.

(4) 어음, 수표 그 밖에 배서로 이전할 수 있는 증권으로서 배서가 금지된 증권채권의 가압류는 집행관이 그 증권의 점유를 개시한 때(민집 291조, 233조)가 집행의 착수 시이다. 민사집행법에서는 유가증권으로서 배서가 금지되지 아니한 것을 유체동산으로 보고 있으므로(민집 189조 2항 3호) 집행의 착수시기에 관하여도 유체동산에 대하여 전술한

바에 따르면 된다.

(5) 가처분에서 집행착수시기는 위에서 설명한 바와 같다.

4. 집행의 속행

247 집행의 속행은 원칙적으로 집행기간이 경과한 후에도 할 수 있다. 집행의 착수부터 집행 종료까지는 통일적으로 하나의 집행행위로 볼 수 있다. 동산가압류의 집행에서 집행기간의 마지막 날에 집행에 착수하였으나, 시간적인 이유로 집행을 완료하지 못하여 그 취지를 조서에 기재한 후 다음 날 동일한 장소에서 다른 동산에 대하여 집행을 하는 경우가 집행속행의 전형적인 예이다. 그러나 기간 경과 후 채권자의 신청에 의하여 다른 장소에 있는 동산에 대하여 집행하는 것은 원칙적으로 집행의 속행이라고 보기 어렵다. 동일한 장소라도 집행기간이 상당히 경과한 후에 집행하는 것 또한 집행의 속행이라고 보기 어렵다. 별개의 독립한 다수의 건물이 동일한 가처분명령의 목적이 된 경우 1개의 건물에 대한 집행이 집행기간 내에 이루어졌더라도 집행기간 경과 후에는 다른 건물에 대하여 집행할 수 없다.

집행관이 부당하게 보전처분의 집행을 중지한 것에 대하여 집행에 관한 이의를 신청하여 기간 경과 후 보전처분집행을 하는 것은 집행의 속행에 해당한다. 집행착수 후 채무자의 집행방해에 의하여 집행이 중지된 경우도 이와 같다.

5. 집행기간 경과의 효과

집행기간이 지나면 집행을 할 수 없고, 그 보전처분은 집행력을 잃는다. 따라서 채권자는 새로운 보전처분 신청을 하여 새로운 재판을 받지 않으면 집행이 불가능하다. 집행기간 경과와 유무는 집행기관이 직권으로 조사하고 집행기간이 경과한 경우에는 집행신청을 각하한다. 집행기간이 지났는데도 집행을 하면 위법한 집행으로서 채무자는 집행에 관한 이의 또는 사정변경을 이유로 한 보전처분의 취소로 구제받을 수 있다.

채권자가 임의로 가압류의 집행을 해제한 경우에도 그 명령만은 존속하고 있으므로 집행기간 내라면 다시 집행에 착수할 수 있다. 당사자가 합의하여 집행을 중지하거나 해제한 경우에도 집행기간 내라면 별 문제가 없으나 기간 경과 후라면 다시 집행할 수 없다.

그러나 집행기간이 경과하였다 하여 보전처분 자체의 효력이 상실되는 것은 아니므로 채무자가 보전처분 자체의 효력을 없애려면 사정변경에 의한 취소신청을 하여야 한다.

제3절 본집행으로의 이전

248

1. 개요

가. 의의

보전처분은 강제집행의 보전을 목적으로 하는 임시적인 처분이므로 채권자가 집행권원을 얻어 강제집행을 할 수 있게 되면 보전처분이 집행되어 있는 상태에서 본집행을 하게 된다. 이를 본집행으로의 이전이라고 부른다. 본집행으로의 이전절차에서 가장 중요한 점은 보전처분이 집행된 상태에서 시간적 간격이 없이 그대로 본집행이 효력을 발생하게 되어야 한다는 점이다.

나. 이전의 요건

(1) 주관적 동일성(당사자의 동일성)

보전집행의 당사자와 본집행의 당사자가 동일하여야 한다. 가압류명령이 있었으나 아직 집행이 되기 전에 보전처분의 피보전채권이 양도되었다면 양수인으로서 승계집행문을 부여받아야 가압류의 집행을 할 수 있다(민집 292조, 301조). 하지만 보전집행 완료 후에 피보전권리가 양도된 경우에는 채권을 양수한 자가 본집행절차에서 보전집행의 효력을 주장하기 위해서 승계집행문을 부여받아야 한다는 견해도 있지만, 가압류의 집행이 완료된 후에는 승계집행문을 부여받을 필요 없이 채권양수 사실만을 소명하면 보전집행의 효력을 주장할 수 있다는 것이 통설 및 판례(대판 1993. 7. 13. 92다33251, 대판 2012. 4. 26. 2010다94090)의 입장이다.

채권동계

앞에서 본 채권자의 지위가 양도되거나 승계된 경우와 달리 보전집행 완료 후에 보전처분 채무자의 지위가 승계되는 경우에는 승계집행문이 필요하다(대판 1999. 3. 23. 98다 59118).

채무승계

(2) 객관적 동일성(피보전권리의 동일성)

249

보전처분의 피보전권리와 본안의 소송물인 권리는 엄격히 일치할 필요가 없고, 청구의 기초의 동일성이 인정되는 한 그 보전처분에 의한 보전의 효력은 본안소송의 권리에 미친다는 것이 판례의 입장이다(대판 2006. 11. 24. 2006다35223).

(3) 집행권원의 존재

보전집행의 효과를 누릴 수 있는 것은 확정판결 등 집행권원에 기한 강제집행의 경우에 한하고, 채무자가 임의로 이행한 경우는 포함되지 않는다.

다. 이전의 시기

보전집행이 언제 본집행으로 이전되는지, 즉 언제 보전처분의 집행상태가 종료되는 것인지에 관하여는, ① 집행권원이 성립한 때, ② 집행력 있는 정본이 채무자에게 송달된 때, ③ 본집행이 신청된 때, ④ 본집행이 개시된 때라고 보는 견해가 대립하고 있다.

본집행 신청 후 본집행 개시까지의 시간적 간격을 이용하여 채무자가 목적물을 처분·멸실 또는 훼손함으로써 보전목적달성이 불가능하게 할 위험이 있으므로 집행의 확실성을 확보할 필요성이 있고, 보전집행이 본집행으로 이전할 때 실제로는 소정의 본집행절차를 처음부터 이행하고 있는 실정을 감안하고 절차의 명확성을 기한다는 점에서 본집행 개시(착수) 시에 비로소 본집행으로 이행하는 것으로 해석함이 타당하다. 실무도 본집행이 개시되면서 보전처분의 집행상태가 종료하고 그 이후는 본집행이 된다고 하여 본집행 개시 시점의 입장을 취하고 있다(대판 2004. 12. 10. 2004다54725). 다만 단행가처분의 경우에는 현실적인 집행 또는 집행처분을 다시 할 필요가 없기 때문에 본집행 신청 시에 본집행으로 이전된다.

250 라. 이전의 절차 일반

본집행으로의 이전에서는 원칙적으로 중복되는 절차를 다시 밟을 필요가 없이 보전처분이 집행되어 있는 단계에서 본집행의 다음 절차를 행하면 족하다. 다만 본집행이 효력을 상실하게 되었다고 할 때 어느 절차까지 유효한 보전처분의 집행으로 볼 수 있는가를 판가름할 수 있게 되므로, 언제 본집행이 개시되었는지를 명확히 할 필요가 있다. 실무에서 학설의 대세와는 달리, 채권·지식재산권의 가압류에서 본압류로 이전하는 절차를 밟으면서 다시 압류를 되풀이하는 것은 주로 위와 같이 본집행개시 시를 명백히 하자는 데 그 주안점이 있다.

2. 가압류의 본집행으로의 이전

가. 유체동산에 대한 가압류

집행관은 본집행의 신청을 받으면 그 물건의 보관장소에 임하여 목적물을 점검한 후 채무자에게 본압류를 집행한다는 뜻을 고지하고 가압류의 표시는 그대로 둔 채 덧붙여 본압류의 표시를 부착시킨다. 가압류의 표시를 그대로 두는 것은 나중에 본압류만이 효력을 상실하게 될 때를 대비하는 것이다(다만 그 표시의 문구가 본압류인지 가압류인지 명백하지 않을 때에는 다시 표시를 붙일 필요가 없다). 금전이 가압류되어 공탁되어 있거나(민집 296조 4항) 가압류물이 현금화되어 그 대금이 공탁되어 있을 때에는(민집 296조 5항) 집행관은 보관 중인 공탁서로 공탁금을 회수하여 금전에 대한 강제집행방법에 의하여 집행한다.

나. 채권에 대한 가압류

지명채권에 대한 가압류에서 본압류로의 이전에서는 압류를 다시 할 필요 없이 직접 추심명령·전부명령 등을 하면 족하다는 것이 학설의 대세이나 실무는 압류부터 다시 한다. 이때에는 신청서에도 가압류의 본압류 이전이라는 것을 밝히고 가압류결정서 사본과 가압류 송달증명을 첨부한다(민집규 159조 2항). 집행법원은 이 신청을 받아 집행사건으로 접수하고(재민 91-1), 사건표지에 ‘채권가압류의 본압류이전’이라고 표시한 다음 별책으로 본집행기록을 조제한다.

251

가압류로부터 본압류로 이전하는 경우의 주문례는 다음과 같다.

채권자와 채무자 사이의 ○○지방법원 20 카단○○ 채권가압류결정에 의한 별지 목록 기재 채권에 대한 가압류는 이를 본압류로 이전한다.

채권이 가압류된 다음 본압류로 이전되는 경우 그 집행법원은 가압류를 명한 법원이 있는 곳을 관할하는 지방법원의 전속관할이다(민집 224조 3항). 가압류한 지명채권에 대하여 가압류에서 본압류로 이전하는 내용의 주문이 누락된 채 압류 및 추심명령이 발령되었다 하더라도, 가압류 및 압류·추심의 당사자 사이에 서로 동일성이 인정되고, 가압류의 피보전채권과 압류·추심의 집행채권 사이 및 가압류 대상 채권과 압류·추심 대상 채권 사이에 서로 동일성이 인정되는 경우에는, 해당 가압류는 특별한 사정이 없는 한 당연히 본압류로 이전되는 효력이 생긴다(대판 2010. 10. 14. 2010다48455).

다. 부동산·선박·항공기·자동차·건설기계·소형선박 등에 대한 가압류

부동산과 이에 준하는 선박·항공기·자동차·건설기계·소형선박 등의 경우는 강제경매개시결정을 함으로써 본압류로 이전한다. 가압류가 동일인을 채권자로 하여 여러 개이고 채권자의 집행권원이 그 중 어느 것에 기한 것인지 명백하지 않을 때 등에는 가압류기록을 현출시켜 첨철한다. 경매개시결정의 기입등기를 새로 촉탁하여야 함은 물론이다.

라. 그 밖의 재산권에 대한 가압류

그 밖의 재산권의 경우에도 실무상은 가압류 상태에서 바로 현금화절차로 들어가지 않고 압류를 다시 한 후 현금화하게 된다. 지식재산권으로서 등록을 요하는 경우에는 압류 외에 새로운 등록촉탁을 하여야 한다.

252 3. 가처분의 본집행으로의 이전

가. 부동산에 대한 처분금지가처분

가처분채권자의 피보전권리와 가처분등기 이후에 경료된 제3자 명의의 등기의 종류에 따라 본집행으로 이전하는 절차가 상이하다. 피보전권리가 등기청구권인 경우에는 집행권원에 기하여 등기를 마치는 방법에 의하고, 가처분등기 이후에 경료된 제3자 명의의 등기가 소유권이전등기인 경우에는 그 소유권이전등기가 가처분채권자에 우선하는 경우에는 이를 말소할 수 없지만, 가처분채권자에 우선하지 않는 소유권이전등기나 소유권이전등기 이외의 등기는 말소되어야 한다.

가) 피보전권리가 소유권말소등기청구권인 경우에는 가처분에 기하여 그 이후에 마쳐진 제3자 명의 소유권이전등기와 소유권이전등기 이외 등기에 대한 말소신청을 하여 말소등기를 하여야 한다.

자세한 것은 제9장 제1절 1. 사. 가처분채권자의 본안승소와 피보전권리의 등기절차 참조.

나. 점유이전금지가처분

가) 집행관 보관의 점유이전금지가처분은 이미 채무자의 점유를 해제하여 인도집행을 종료하였기 때문에 새로 점유를 취득하는 절차는 필요 없고 그대로 채권자에게 점유를 이전하

면적이다. 집행관 보관·채무자 사용형의 경우에는 새로이 채무자의 사용을 배제하는 현실적인 집행이 필요하다. 집행관 보관·채권자 사용형은 채권자에게 집행관 보관이 해제되었음을 고지함으로써 족하다.

다. 단행가처분

단행가처분은 본집행에의 이전절차가 불필요하다는 견해도 있으나 임시의 집행을 종국적인 것으로 전환하기 위해서는 본집행이 필요하다. 구체적으로는 집행력 있는 판결정본 등 집행권원에 기하여 본집행의 신청을 하는 것으로 바로 본집행으로 이행됨과 동시에 253 본집행이 집행목적 달성으로 종료한 것으로 처리한다.

4. 이전의 효과

가. 의의

보전집행이 본집행으로 이전된 경우 그 보전집행의 효력에 관하여는 견해의 대립이 있다.

제1설은 보전처분의 집행은 본집행으로 이전됨으로써 장래를 향하여 효력이 소멸되고, 따라서 본집행으로 이전된 후에는 보전집행의 취소 등은 구할 수 없으나 이는 장래에 향하여만 효력이 있는 것이므로 보전집행의 지나간 효력은 그대로 유지되고 채권자는 그로 인한 효과를 그대로 이어 받게 된다고 한다.

제2설은 본집행으로의 이전에 의하여 그 보전집행의 효력이 소멸한다거나 보전처분절차가 당연히 종료한다고 볼 필요는 없고, 본집행에 포섭되어 독자적인 존재를 잃지만 잠재적으로 존속하고 있고, 따라서 본집행의 취소사유가 보전집행의 소멸도 포함한다고 인정할 수 있는 경우를 제외하고는 독립의 존재를 회복한다고 한다. 보전처분이 독자적인 존재를 잃는 결과 본집행이 되어 있는 한 채무자는 보전처분에 특유한 구제(보전처분의 집행취소 등)를 구할 수 없고, 채권자는 보전처분이나 집행만의 취하를 할 수 없으나 청구권의 만족이나 만족불능을 이유로 하여 본집행이 실효되는 경우에는 보전처분 집행의 효력도 소멸한다고 한다.

나. 판례

가압류집행이 있는 후 그 가압류가 강제경매개시결정으로 인하여 본압류로 이전된 경우

254 에 가압류집행이 본집행에 포섭됨으로써 당초부터 본집행이 있었던 것과 같은 효력이 있고(대판 2010. 10. 14. 2010다48455), 본집행의 효력이 유효하게 존속하는 한 상대방은 가압류집행의 효력을 다룰 수는 없으며(대판 2004. 12. 10. 2004다54725), 오로지 본집행의 효력에 대하여만 다투어야 하는 것이므로, 본집행이 취소·실효되지 않는 한 가압류집행이 취소되었다고 하여도 이미 그 효력을 발생한 본집행에는 아무런 영향을 미치지 않는다(대결 2002. 3. 15. 2001마6620). 따라서 부동산에 대한 가압류가 본압류로 이전되어 본집행의 효력이 유효하게 존속하는 한 집행법원의 가압류등기말소촉탁은 그 취지 자체로 보아 법률상 허용될 수 없음이 명백한 경우에 해당된다(대결 2012. 5. 10. 2012마180). 가압류등기 후 제3자 앞으로 소유권이전등기가 마쳐진 부동산에 대하여 가압류채권자의 신청에 의한 강제경매절차가 진행 중에 가압류해방금액을 공탁하였다고 하더라도 이를 이유로 가압류집행을 취소할 수 없고, 나아가 가압류집행취소의 결과 가압류등기가 말소되었더라도 이를 이유로 강제경매개시결정을 취소할 수는 없다(위 2001마6620 결정).

또한 판례는, 본집행의 효력이 없는 것이라면 보전집행의 효력은 그대로 살아나서 보전집행상태가 유지되나(대판 2000. 6. 9. 97다34594), 보전집행과 본집행은 하나의 목적을 위한 일련의 절차로서 일체를 이루는 것이므로 본집행이 목적달성불능으로 종료된 경우(강제경매개시결정이 잉여의 가량이 없어 취소된 경우 등)에는 선행한 보전집행의 효력도 상실한다(대결 1980. 6. 26. 80마146)고 한다.

다. 관련 문제

(1) 보전집행에 대하여 제3자이의의 소가 제기되어 그 소송계속 중에 당해 보전집행이 본집행으로 이전된 경우 본집행의 불허를 구하는 것으로 소를 변경하여야 하는가 또는 신청취지를 정정하면 족한 것인가의 문제가 있다. 가압류 제3자이의의 소와 본집행 제3자이의의 소는 그 소송물이 다르므로 소변경설이 타당하다.

255 (2) 가압류집행의 본압류로의 이전으로 인하여 가압류에 의한 시효중단의 효력이 소멸하는가의 문제가 있으나 가압류와 본압류의 사이에 압류의 연속이 있으므로 결국 가압류의 시효중단의 효력은 소멸하지 아니하고 계속 존속하는 것으로 봄이 타당하다.

(3) 민사집행법 53조 1항의 '강제집행에 필요한 비용'에는 가압류의 집행비용이 당연히 포함된다. 그리고 가압류가 집행된 후 그 가압류가 본압류로 이전된 때에는 가압류집행이 본집행에 포섭됨으로써 당초부터 본집행이 있었던 것과 같은 효력이 있다. 그러므로 가압류만 되어 있을 뿐 아직 본압류로 이전되지 아니한 단계에서는 가압류채권자가 그 가압류의

집행비용을 변상받을 수 없고, 따라서 제3취득자가 가압류의 집행비용을 고려함이 없이 그 처분금지의 효력이 미치는 객관적 범위에 속하는 청구금액만을 변제함으로써 가압류의 집행의 배제를 소구할 수 있다. 그러나 가압류에서 본압류로 이전된 후에는 민사집행법 53조 1항의 적용을 받게 되므로 가압류 후 본압류로의 이행 전에 가압류의 목적물의 소유권을 취득한 제3취득자로서는 가압류의 청구금액 외에, 그 가압류의 집행비용 및 본집행의 비용 중 가압류의 본압류로의 이행에 대응하는 부분까지를 아울러 변제하여야만 가압류에서 이행된 본압류의 집행배제를 구할 수 있다(대판 2006. 11. 24. 2006다35223).

제4절 보전집행의 취소

1. 집행취소의 의의

집행취소는 이미 실시한 보전집행의 전부 또는 일부의 효력을 상실시키는 집행기관의 행위를 말한다. 집행취소는 채권자, 채무자, 제3자의 신청에 의하거나 집행법원이 직권으로 한다.

2. 집행취소의 사유

256

가. 채권자의 집행취소(해제)신청

(1) 개요

채권자는 보전처분의 집행상태가 계속되고 있는 한 언제든지 그 집행취소를 신청할 수 있다. 집행취소신청이라는 용어 외에 집행해제신청 또는 집행신청의 취하라는 용어가 사용되기도 하나 어느 것이나 마찬가지 뜻이다. 집행취소는 채무자에게는 불이익할 것이 전혀 없으므로 채권자가 집행취소의 신청을 함에는 채무자의 동의가 필요 없으며, 또 그 신청에 기한 집행취소결정에 대하여 채무자는 항고할 이익이 없다(대결 1980. 2. 15. 79마351).

(2) 신청절차

채권자의 집행취소신청은 집행기관에 대하여 한다. 즉 채권, 부동산가압류, 부동산의 처분금지가처분과 같이 법원이 집행한 보전처분에 대하여는 법원에, 동산가압류, 부동산

점유이전금지가처분 등 집행관이 집행을 한 보전처분에 대하여는 집행관에게 각각 취소신청서를 제출한다. 집행취소신청을 함에는 그 취소절차에 필요한 비용(송달료, 등록면허세 등)을 예납하여야 하나, 인지를 붙일 필요는 없다. 이 신청은 문서건명부에 등재하고 가철한다(재민 91-1).

(3) 집행취소결정의 요부

집행취소신청에 대하여 제3채무자에게 취소되었음을 명백히 고지할 필요가 있다는 이유로 집행취소결정을 하는 예도 있으나 다수의 실무는 집행취소결정을 하지 않고 바로 집행취소의 절차를 밟는다. 집행취소신청은 보전처분의 집행절차를 이루는 행위에 속하고, 그 신청이 채권자의 의사에 기한 것인지 여부는 집행법원이 조사·판단하여야 할 사항이므로, 그 신청서가 위조되었다는 사유는 그 신청에 기한 집행행위, 즉 보전처분기입등기의 말소촉탁에 대한 집행이의 사유가 된다. 따라서 집행취소신청서 등이 위조되었다고 주장하는 채권자는 집행법원에 대한 집행이의를 통하여 말소회복을 구할 수 있고, 그 집행이
257 의가 이유 있다면 집행법원이 보전처분기입등기의 말소회복등기를 촉탁하여야 하므로, 이러한 경우 채권자가 말소된 보전처분기입등기의 회복등기절차의 이행을 소구할 이익은 없다(대판 2000. 3. 24. 99다27149). 다만 보전처분기입등기가 말소될 당시 그 부동산에 관하여 소유권이전등기를 마친 자와 같이 등기상 이해관계가 있는 제3자가 있는 경우에는 그의 승낙서를 집행법원에 제출하여야 하므로, 승낙을 하지 않는다면 그 이해관계인을 상대로 보전처분기입등기의 회복절차에 대한 승낙청구의 소를 제기할 수 있다(대판 1997. 2. 14. 95다13951, 대판 2002. 4. 12. 2001다84367).

나. 해방금액의 공탁을 이유로 한 채무자의 가압류집행취소신청

(1) 개요

채무자가 가압류명령에 기재된 해방금액을 공탁하였을 때에는 법원은 집행한 가압류를 취소하여야 한다(민집 299조 1항) (그 공탁금의 성질 등은 제4장 제3절 3. 마. 해방공탁금의 표시 참조). 해방금액은 금전에 의한 공탁만이 허용되고, 유가증권에 의한 공탁은 그 유가증권이 실질적 통용가치가 있는 것이라고 하더라도 허용되지 않는다[대결(전) 1996. 10. 1. 96마162].

채무자 아닌 제3자가 해방금액을 공탁할 수 있느냐에 관하여는 나중에 채권자가 채무자에 대한 집행권원을 받아도 그 해방금액에 대한 집행을 할 근거가 없게 되므로 부정하여야

할 것이다. 또 해방금액의 일부만을 공탁하고 가압류집행 일부만을 취소신청 하는 것도 허용되지 않는다. 공탁은 해방금액을 공탁사무 문서양식에 관한 예규(행정예규 제1153호) 별표 제1-3호 양식에 의하여 공탁함으로써 한다.

(2) 신청과 결정

(가) 해방금액을 공탁한 채무자는 그 공탁서를 첨부하여 가압류를 발령한 법원에 가압류 집행을 취소를 신청한다(재민 91-1 3조 1항 [별표] 참조). 절차비용을 예납하여야 함은 258 채권자가 신청한 경우와 같다.

(나) 이 신청이 있으면 신청사건부에 등재하고(재민 91-1) 집행취소의 결정을 한다. 취소결정은 확정되지 아니하여도 고지와 동시에 효력이 생긴다(민집 299조 4항). 원래 강제 집행절차를 취소하는 결정은 확정되어야 효력이 있지만(민집 17조 2항) 채무자가 해방금액을 공탁하여 가압류집행취소결정을 얻어도 집행취소결정이 확정될 때까지는 집行的 취소를 받을 수 없다고 하면 채무자에게 이중의 부담을 가하게 되는 부당한 결과가 되므로 민사집행법 299조 4항은 같은 법 17조 2항의 적용을 배제한 것이다. 이 결정에 대하여는 채권자가 즉시항고할 수 있다(민집 299조 3항). 결정 양식은 다음과 같다.

[전산양식 A4760] 해방공탁을 이유로 한 가압류집행취소결정

○ ○ 지 방 법 원 결 정	
사 건 20 카기 채 권 자 채 무 자	주 문 이 법원의 20 . . . 자 20 카단 가압류 결정 정본에 의하여 20 . . . 별지 기재 에 대하여 실시한 가압류의 집행을 취소한다.
이 유 이 법원 20 카단 가압류사건에 관하여 채무자가 가압류명령에서 정한 원을 공탁(○○법원 20○○년 금제○○○호)하고 한 가압류 집행취소신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.	
2000. ○. ○. 판사(사법보좌관) ㉠	

259 집행취소신청을 각하 또는 기각하는 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 없다(민집 15조 1항 참조). 집행취소를 하였어야 함에도 집행취소신청을 부당하게 기각하거나, 집행기관이 집행취소절차에 착수하지 아니하는 경우는 집행이의사유가 된다.

(다) 이와 같이 가압류집행이 취소되더라도 가압류명령 그 자체의 효력이 소멸되는 것은 아니다. 그리고 집행이 취소되면 해방공탁금은 앞으로 가압류채권자가 본안청구에 관하여 승소의 확정판결을 받거나 가집행선고가 붙은 승소판결을 얻은 때에 집행의 목적물로 된다.

이 경우 전해가 나누어지나 가압류의 효력은 공탁금 자체가 아니라 공탁자인 가압류채무자의 공탁금 회수청구권에 대하여 미치고, 가압류채권자는 본안승소판결의 집행력 있는 집행권원에 기하여 가압류채무자가 가지는 공탁금 회수청구권에 대하여 집행법원의 현금 화명령(전부명령 또는 추심명령)을 받아서 공탁금을 회수할 수 있다고 하는 것이 실무의 태도이다. 따라서 가압류채무자의 다른 채권자가 해방공탁금 회수청구권에 대하여 압류명령을 받은 경우에는 가압류채권자의 가압류와 다른 채권자의 압류는 그 집행대상이 같아서 서로 경합하게 된다(대결 1996. 11. 11. 95마252). 다만 가압류채무자에게 해방공탁금의 용도로 금원을 대여하여 가압류집행을 취소할 수 있도록 한 자는 특별한 사정이 없는 한 가압류채권자에 대한 관계에서 공탁금 회수청구권에 대하여 위 대여금 채권에 의한 압류 또는 가압류의 효력을 주장할 수는 없다(대판 1998. 6. 26. 97다30820).

(라) 가압류채권자가 가압류신청을 취하하거나 집행을 해제하면 가압류채무자는 그 증명서를 첨부하여 해방공탁금의 반환을 청구할 수 있다. 또한 가압류채무자가 본안소송에서 승소하면 이를 이유로 사정변경에 의한 가압류취소신청을 하여 가압류취소결정을 받아 해방공탁금을 반환받을 수 있다.

260 다. 보전처분신청의 취하를 이유로 한 채무자의 집행취소신청

(1) 개요

보전처분신청이 취하되었을 때 채무자가 이를 이유로 집행취소신청을 할 수 있는가에 관하여는 전해가 엇갈리나 실무상은 할 수 있는 것으로 본다. 또 이 집행취소의 신청을 민사집행법 299조에 준하는 것으로 볼 것인가, 같은 법 49조, 50조에 준하는 것으로 볼 것인가에 대하여도 논의가 있으나, 실무는 보전처분의 취하서 또는 취하증명서를 같은 법 49조의 서면에 준하는 것으로 보고 같은 법 50조에 의하여 집행을 취소하는 것으로 본다.

다만 보전처분신청취하의 효력이 발생하는 시점과 집행의 효력이 소멸하는 시점이 일치하는 것은 아니다. 예를 들면 채권가압류에서 채권자가 채권가압류신청을 취하하면 채권

가압류명령은 그로써 효력이 소멸되지만, 채권가압류명령 정본이 제3채무자에게 이미 송달되어 채권가압류명령이 집행되었다면 그 취하통지서가 제3채무자에게 송달되었을 때에 비로소 그 가압류집행의 효력이 장래를 향하여 소멸된다(대판 2001. 10. 12. 2000다19373). 취하통지서가 제3채무자에게 송달되기 전에 제3채무자가 집행법원 법원사무관 등의 통지에 의하지 아니한 다른 방법으로 가압류신청 취하사실을 알게 된 경우에도 취하통지서의 송달이 필요하다(대판 2008. 1. 17. 2007다73826).

(2) 신청과 집행취소

이 집행취소신청을 실무와 같이 민사집행법 49조, 50조에 의한 취소로 본다면 채무자는 집행기관(집행법원 또는 집행관)에 보전처분신청취하증명서를 첨부하여 비용과 함께 집행취소의 신청을 하여야 하고 집행기관은 별도의 결정 없이 집행취소절차에 착수한다. 이 신청은 문서건명부에 등재하고 가철한다. 인지를 붙일 필요는 없다(재민 91-1).

라. 보전처분취소에 따른 채무자의 집행취소신청

261

(1) 개요

보전처분에 대한 이의·취소사건 등에서 보전처분을 취소하는 결정이 있거나 민사집행법 309조 1항에 의하여 집행한 가처분을 취소하는 결정이 있는 경우 실무는 채무자가 같은 법 49조, 50조에 의해 그 재판서 정본을 집행기관에 제출하여 집행취소를 신청하면 집행취소절차를 밟고 있다.

보전처분취소결정 등에 대하여 상소가 제기되어 사건기록이 상소심으로 송부된 후에도 집행취소사건의 관할법원은 보전처분을 한 법원(집행법원)이다. 따라서 이때 채무자가 집행법원에 보전처분을 취소하는 재판서 정본과 보전처분의 등기가 마쳐진 등기사항증명서 등본을 첨부하여 집행취소를 신청하면 상소심에 기록송부촉탁을 하여 기록을 송부받거나 사건이 종결되어 기록이 되돌아올 때까지 기다릴 것이 아니라, 이들 서류만으로도 집행취소 사유는 충분히 소명되는 것이므로 곧바로 말소촉탁을 하고, 등기관으로부터 전자적으로 등기완료 통지를 받으면 관련기록을 사건이 계속 중인 상소심으로 추송하는 것이 바람직할 것이다.

(2) 신청

신청서에는 보전처분의 취소를 명하는 재판서의 정본이 첨부되어야 하며 비용이 예납되

어야 한다. 집행기관은 별도의 결정 없이 즉시 집행취소의 절차를 밟아야 한다. 이 신청은 문서건명부에 등재하고 가철한다(재민 91-1).

마. 제3자의 집행취소신청

제3자가 제3자이의의 소를 제기하여 승소한 결과 보전처분의 집행력을 배제하는 재판을 얻게 되면, 제3자는 집행기관에 재판서正本과 비용을 예납하고 집행취소를 신청하여야 한다. 한편 부동산에 대한 가압류등기가 무효라면 부동산소유자는 가압류채권자를 상대로 그 가압류등기의 말소청구를 할 수 있지만(대판 1988. 10. 11. 87다카2136), 무효가 아닌 가처분등기 경료 후 가처분목적물에 대한 소유권을 취득한 사람은 집행법원에 가처분결정취소나 집행취소신청을 하여 그 결정을 받아 이를 원인증서로 하여 가처분등기를 말소시킬 수 있을 뿐, 곧바로 가처분등기 자체의 말소를 소구할 수 없다(대판 1976. 3. 9. 75다1923, 대판 1982. 12. 14. 80다1872).

바. 직권에 의한 집행취소

채권자가 집행비용을 미리 내지 아니한 때에는 법원은 직권에 의하여 결정으로 집행을 취소할 수 있다(민집 18조 2항). 채권자는 집행취소결정에 대하여 즉시항고할 수 있다(민집 18조 3항).

3. 집행취소의 절차

가. 집행취소기관

집행취소는 집행기관이 실시한다. 집행법원이 집행취소결정을 한 경우에도 집행기관이 집행관인 때에는 채무자는 그 결정 정본을 집행관에게 제출하여 집행취소를 위임하여야 한다.

나. 집행취소의 방법

집행취소는 보전처분의 집행상태를 소멸시키는 절차를 취하는 것으로서 그 구체적 절차는 각종의 보전처분에 따라 다르다.

(1) 등기·등록을 요하는 집행의 취소

부동산·선박·항공기·자동차·건설기계·소형선박·지식재산권의 가압류, 처분금지가처분 등과 같이 등기·등록을 함으로써 보전처분을 집행한 경우에는 집행법원의 법원사무관 등이 보전처분기입등기·등록의 말소를 촉탁함으로써 취소한다(민집 293조 3항 참조). 그 등기촉탁서의 양식은 다음과 같다.

[전산양식 A4764] 부동산가압류 말소등기촉탁서

263

○ ○ 법 원							
등기촉탁서							
							등기관 귀하
사 건 20 카단 부동산가압류							
부동산의 표시							
등기관리자							
등기의무자							
등기원인과 그 연월일 20 . . . 가압류 집행취소신청							
등 기 목 적 20 . . . 자 가압류기입등기의 말소등기							
과 세 표 준 1건							
등록면허세 금 ○○원(시·도명, 등록세 납세번호)							
지방교육세 금 ○○원							
등기신청수수료 금 ○○원							
첨 부 가압류 집행해제신청서 부분 1통							
위 등기를 촉탁합니다.							
2000. ○. ○.							
법원사무관				[직인]			
접 수	. . .	처 리 인	접 수	조 사	기 입	등기필 통 지	비 고
제 호							

전자기록사건 중 부동산가압류·가처분등기가 전자촉탁으로 이루어진 경우에는 이에 대한 말소등기촉탁은 해당법원과 등기소 사이에 연계된 서버를 이용하여 전자적 방법으로 촉탁하여야 한다. 다만 전산장애 등으로 인하여 전자촉탁이 불가능한 경우에는 서면촉탁으로 한다(재일 2012-1 111조). 이후 등기관으로부터 등기완료통지 또는 말소통지를 전자적으로 받은 경우, 그 통지에 관한 관련 정보를 전자사건부에 표시한다(재일 2012-1 42조 1항 13호).

집행취소결정이 있을 때에는 등기원인을 ‘가압류집행취소결정’이라고 쓰고 그 결정 정 264

본을 첨부한다. 과세표준은 1건이라고 쓰고 지방세법 28조 1항 1호 마목에 따른 등록면허세와 같은 법 151조 1항 2호에 따른 지방교육세를 납부하여야 한다.

(2) 채권의 집행취소

제3채무자에게 취소되었음을 명백히 고지할 필요가 있다는 이유로 집행취소결정을 하는 경우에는 집행법원의 법원사무관등이 집행취소결정 정보(해방공탁에 의한 집행취소의 경우)이나 보전처분취소결정 정보(이의사건이나 취소사건의 경우)를 첨부하여 집행취소통지서[전산양식 A4317]를 제3채무자에게 송달한다(민집규 160조 1항, 213조 2항). 하지만 다수 실무례처럼 집행취소결정을 하지 않고 집행취소절차를 밟는 경우에는 취소신청서 부분(채권자신청의 경우), 보전처분신청취하증명서 등과 함께 법원사무관등이 작성한 집행취소통지서를 제3채무자에게 송달한다.

가압류의 취소를 명하는 결정이 있다고 하더라도, 채무자가 그 결정 정보를 집행법원에 제출하면서 가압류의 집행취소를 신청하여, 집행법원이 이에 따른 가압류의 집행취소절차를 밟기에 이르지 아니한 이상 가압류 집행의 효력은 여전히 유지되는 것이고, 이러한 절차가 취하여지지 않은 채 가압류명령을 한 법원이 이의를 받아들여 취소결정을 한 다음 제3채무자에게 결정문을 송달하였다 하더라도 그것만으로 위 가압류의 집행이 당연히 취소되었다고 할 수 없다(대판 2003. 7. 22. 2003다24598).

(3) 집행행위가 필요 없는 보전처분의 집행취소

부작위의무를 명하는 보전처분의 경우와 같이 따로 집행행위가 필요 없이 채무자에게 결정 정보를 송달함으로써 집행하는 보전처분은 그 취소를 함에도 위 (2)에서 설명한 서면(집행취소결정 정보 등)을 채무자에게 송달함으로써 족하다.

(4) 집행관이 행한 집행의 취소

265 집행관이 그 집행상태를 제거하는 조치를 취함으로써 한다. 부동산점유이전금지가처분의 경우에는 집행관이 현장에 임하여 가처분에 관한 공시문을 제거하고 집행관의 점유를 해제하며 채무자의 점유로 되돌린다는 취지를 채무자에게 알린다. 하지만 동산점유이전금지가처분의 경우에는 집행관이 채무자의 점유를 배제하고 직접점유한 물건은 현실로 점유를 반환하는 절차가 필요하다.

(5) 단행가처분의 집행취소

금전지급, 물건의 인도단행가처분은 집행이 취소되어도 집행관이 당연히 원상회복을 위

한 집행을 할 수 있는 것은 아니다. 집행취소는 장래에 향해서만 효력이 있기 때문이다. 다만 가처분을 취소하는 재판에서 민사집행법 308조에 따라 원상회복을 명한 경우에는 그 재판을 집행함으로써 원상회복을 시킬 수 있다.

4. 집행취소의 효과

가. 소급효의 부존재

보전처분집행의 구속력에서 해방되는 것은 장래에 대하여만 효력이 있고 소급하는 것이 아니다. 따라서 가압류목적물을 현금화한 경우에는 그 현금화한 금전을 채무자에게 지급하면 족하고 그 현금화의 효력이 번복되는 것은 아니며, 직무대행자가 한 행위는 집행취소 후에도 유효하다.

나. 소멸시효 중단 효과의 소급적 소멸

채무자의 금전채권에 대하여 가압류가 행하여진 후 채권자의 신청에 의하여 그 집행이 취소되었다면, 다른 특별한 사정이 없는 한 가압류에 의한 소멸시효 중단의 효과는 소급적으로 소멸된다(대판 2010. 10. 14. 2010다53273). 그러나 보전집행 후 3년간 본안의 소를 제기하지 아니하였음을 이유로 한 가압류취소는 시효중단의 효력이 소급하여 없어지는 민법 175조에서 정한 가압류취소의 경우에 해당하지 않는다(대판 2009. 5. 28. 2009다20).

다. 보전처분의 구속력에서 해방

집행취소 결과 채무자와 집행목적물에 이해관계를 갖는 제3자는 보전처분의 구속에서 벗어나게 된다. 따라서 가처분취소결정의 집행에 의하여 처분금지가처분등기가 말소된 경우 그 효력은 확정적인 것이므로, 그 이후에 당해 부동산에 관한 소유권이전등기를 마친 사람은 그 부동산에 관하여 아무런 제한을 받지 않고 가처분채권자에게 그 소유권 취득의 효력으로 대항할 수 있다(대판 1998. 10. 13. 96다42307, 대판 2000. 10. 6. 2000다32147). 가처분등기가 말소되기 전에 이전등기를 한 경우에도 같다.

보전처분취소결정이 상고심에서 취소되었다 하더라도, 취소된 보전처분집행이 소급하여 부활할 수 없고, 그 보전처분취소결정의 집행으로 이루어진 보전처분등기의 말소등기가 원인무효의 등기가 되는 것이 아니며, 이미 보전처분취소결정의 집행에 의하여 말소된

등기가 당연히 회복되는 것도 아니다.

라. 제1심결정에 따라 집행취소된 경우 항고심 등의 업무처리 방향

보전처분취소결정의 집행에 의하여 보전처분등기가 말소된 경우 그 효력은 확정적인 것이다. 따라서 처분금지가처분결정에 따른 가처분등기가 마쳐져 있던 상태에서 부동산을 양수하여 소유권이전등기를 마친 제3자라 하더라도 가처분등기가 말소된 이후에는 더 이상 처분금지효의 제한을 받지 않고 소유권 취득의 효력으로 가처분채권자에게 대항할 수 있게 된다. 이러한 경우 가처분채권자는 더 이상 처분금지가처분을 신청할 이익이 없다(대결 2017. 10. 19. 2015마1383).

항고심으로서의 아무리 채권자의 피보전권리가 인정되고 보전의 필요성이 인정된다고 하더라도 채권자의 보전신청은 신청의 이익을 상실하여 부적법하므로 당해 보전처분결정을 취소한 제1심결정은 결과적으로 정당하다고 보아, 채권자의 항고를 기각하여야 한다. 그럼에도 불구하고 항고심이 제1심의 가처분취소결정에 대해 채권자의 항고를 받아들여
267 제1심결정을 취소하고 채무자의 가처분취소 신청을 기각하였다면, 대법원은 직권으로 원심결정을 파기하고 채권자의 항고를 기각하여야 한다(대결 2017. 10. 19. 2015마1383).

제5절 보전처분집행에 관한 불복

보전처분집행에 관한 불복방법으로는 집행에 관한 이의, 집행문부여의 소, 집행문부여에 대한 이의의 소, 제3자이의의 소, 집행항고 등이 있다. 이 중 집행문부여의 소나 집행문부여에 대한 이의의 소는 강제집행에 관한 설명과 큰 차이가 없으므로, 이하에서는 나머지 불복절차에 관하여 설명한다.

1. 집행에 관한 이의

가. 이의의 대상

(1) 집행법원의 집행절차에 관한 재판으로 즉시항고할 수 없는 것

집행에 관한 이의의 대상은 집행법원의 집행절차에 관한 재판으로 즉시항고할 수 없는

것이다(민집 16조 1항). 집행에 관한 이의는 집행 또는 집행행위에서 형식적인 절차상 하자가 있는 경우에 한하여 할 수 있기 때문에, 채무자 명의의 등기는 실체관계에 부합하지 않는 무효의 등기이고 그 부동산의 소유자는 신청인이라는 실체적 권리관계에 관한 사유는 부동산가압류집행에서 집행에 관한 이의사유가 될 수 없다(대결 1981. 5. 30. 80마490). 그러나 집행법원의 착오에 따른 등기촉탁에 의하여 가압류기입등기가 말소되어 가압류채권자가 회복등기의 촉탁신청을 하였으나 이를 거절한 처분에 대하여 불복하는 경우(대판 1996. 5. 31. 94다27205), 가처분결정취소재판 정본의 제출에 따른 간접강제결정 취소결정에 대하여 불복하는 경우(집행에 관한 이의만이 인정되고 즉시항고가 허용되지 아니하는 경우라면 불복하면서 제출한 서면의 제목이 ‘즉시항고장’이고, 그 끝 부분에 항고법원명이 기재되어 있다 하더라도 이를 집행에 관한 이의로 보아 처리하여야 한다. 대결 2000. 3. 17. 99마3754), 가처분해제신청서가 위조되었다고 주장하는 가처분채권자가 법원의 촉탁에 의하여 말소된 가처분기입등기의 말소회복을 구하는 경우(대판 2000. 3. 24. 99다27149), 서로 모순·저촉되는 점유이전금지가처분집행이 경합된 경우(대결 1981. 8. 29. 81마86) 등에는 집행에 관한 이의가 인정된다. 또한 집행취소사유가 존재하여 당사자가 집행취소문서를 제출하였음에도 집행기관이 집행취소절차에 착수하지 아니하거나 해태한 경우에도 집행이의사유가 인정된다.

268

(2) 집행관의 집행처분 및 집행관이 지킬 집행절차

집행관의 집행처분은 법률효과를 수반하는 처분을 말한다. 동산에 대한 가처분집행이 그 대상물을 전혀 특정되지 아니한 채 이루어진 경우 집행관의 집행처분은 무효이나 형식적인 집행처분이 존재하고 있으므로 상대방은 집행에 관한 이의를 통하여 무효확인을 구하는 취지의 집행취소를 구할 수 있다(대결 1999. 5. 13. 99마230). 집행관이 지킬 집행절차란 집행관이 당사자의 신청을 각하하거나 집행기록의 열람을 거부하는 것과 같이 집행처분 이외에 집행관이 집행절차에서 지켜야 하는 절차를 말한다.

(3) 집행관의 집행거부, 집행지체, 수수료에 관한 분쟁

집행관이 집행을 위임받기를 거부하거나(대결 2005. 5. 20. 2004그162), 집행행위를 지체하거나 집행관이 계산한 수수료에 대하여 다툼이 있는 경우에는 집행에 관한 이의를 할 수 있다(민집 16조 3항).

나. 집행이의사건의 절차

(1) 관할

집행법원이나 집행관이 집행절차를 실시할 곳이나 실시한 곳을 관할하는 지방법원이 집행에 관한 이의사건의 전속관할법원이 된다(민집 21조).

269 (2) 신청

집행이의신청은 기일에 출석하여 제기하는 경우를 제외하고는 서면에 의하여야 하고, 이의의 이유를 구체적으로 밝혀야 한다(민집규 15조). 신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다(인지 9조 5항 4호). 집행이의는 보전처분집행이 종료되기 전(본집행으로 이전되기 전)까지 제기할 수 있다.

(3) 재판

집행이의에 대한 재판은 변론 없이 할 수 있다(민집 3조 2항). 입증의 정도에 관하여 특별한 규정이 없으므로, 소명으로는 부족하고 증거가 있어야 한다. 집행이의의 재판은 결정으로 한다. 집행절차를 취소하는 결정, 집행절차를 취소한 집행관의 처분에 대한 이의 신청을 기각·각하하는 결정 또는 집행관에게 집행절차의 취소를 명하는 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있고(민집 17조 1항), 위 결정은 확정되어야 효력을 가진다(민집 17조 2항). 집행에 관한 이의신청을 기각하는 결정(대결 2005. 10. 31. 2005그87, 대결 2009. 5. 20. 2009그70), 집행에 관한 이의신청을 각하하는 결정(대결 2005. 8. 29. 2005마 258) 등과 같이 민사집행법 17조 1항에 해당하지 아니하는 결정에 대하여는 즉시항고를 제기할 수 없으므로 위와 같은 결정은 즉시 효력이 발생하지만, 위와 같은 결정에 특별항고사유가 있으면 특별항고를 제기하여 불복할 수 있다.

2. 제3자이의의 소

가. 의의

보전처분집행에 관한 제3자이의의 소는 이미 집행이 개시된 보전처분의 목적물에 대하여 소유권이나 양도 또는 인도를 저지하는 권리를 가진 제3자가 그 권리를 침해하여 현실적으로 진행되고 있는 보전처분의 집행에 대하여 이의를 주장하고 집행의 배제를 구하는 소이다.

나. 이의 원인

270

(1) 집행채권자에게 대항할 수 있는 권리

제3자이의의 소의 원인이 되는 권리는 집행채권자에게 대항할 수 있는 것이어야 하고(대판 2013. 3. 14. 2012다107068), 그 대항 여부는 그 권리의 취득과 집행의 선후에 의하여 결정되는 것이 보통이므로 그 권리가 집행 당시에 이미 존재하여야 하는 것이 일반적이지만, 집행 후에 취득한 권리라고 하더라도 특별히 권리자가 이로써 집행채권자에게 대항할 수 있는 경우라면 그 권리자는 그 집행의 배제를 구하기 위하여 제3자이의 소를 제기할 수 있다(대판 1997. 8. 29. 96다14470). 또한 제3자이의의 소의 이의 원인은 소유권에 한정되는 것이 아니고 집행목적물의 양도나 인도를 막을 수 있는 권리이면 족하며, 집행목적물이 집행채무자의 소유에 속하지 아니한 경우에는 집행채무자와 사이의 계약관계에 의거하여 집행채무자에 대하여 목적물의 반환을 구할 채권적 청구권을 가지고 있는 제3자는 집행에 의한 양도나 인도를 막을 이익이 있으므로 그 채권적 청구권도 제3자이의의 소의 이의 원인이 될 수 있다(대판 2003. 6. 13. 2002다16576).

(2) 무효인 보전처분

피고의 가압류신청이 사망자를 상대로 한 것이라면 사망자 명의의 그 가압류명령은 무효이고, 무효의 가압류명령에 기한 가압류집행에 대해서는 그 집행 이후 소유권을 취득한 원고도 그 집행채권자인 피고에 대하여 그 소유권 취득을 주장하여 대항할 수 있으므로, 원고는 제3자이의의 소에 의하여 위 집행의 배제를 구할 수 있다(대판 1982. 10. 26. 82다카884). 가압류집행이 형식적으로는 채권확보를 위한 강제집행절차에 따른 것이라고 하여도 법이 보호할 수 없는 반사회적인 행위에 의하여 이루어진 것이어서 무효인 경우, 그 가압류 이후의 소유권 취득자가 강제집행절차에서 그 무효를 주장하고 제3자이의의 소에 의하여 그 집행의 배제를 구할 수 있다(대판 1996. 6. 14. 96다14494, 대판 1997. 8. 29. 96다14470).

271

(3) 부정되는 경우

점유이전금지가처분의 대상이 된 목적물의 소유자가 그 의사에 기하여 가처분채무자에게 직접점유를 하게 한 경우에는 그 점유에 관한 현상을 고정시키는 것만으로 소유권이 침해되거나 침해될 우려는 없고 소유자의 간접점유권이 침해되는 것도 아니므로, 간접점유자에 불과한 소유자는 직접점유자를 가처분채무자로 하는 점유이전금지가처분의 집행

에 대하여 제3자이의의 소를 제기할 수 없다(대판 2002. 3. 29. 2000다33010). 또한 부동산을 명의신탁한 경우에는 소유권이 대외적으로 수탁자에게 귀속하므로 명의신탁자인 종중은 신탁을 이유로 제3자에 대하여 그 소유권을 주장할 수 없고, 특별한 사정이 없는 한 신탁자가 수탁자에 대해 가지는 명의신탁해지를 원인으로 한 소유권이전등기청구권은 집행채권자에게 대항할 수 있는 권리가 될 수 없으므로, 명의신탁자는 명의신탁된 부동산에 관하여 제3자이의의 소의 원인이 되는 권리를 가지고 있지 않다(대판 2007. 5. 10. 2007다7409).

다. 제한

제3자이의의 소는 집행목적물에 대한 구체적인 집행행위의 배제를 구하는 소로서 집행이 종료된 이후에는 그 소를 제기할 이익이 없다. 보전처분의 집행이 종료되는 시점은 집행이 취소되거나 본집행으로 이전되는 시점이 된다.

3. 집행항고

가. 즉시항고

보전처분신청을 기각하거나 각하하는 등의 보전소송에 관한 재판은 집행절차에 관한
272 집행법원의 재판이라고 할 수 없어 그 재판에 대한 즉시항고에 관하여는 민사집행법 15조가 아닌 민사소송법의 즉시항고에 관한 규정이 준용되지만, 보전처분의 집행에 대한 즉시항고에는 민사집행법 15조가 준용되므로 항고이유를 명확하게 하여야 한다. 항고심은 명확하게 된 항고이유에 한하여 조사하는 것이 원칙이고, 항고장에 항고이유를 적지 아니한 때에는 항고장을 제출한 날로부터 10일 이내에 항고이유서를 원심법원에 제출하여야 하며, 항고이유서를 정하여진 기간 안에 제출하지 아니하거나 항고이유서를 제출하긴 하였으나 그 기재가 대법원규칙이 정하고 있는 바에 위반된 때에는 즉시항고를 각하하여야 하며(민집 15조 3항, 4항, 5항, 7항), 원심법원이 즉시항고를 각하하여야 함에도 불구하고 이를 각하하지 아니하고 사건을 송부한 경우에는 항고법원은 곧바로 즉시항고를 각하하여야 한다(대결 2011. 4. 26. 2010마1982).

(1) 집행신청각하결정에 대한 즉시항고

채권자가 보전집행을 신청하였으나, 법원이 집행기간의 경과를 이유로 위 신청을 각하

한 경우에는 채권자는 각하결정에 대하여 즉시항고를 할 수 있다(민집 291조, 15조, 83조 5항). 이와 달리 집행관이 집행기관인 경우에는 집행에 관한 이의를 하여야 한다(민집 291조, 16조).

(2) 집행취소결정에 대한 즉시항고

채권자가 집행비용을 미리 내지 아니한 것을 이유로 법원이 직권으로 집행을 취소한 경우 채권자는 집행취소결정에 대하여 즉시항고할 수 있다(민집 18조 3항). 이와 달리 채권자는 채무자의 동의 없이 보전집행취소신청을 할 수 있고 집행취소결정은 채무자에게 아무런 불이익도 주지 아니하므로, 채무자는 집행취소결정에 대하여 즉시항고할 수 없다(대결 1980. 2. 15. 79마351).

(3) 간접강제결정에 대한 즉시항고

간접강제결정에 대한 즉시항고도 민사집행법상의 즉시항고이므로 그에 관한 항고법원의 결정에 대한 재항고절차에는 민사집행법상의 즉시항고와 재항고에 관한 규정이 적용된다(대결 2011. 4. 26. 2010마1982).

나. 특별항고

273

불복할 수 없는 결정이나 명령에 대하여는 재판에 영향을 미친 헌법위반이 있거나, 재판의 전제가 된 명령·규칙·처분의 헌법 또는 법률의 위반여부에 대한 판단이 부당하다는 것을 이유로 하는 때에만 대법원에 특별항고를 할 수 있다(민집 23조 1항, 민소 449조 1항). 신청인의 가처분집행취소신청에 대하여 법원이 민사집행법 301조, 291조, 민사소송법 500조, 501조를 준용하여 담보를 제공케 하고 피신청인이 실시한 가처분집행을 취소한 경우, 가처분집행취소결정에 대하여는 민사소송법 500조 3항의 규정에 의하여 불복을 신청할 수 없도록 되어 있어서 같은 법 449조 소정의 특별항고만이 허용되므로, 불복신청자가 특별항고라는 표시를 하지 않았고 대법원에 대한 것임을 표시하지 않았다 하여도 원심법원은 이를 특별항고로 하여 기록을 대법원에 송부함이 마땅하다(대결 1968. 11. 8. 68마1303). 또한 해방공탁에 의한 가압류집행취소신청을 기각한 결정에 대하여는 항고제기의 방법으로 불복을 신청할 수는 없고, 민사소송법 449조 소정의 특별항고가 허용될 뿐이다. 그러나 대법원의 결정에 대하여는 특별항고를 할 수 없다(대결 1987. 9. 15. 87그30).

제8장 각종의 가압류와 그 집행

제1절 부동산에 대한 가압류

1. 총설

부동산의 강제집행방법에 강제경매와 강제관리의 두 가지가 있는 것과 같이 그 보전수단인 부동산가압류도 부동산소유권에 대한 가압류와 가압류를 위한 강제관리의 두 가지 방법이 있다.

2. 부동산소유권에 대한 가압류

가. 신청과 심리

(1) 부동산가압류(‘부동산소유권에 대한 가압류’를 ‘부동산가압류’로 줄여 사용하는 것이 일반적이다. 이하에서도 ‘부동산가압류’를 같은 의미로 사용한다)를 신청할 때에는 송달료와 등기축탁에 필요한 등록면허세, 지방교육세를 내야 한다. 부동산등기사항증명서도 같이 낸다.

(2) 과거 부동산가압류는 부당 가압류의 경우에도 채무자가 입을 피해가 다른 가압류에 비하여 적을 것이라고 생각하여 쉽게 가압류명령을 하는 사례도 있었다.

그러나 부동산가압류도 집행취소까지 상당한 시일과 노력이 소요되고, 채무자가 제때에 부동산을 처분하지 못하여 큰 손해를 입을 수 있으므로 피보전권리와 보전의 필요성에 대한 심사를 소홀히 해서는 아니 된다. 민사집행법은 청구채권이나 가압류의 이유를 소명하지 못하는 경우에도 법원이 정한 담보를 제공한 때에는 법원은 가압류를 명할 수 있다고 하나(민집 280조 2항), 이는 예외적인 경우에 관한 것이고 채권자가 가압류의 요건을 소명하지 않

거나 소명하지 못하는 경우에는 가압류신청을 기각하는 것이 원칙이다(민집 276조, 277조).

나. 부동산가압류의 목적물

(1) 가압류 목적물의 특정

가압류명령 시에는 가압류할 부동산을 특정하여야 한다. 지분이 가압류의 목적물인 경우는 “서울 ○○구 ○○동 291 대 57㎡ 중 23㎡”라고 표시하여서는 아니 되고, “서울 ○○구 ○○동 291 대 57㎡에 대한 공유자 ○○○ 지분 57분의 23 전부”와 같이 정확히 지분을 표시하여야 한다.

(2) 부동산의 합유지분

민법 714조는 “조합원의 지분에 대한 압류는 그 조합원의 장래의 이익배당 및 지분의 반환을 받을 권리에 대하여 효력이 있다.”고 규정하여 조합원의 지분에 대한 가압류, 압류를 허용하고 있으나, 여기에서 조합원의 지분이란 전체로서의 조합재산에 대한 조합원 지분을 의미하고, 조합재산을 구성하는 특정 부동산의 합유지분은 가압류나 압류의 목적물이 될 수 없으므로 그러한 가압류신청은 각하해야 할 것이다(대결 2007. 11. 30. 2005마1130).

(3) 미등기 부동산

민사집행법 81조 1항 2호 단서, 3항은 미등기 건물의 강제경매신청서에는 그 건물이 채무자의 소유임을 증명할 서류, 그 건물의 지번·구조·면적을 증명할 서류 및 그 건물에 관한 건축허가 또는 건축신고를 증명할 서류를 붙이거나 그 조사를 집행법원에 신청할 수 있다고 규정하고, 민사집행규칙 42조 2항은 민사집행법 81조 1항 2호 단서의 규정에 따라 채권자가 제출한 서류에 의하여 강제경매신청을 한 건물의 지번·구조·면적이 건축허가 또는 건축신고된 것과 동일하다고 인정되지 아니하는 때에는 법원은 강제경매신청을 276 각하하여야 한다고 규정하고 있다.

민사집행규칙 218조는 보전처분의 집행에 관하여는 특별한 규정이 없으면 강제집행에 관한 규정을 준용하도록 규정하고 있으므로, 채권자가 미등기 건물에 대해 가압류신청을 하려면 ① 건물이 채무자의 소유임을 증명할 서류(실무에서는 통상 건축허가서나 건축신고서를 제출받고 있고, 미흡할 경우 건축도급계약서 등을 추가로 받고 있다), ② 건물의 지번과 구조와 면적을 증명할 서류, ③ 건물에 관한 건축허가(신고)를 증명할 서류가 필요하다. 또한 민사집행법 81조 2항, 3항은 채권자는 공적 장부를 주관하는 공공기관에 위

서류들에 관한 사항을 증명하여 줄 것을 청구할 수 있고(사실조회신청), 집행법원에 건물
의 지번·구조·면적의 조사를 신청할 수 있다고(현황조사명령신청) 규정하고 있다.

건물로서의 실질과 외관을 갖추고 지번·구조·면적 등이 건축허가 또는 건축신고의 내용
과 사회통념상 동일하다고 인정될 수 있는 정도에 이르지 못한 미등기 건물은 가압류의
대상이 될 수 없어 가압류신청은 각하되게 된다(대결 2009. 5. 19. 2009마406).

미등기 부동산에 관하여 가압류명령을 하면 법원은 등기관에게 미등기 부동산에 대한
가압류등기를 촉탁한다. 등기관은 법원의 촉탁에 따라 미등기 부동산에 대하여 직권으로
소유권보존등기를 한 후 가압류등기를 한다.

자세한 것은 [II] 제3장 제1절 강제경매 참조.

(4) 신탁법상 신탁재산

신탁재산에 대하여는 가압류 등 보전처분을 할 수 없다(신탁 22조 1항 본문). 다만 신탁
전의 원인으로 발생한 권리 또는 신탁사무의 처리상 발생한 권리를 근거로 한 경우에는
예외적으로 가압류가 허용된다(같은 항 단서). ‘신탁 전의 원인으로 발생한 권리’란 신탁
전에 위탁자에 관하여 생긴 모든 채권을 의미하는 것이 아니고, 신탁재산 그 자체를 목적
으로 하여 생긴 채권(신탁 전에 이미 신탁부동산에 저당권이 설정된 경우 등)만을 의미하
는데(대판 1987. 5. 12. 86다545, 대판 1996. 10. 15. 96다17424), 이러한 채권이 가압
277 류의 청구채권이 되는 경우는 사실상 생각하기 어렵다. ‘신탁사무의 처리상 발생한 권리’
란 신탁 후에 신탁재산의 관리, 처분으로 인하여 수탁자에 대하여 발생한 권리를 말하는
데, 신탁재산에 대한 조세채권이나 신탁재산에 속하는 공작물의 하자로 말미암은 손해배
상채권 등 신탁재산 자체에서 연유하는 권리뿐 아니라 수탁자의 통상적인 사업활동상의
행위로 인하여 손해를 입은 제3자가 가지는 위자료청구권 등의 손해배상채권도 포함된다
(대판 2007. 6. 1. 2005다5843). 신탁법의 규정을 위반한 가압류라도 당연히무효인 것은
아니나, 위탁자, 수익자 또는 수탁자는 제3자이의의 소를 제기하여 그 집행을 배제할 수
있고(신탁 22조 2항), 채무자는 가압류이의를 할 수 있다(대판 1987. 5. 12. 86다545,
86다카2876, 대판 2007. 6. 1. 2005다5843).

다. 집행절차

(1) 부동산가압류는 가압류명령에 관한 사항을 등기부에 기재하는 방법으로 집행한다(민
집 293조 1항). 부동산가압류의 집행법원은 가압류명령을 한 법원이 되나(같은 조 2항),

가압류등기는 법원사무관등이 촉탁한다(같은 조 3항). 부동산가압류에서는 가압류신청 시에 집행신청도 함께 한 것으로 보아 따로 집행신청을 하지 않더라도 집행에 착수한다.

(2) 상속등기를 하지 아니한 부동산에 관하여 가압류명령이 있을 때에는 채권자는 등기 촉탁 이전에 먼저 대위에 의한 상속등기를 함으로써 등기의무자의 표시가 등기부와 일치하도록 하여야 한다. 이때 대위원인증서로 가압류명령의 정보 또는 등본을 첨부하고, 대위원인은 “○년 ○월 ○일 ○○지방법원의 가압류 결정”이라고 기재한다(등기예규 1432호).

(3) 부동산가압류의 촉탁서 양식은 다음과 같다.

[전산양식 A4780] 부동산가압류등기촉탁서

278

○ ○ 지 방 법 원				
등기촉탁서				
				○ ○ 등기관 귀하
사 건	20 카	부동산가압류		
부동산의 표시	별지와 같음			
등기관리자				
등기의무자				
등기원인과 그 연월일	20 . . .	.자 부동산가압류명령		
등기목적	부동산가압류 등기의 기입등기			
과세표준	금 ○○원			
등록면허세	금 ○○원(시·도명, 등록세 납세번호)			
지방교육세	금 ○○원			
등기신청수수료	금 ○○원			
첨 부	결정正本 1부			
위의 등기를 촉탁합니다.				
2000. ○. ○.				
법원사무관			[직인]	

접수	. . .	처리인	등기관 확인	각종 통지
	제 호			

등록면허세액은 청구금액의 1,000분의 2이며[지방세 28조 1항 1호 라목 1)], 그 세액의 100분의 20이 지방교육세액이 된다(지방세 151조 1항 2호).

그 외 등기촉탁에 관한 자세한 점은 [II] 제3장 제1절 5. 나. 경매개시결정등기의 촉탁 참조.

279 라. 재판과 그 집행의 효력

(1) 주문례

통상적인 주문례는 다음과 같다.

1. 채무자 소유의 별지 기재 부동산을 가압류한다.
2. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

(2) 처분금지의 효력

(가) 상대적 효력

가압류명령은 가압류 목적물에 대한 채무자의 처분행위를 금지하는 것이므로, 만약 채무자가 이에 위반하여 처분행위를 하였을 때 그 효력을 어떻게 볼 것인가가 문제 된다. 이에 관하여 가압류에 위반하는 채무자의 처분행위는 절대적으로 무효이고 따라서 가압류가 취소 또는 취하되더라도 무효인 처분행위가 다시 유효로 되는 것은 아니라는 견해(절대적 효력설)도 가능하다. 그러나 가압류의 목적은 장차 가압류 목적물을 현금화하여 그로부터 금전적 만족을 얻는 데 있으므로, 그러한 목적 달성에 필요한 범위를 넘어서까지 채무자의 처분행위를 막는 것은 채무자의 이익 내지 일반 거래상의 안전을 지나치게 해치는 결과가 된다는 이유에서 가압류가 집행되었더라도 채무자는 가압류 목적물을 매매하거나 기타의 처분행위를 할 수 있고, 다만 가압류채권자에 대한 관계에서만 처분행위의 유효를 주장할 수 없을 뿐이라는 견해(상대적 효력설)가 통설과 판례(대판 2002. 9. 6. 2000다71715)의 입장이다. 따라서 채무자의 처분행위로 부동산을 취득한 사람이 이에 따른 등기를 신청하면 등기관은 부동산가압류가 집행되어 있다는 이유로 이를 거부할 수 없고, 취득자가 그 등기를 마치면 가압류채권자 이외의 자에 대해서는 그 취득의 효과를 주장할 수 있다.

그리고 채무자와 제3취득자 사이의 거래행위가 있는 후에 가압류가 취소, 해제되거나, 제3취득자의 대위변제 등으로 피보전권리가 소멸하거나(대판 1982. 9. 14. 81다527, 대
280 결 1982. 9. 30. 82그19), 가압류명령 또는 가압류집행이 무효인 것으로 판명된 경우(대판 1982. 10. 26. 82다카884, 대판 1997. 8. 29. 96다14470)에는 채무자와 제3취득자 사이의 거래행위는 유효한 것으로 된다.

토지에 대하여 가압류가 집행되어 있어도 토지의 수용으로 사업시행자가 그 소유권을 원시취득하면 가압류의 효력은 소멸되고, 그 가압류가 수용보상금 청구권에 당연히 이전되는 것은 아니다(대판 2000. 7. 4. 98다62961).

(나) 상대적 효력의 인적 범위

상대적 효력설에 의하면 가압류채권자가 본안소송에서 승소판결을 받고 강제경매신청을 하여 집행절차가 개시되면 (집행절차가 실효되지 않는 한) 채무자가 한 가압류에 위반한 처분행위는 무효로 된다. 이러한 효과가 그 집행절차에 참여한 채무자의 다른 채권자들에 대해서도 마찬가지로 인가가 문제된다. 이에 관하여는 집행절차에 참가한 채무자의 모든 채권자들에 대해 처분행위는 무효가 되고 이들 간에 평등배당이 이루어진다는 입장(절차상대효설)과 채무자의 처분행위가 있기 전에 가압류나 압류를 하거나 담보권을 설정하는 등 집행행위를 한 채권자들에 대해서만 처분행위는 무효가 되고 그들 중 담보권자 등 선순위 채권자는 후순위 채권자에 대하여 우선한다는 입장(개별상대효설)이 있는데, 개별상대효설이 통설, 판례이다.

개별상대효설에 의하면 가압류에 관하여 다음과 같은 결과가 발생하게 된다.

첫째, 채무자가 가압류집행이 된 부동산을 제3자에게 양도하였다면, 제3자의 소유권 취득은 그 가압류의 집행보전의 목적을 달성하는 데 필요한 범위 안에서 가압류채권자에 대한 관계에서만 상대적으로 무효일 뿐이므로, 채무자(구 소유자)의 다른 채권자는 제3자 소유인 그 부동산을 압류할 수 없고 그에 관한 배당요구도 할 수 없다(대판 1998. 11. 13. 97다57337).

둘째, 가압류 후 부동산이 제3자에게 양도된 경우에 그 가압류에 의한 집행절차에서 채권자들이 모두 만족한 후에도 잉여금이 있다면 양수인인 제3자에게 지급해야 한다(대판 1992. 2. 11. 91누5228). 만약 부동산을 양수한 제3자의 채권자가 부동산에 대해 경매신청을 하였다면 제3자의 채권자는 부동산의 매각대금 중 가압류의 처분금지 효력이 미치는 범위의 금액을 제외한 나머지 금액에 대해서만 배당받을 수 있다(대판 2006. 7. 28. 2006다19986). 281

셋째, 가압류 후에 저당권을 취득한 사람은 가압류채권자와 동순위로 배당을 받는다(대판 2008. 2. 28. 2007다77446). 저당권자보다 후순위인 일반채권자도 배당요구를 하였을 경우에는 일단 안분배당을 한 후 저당권자가 자기의 채권액을 만족시킬 때까지 후순위인 일반채권자의 배당을 흡수하여 배당을 받는다(대결 1994. 11. 29. 94마417).

(다) 상대적 효력의 물적 범위

통설, 판례인 개별상대효설에 의하면 가압류의 처분금지 효력은 채무자의 가압류에 위반한 처분행위가 있기 전에 집행된 가압류의 피보전권리의 범위 내에서만 미치게 된다. 즉 가압류의 처분금지 효력은 목적물의 교환가치 중 피보전권리액에 대응하는 목적물의 교환가치 부분에만 미치므로(가압류에 위반한 처분행위는 가압류의 피보전권리액 부분에

한하여 무효가 되므로), 제3취득자는 완전한 소유권을 취득하기 위하여 그 처분행위가 있기 전까지 집행이 완료된 가압류의 피보전권리액만 변제하면 되며, 그 후에 가압류채권자가 채무자에 대하여 취득한 채권이 있더라도 이를 변제할 필요는 없다.

판례도 피보전권리로 원금채권만 기재하여 부동산가압류가 집행되었고 그 후 부동산의 소유권이 제3자에게 이전되었으며 그리고 나서 가압류채권자가 집행권원을 얻어 가압류채무자를 집행채무자로 하여 가압류를 본압류로 이전하는 강제집행을 실시하였다면 부동산의 매각대금에서 가압류명령에 청구금액으로 기재된 금액의 범위에서만 배당을 받을 수 있고 그 금액을 넘어서는 이자 또는 지연손해금 채권과 소송비용채권을 배당받을 수는 없다고 한다(대판 1998. 11. 10. 98다43441).

다만 집행권원에서 인정된 원금채권액이 가압류명령의 청구금액에 미치지 못하면 청구금액의 범위 내에서 원금채권과 청구기초의 동일성이 인정되는 채권인 이자 또는 지연손해금채권도 배당받을 수 있다는 것이 판례이다(대판 2013. 6. 13. 2011다75478). 가압류의 집행비용과 본집행의 비용 중 가압류의 본압류로의 이전에 대응하는 부분은 민사집행
282 법 53조 1항에 따라 우선적으로 변상받을 수 있다(대판 2006. 11. 24. 2006다35223).

(3) 사용, 관리, 수익에 관한 효력

가압류의 집행은 채무자의 목적물에 대한 처분의 금지에만 그치지 않고 그 목적달성을 위한 범위 내에서 가압류 대상의 사용·관리·수익까지 제한하는 효력이 있는 것이 원칙이다. 그런데 부동산가압류집행 후 채무자에게 부동산의 관리, 이용을 허용해도 부동산의 처분금지라는 가압류의 목적달성에 장애가 되는 것은 아니므로, 민사집행법은 부동산이 가압류된 경우에도 채무자가 부동산을 관리, 이용할 수 있도록 하고 있다(민집 291조, 83조 2항). 따라서 채무자가 부동산을 관리, 이용하여 부동산으로부터 수익을 취하는 것을 금지하려면 별도로 가압류를 위한 강제관리신청을 해야 한다(민집 294조).

(4) 다른 절차와의 경합

(가) 부동산가압류 간의 경합

같은 부동산에 대한 가압류집행의 경합이 허용되고, 가압류채권자 상호 간의 우열도 없다. 가압류집행이 경합된 경우 그중 하나가 본압류로 이전된 때에는 다른 가압류채권자는 배당받을 채권자의 지위를 갖는다(민집 148조 3호).

(나) 부동산처분금지가처분과의 경합

부동산가압류와 부동산처분금지가처분은 그 내용이 서로 모순, 저촉되지 않는 경우라면

(가처분의 피보전권리가 제한물권의 설정청구권인 경우 등) 경합이 가능하다.

하지만 그 내용이 모순, 저촉되는 경우(가처분의 피보전권리가 소유권이전등기청구권 또는 말소등기청구권인 경우 등) 효력의 우열은 집행의 선후에 의하여 결정된다(가처분집행이 선행한 경우는 대판 2005. 1. 14. 2003다33004 참조).

(다) 압류(강제집행)와의 경합

같은 부동산에 대한 가압류집행과 압류집행의 경합도 가능하다. 가압류집행이 선행하면 가압류채권자는 배당요구의 필요 없이 당연히 배당받을 채권자의 지위를 갖게 되고(민집 148조 3호), 압류집행이 선행하면(경매개시결정 기입등기 후에 가압류를 하였다면) 가압류 채권자는 배당요구를 할 수 있다(민집 88조 1항).

283

(라) 체납처분과의 경합

체납처분은 재판상의 가압류 또는 가처분으로 인하여 그 집행에 영향을 받지 아니하며(국세징수법 35조), 국세 또는 체납처분비는 다른 공과금 기타 채권에 우선하여 징수한다(국세기 35조 1항 본문). 따라서 가압류집행이 선행되었다 하더라도 국세체납처분은 아무런 장애 없이 집행할 수 있다.

이처럼 현행법상 국세 체납절차와 보전처분절차는 별개의 절차로서 양 절차 간의 관계를 조정하는 별도의 법률이 마련되어 있지 않으므로 한쪽의 절차가 다른 쪽의 절차에 간섭할 수 없는 반면, 쌍방 절차에서 각 채권자는 서로 다른 절차에서 정한 방법으로 그 다른 절차에 참여할 수밖에 없다(대판 2002. 12. 24. 2000다26036). 따라서 설령 가압류채권자가 먼저 부동산에 가압류집행을 마쳤어도 같은 부동산에 대한 국세 체납절차가 진행되어 청산절차가 종결되면 그 가압류는 효력을 상실하게 된다. 반면 체납처분에 따른 압류가 먼저 이루어졌더라도 이후 집행된 가압류가 본압류로 이전되어 강제경매절차가 종결되면 체납처분에 따른 압류는 효력을 상실하게 된다(경매개시결정 기입등기 전에 체납처분에 따른 압류를 마친 경우이므로, 배당요구로서 교부청구를 하지 않아도 배당을 받게 될 것이다).

다만 국세징수법이 2011. 4. 4. 법률 제10527호로 개정됨에 따라 세무서장은 체납처분에 의한 압류재산의 매각대금 등을 배분할 때 체납액 등과 우선변제권 있는 채권뿐만 아니라 가압류 청구채권(공매공고의 등기 또는 등록 전까지 가압류의 등기나 등록을 한 것 또는 그 후에 가압류한 경우에는 배분요구의 종기까지 배분요구를 한 것)에 대하여도 배분하여야 하고, 배분하고 남은 금액이 있을 때에 체납자에게 지급하여야 하며(같은 법 68조의2 1항, 81조 1항, 3항, 80조 1항), 가압류 청구채권액이 확정되지 아니한 경우에는 가압류채권자에게 배분할 금액을 한국은행에 예탁하여야 한다(같은 법 84조 1항). 위와 같은 국세징수법의 개정이

있기 전부터 판례는 국세채납처분에 의한 매각대금의 배분대상에 같은 법 81조 1항 3호에
 284 규정된 담보권보다 선순위 또는 동순위에 있는 가압류 청구채권이 포함된다고 판시해왔는바
 (대판 2002. 3. 26. 2000두7971), 위 개정으로 배분대상인 가압류의 범위가 확대되었다.

3. 부동산 수익의 가압류를 위한 강제관리

가. 개요

강제관리는 부동산, 즉 토지 또는 건물의 수익(차임 등)으로 채권자의 금전채권을 만족
 하게 하려는 집행방법이다(민집 78조 2항 2호, 163조 이하). 다만 강제집행을 위한 강제
 관리가 부동산 수익에서 그 부동산이 부담하는 조세, 그 밖의 공과금을 뺀 뒤에 관리비용
 을 변제하고, 그 나머지 금액을 채권자에게 변제하는 것(민집 169조 1항)과 달리, 부동산
 수익의 가압류를 위한 강제관리(이하 '가압류를 위한 강제관리')에서는 가압류의 성질상
 채권자에 대한 변제(배당)의 단계까지 갈 수 없으므로, 이를 가압류 청구채권액에 이를
 때까지 공탁하게 된다(같은 법 294조).

가압류를 위한 강제관리는 부동산가압류에 비하여 절차가 다소 복잡하여 실무상 많이
 이용되고 있지 아니하나 경우에 따라서는 적절한 보전처분이 될 수 있다. 예를 들어, 목적
 물이 대규모의 집합건물인 경우에는 이를 경매하여 돈으로 바꾸는 것은 매우 어려운 일이
 지만 채무자가 차임 등을 임차인으로부터 지급받고 있는 때에는 그 수익으로 채권자가
 만족을 얻을 수 있기 때문이다.

가압류를 위한 강제관리의 신청은 이미 가압류한 부동산에 대하여 할 수도 있다(민집
 291조, 78조 3, 4항).

그 외 가압류를 위한 강제관리의 신청에 첨부할 서류, 기입등기의 촉탁, 관리인의 선임
 과 그 보수결정, 관리인의 권한과 강제관리의 집행, 그 취소절차 등은 모두 본서의 강제집
 행으로서의 강제관리에 준하여 생각하면 된다([Ⅷ] 제3장 제3절 강제관리 참조).

285 나. 보전의 필요성

가압류를 위한 강제관리는 부동산의 수익에 관하여 채무자의 처분권을 제한하는 것으
 로, 배당절차가 없다는 것 이외에는 본집행과 거의 유사하다. 따라서 강제관리가 개시되면
 채무자의 불이익이 클 수밖에 없으므로, 가압류를 위한 강제관리사건에서 보전의 필요성
 은 엄격히 판단되어야 할 것이다.

다. 수익의 공탁

관리인은 부동산의 수익에서 그 부동산이 부담하는 조세, 그 밖의 공과금을 뺀 뒤에 관리비용을 변제하고 나머지를 공탁하여야 한다(민집 291조, 169조 1항, 294조). 공탁서는 법원에 제출하며 법원은 이를 민사보관물관리에 관한 예규(재민 79-7)에 규정된 보관요령에 따라 보관한다. 그와 같이 공탁한 총액이 가압류 청구채권액에 이르면 법원은 직권으로 강제관리취소결정을 하고, 그 결정이 확정된 경우 법원사무관등은 가압류등기의 말소를 촉탁한다(민집 291조, 171조). 가압류의 효력은 이 공탁금 회수청구권에 미치게 된다.

[전산양식 A4743] 가압류를 위한 부동산강제관리결정

286

○ ○ 법 원			
결 정			
사 건	20 카기	가압류를 위한 부동산강제관리	
채 권 자			
채 무 자			
제 3 자			
주 문			
1. 채무자 소유의 별지 기재 부동산에 대한 강제관리절차를 개시하고 채권자를 위하여 이를 가압류한다.			
2. 채무자는 관리인의 사무에 간섭하거나 또는 위 부동산의 수익을 처분하여서는 아니 된다.			
3. 제3자는 위 부동산의 수익을 관리인에게 지급하여야 한다.			
4. 아래 사람을 이 사건 관리인으로 임명한다.			
○○지방법원 집행관 ○ ○ ○			
5. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 가압류집행의 정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.			
청구채권의 내용			
청구금액			
금	○○원	20 . . .	자 대여금
금	○○원	20 . . .	부터 20 . . . 까지
연 ○%의 비율에 의한 이자			
합계 금	○○원		
이 유			
이 사건 가압류신청은 이유 있으므로 담보로 금 ○○원을 공탁하게 하고			
주문과 같이 결정한다.			
2000. ○. ○.			
판 사 ㉠			

- 주 1. 수익을 지급할 제3자가 없는 때 또는 그 존재가 판명되지 아니한 때에는 제3자의 이름과 주소 및 제3자는 위 수익을 관리인에게 지급하여야 한다는 문구를 기재하지 않는다.
2. 관리인을 개시결정과 동시에 임명하지 아니하는 때에는 관리인의 임명에 관한 문구를 기재하지 않는다.

제2절 선박·항공기·자동차·건설기계에 대한 가압류

1. 선박에 대한 가압류

가. 개요

(1) 원래 선박은 민법상으로는 동산이지만, 일정 규모 이상의 선박은 부동산과 마찬가지로 등기의 대상이 되고(선박 8조, 선박등기법 2조), 일반의 유체동산에 비하여 비교적 가액이 고가일 뿐만 아니라 그에 관하여 다수 이해관계인이 생겨 법률관계가 복잡하게 되는 등 부동산과 유사한 면이 많으므로 민사집행법은 선박에 대한 가압류의 집행에 관하여 기본적으로 부동산집행, 그중에서도 강제경매에 관한 규정을 준용하도록 하고 있다(민집 291조, 172조).

(2) 선박 중에서도 등기할 수 있는 선박만이 선박가압류의 대상이 된다. 선박 중 총톤수 20톤 이상의 기선과 범선 및 총톤수 100톤 이상의 부선(다만 선박계류용·저장용 등으로 사용하기 위하여 수상에 고정하여 설치하는 부선은 제외되나, 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 8조에 따른 점용 또는 사용 허가나 하천법 33조에 따른 점용허가를 받은 수상호텔, 수상식당 또는 수상공연장 등 부유식 수상구조물형 부선은 포함)에 대하여 등기를 할 수 있다(선박 26조, 선박등기법 2조). 한편 자동차 등 특정동산 저당법의 적용을 받는 소형 선박에 대한 가압류에는 자동차에 대한 가압류 규정이 준용된다(민집규 211조). 등기할 수 있는 선박이 아니고 위 소형선박에도 해당되지 않는 선박은 유체동산가압류절차에 의한다.

가압류의 대상이 되는 선박의 개념과 그 가압류 제한 등의 사항에 관하여는 강제집행의 경우와 같으므로 선박에 대한 강제집행 부분(Ⅲ 제4장 제1절 선박에 대한 집행)을 참조.

288 (3) 항해준비를 완료한 선박에 대한 가압류의 제한에 대한 예외로서 ‘항해를 준비하기 위하여 생긴 채권’으로는 가압류를 할 수 있는데(상 744조) 이러한 종류의 채권은 선박우선특권을 갖게 되는 경우가 많다(상 777조). 그런데 선박우선특권이 있는 채권은 선박소유권의 이전에 관계없이 집행권원 없이도 선박에 대한 경매청구권을 행사하여 우선변제를 받게 되므로(상 777조 2항, 785조) 그 채권을 보전하기 위한 가압류는 보전의 필요성이 인정되지 않는다(대판 1988. 11. 22. 87다카1671 등).

나. 신청

(1) 관할

선박에 대한 가압류는 가압류할 선박이 있는 곳을 관할하는 지방법원 또는 본안의 관할법원이 담당한다(민집 278조). 가압류할 선박이 있는 곳이란 현재 입항하여 정박 중인 곳을 말한다.

(2) 신청서

선박에 대한 가압류신청서에는 선박의 표시, 선박의 정박항 및 선장의 이름과 현재지를 기재하여야 하는데(민집규 218조, 95조, 민집 80조), 별지에 기재함이 통례이다.

선박의 표시는 선박을 특정할 수 있도록 선박의 종류와 명칭, 선적항, 선질, 총톤수, 기관의 종류와 그 수, 추진기의 종류와 그 수, 진수연월일 등을 기재한다(선박등기규칙 10조 참조). 이미 등기된 선박에 대하여는 선박등기사항증명서에 기재되어 있는 사항을 그대로 적으면 된다.

선장의 이름과 현재지를 기재하도록 하는 이유는 선장이 선적항 외에서 항해에 필요한 모든 재판상 및 재판 외의 행위를 채무자(선주)를 대리하여 할 수 있기 때문이다(상 749조). 선장의 현재지는 '○○함내 승선 중'이라고 표시할 수 있고, 만일 선장의 이름과 현재지가 분명하지 않다면 '선장의 이름 및 현재지: 불명'이라고 기재하여도 무방하다.

(3) 신청서에 첨부할 서류

289

(가) 선박등기사항증명서

(나) 항해의 준비를 완료하지 않았다는 보고서: 상법 744조에 의하여 항해의 준비를 완료한 선박과 그 속구는 가압류하지 못하므로 그에 해당되지 않는다는 소명을 위한 서류인데, 보고서 작성자가 법정되어 있지는 않다.

(다) 정박증명서: 가압류할 선박이 있는 곳을 담당하는 지방법원을 관할법원으로 삼아 선박가압류를 신청하는 경우 관할을 정하기 위하여 필요한데, 증명서 작성자가 법정되어 있지는 않다.

(라) 선가증명서: 담보액을 정함에 필요할 수 있다.

다. 심리, 재판과 집행

(1) 심리 및 재판

선박가압류의 집행은 가압류등기를 하거나 선박국적증서 등을 선장으로부터 받아 법원

에 제출하는 방법으로 한다. 이들 방법은 함께 사용할 수 있다(민집 295조).

또한 민사집행법은 아래에서 살펴보는 바와 같이 가압류집행에 부수하여 선박에 대한 감수·보존의 필요가 있는 경우에는 선박에 대한 강제집행의 조문을 준용하여 감수·보존처분을 할 수 있도록 하고 있다(민집 295조, 291조, 178조).

(2) 주문례

가압류등기를 하는 방법으로 선박가압류를 집행하는 경우에는 다음과 같다.

1. 채무자 소유의 별지 기재 선박을 가압류한다.
2. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

선박국적증서 등을 제출하는 방법으로 선박가압류를 집행하는 경우에는 다음과 같다.

290

1. 채무자 소유의 별지 기재 선박을 가압류한다.
2. 집행관은 위 선박의 선박국적증서 및 그 밖에 선박운행에 필요한 문서를 선장으로부터 받아 이 법원에 제출하라.
3. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

(3) 집행절차와 효력

가압류등기를 하는 방법에 의한 가압류집행은 가압류명령을 한 법원이, 선박국적증서 등을 받아 제출하도록 명하는 방법에 의한 가압류집행은 선박이 정박하여 있는 곳을 관할하는 지방법원이 집행법원으로서 관할한다(민집 295조 2항).

가압류등기를 하는 방법으로 선박가압류를 집행하는 때에는 법원사무관등은 그 기입등의 촉탁을 하여야 한다(민집 295조 3항, 293조 3항). 등기촉탁서의 양식은 부동산가압류 등기촉탁서에 준하고 과세표준은 1건이라고 기재하며 등록면허세액은 1건당 15,000원, 지방교육세액은 그 100분의 20이다(지방세 28조 1항 2호 다목, 151조 1항 2호).

선박국적증서 등을 제출하는 방법으로 가압류를 집행하는 경우에는 집행법원은 집행관에게 선박국적증서, 그 밖에 선박운행에 필요한 문서를 선장으로부터 받아 법원에 제출할 것을 명하여야 한다(민집 295조 1항). 외국선박에 대하여는 등기의 방법으로는 집행할 수 없으므로 선박국적증서를 받아 제출하는 방법으로 집행해야 할 것이다(민집 291조, 186조, 174조).

가압류의 효력은 원칙적으로 채무자에게 가압류명령이 송달된 때 또는 가압류등기가 된 때에 생기나(민집 291조, 172조, 83조 4항, 94조), 그 외에 집행관이 선박국적증서

등을 받은 때(민집 291조, 174조 2항) 또는 감수·보존처분을 하였을 때에도(민집 291조, 178조 2항) 가압류의 효력이 생긴다. 위 각 시기 중 가장 빠른 때에 가압류의 효력이 발생 하는 것이다.

선박가압류의 집행에 관한 그 밖의 사항에 관하여는 선박에 관한 강제집행의 규정이 준용되나(민집 291조), 선박집행신청 전의 선박국적증서 등의 인도명령(민집 175조), 압류선박의 정박(민집 176조), 관할위반으로 말미암은 절차의 취소(민집 180조), 보증의 제 291 공에 의한 강제경매절차의 취소(민집 181조), 사건의 이송(민집 182조), 선박국적증서 등을 넘겨받지 못한 경우의 경매절차취소(민집 183조) 등의 규정은 성격상 준용하기 곤란하거나 당사자 일방에 지나치게 유리하므로 그 준용이 배제된다고 보아야 할 것이다.

(4) 감수·보존

민사집행법이 선박가압류의 집행방법에서 구법과는 달리 정박명령을 배제하였지만, 특별한 사정이 있어 선박에 대하여 감수·보존의 필요가 있는 경우(감수·보존이 이루어지지 않으면 가압류집행의 실효성이 상실되는 경우 등이 이에 해당할 것이다), 집행법원은 채권자의 신청에 따라 선박을 감수하고 보존하기 위하여 필요한 처분을 할 수 있다(민집 291조, 178조 1항). 이 처분은 필요에 따라 가압류명령 전에도 할 수 있다(민집규 218조, 102조).

이 신청은 독립한 신청사건으로 접수하여 가압류사건기록에 합철한다(재민 91-1). 채권자는 집행비용으로 법원이 정하는 금액을 미리 내야 한다.

감수·보존의 방법에는 제한이 없으나 실무상 주로 사용되는 것은 집행관으로 하여금 선박을 보관하게 하는 것이다(민집규 103조 참조). 감수인 또는 보존인으로 정하여진 집행관 등은 그 감수 또는 보존에 필요한 조치를 할 수 있다(민집규 103조 2항, 3항). 감수처분과 보존처분은 중복하여 할 수 있다(민집규 103조 4항).

외국선박에 대한 가압류명령을 받은 가압류채권자는 가압류집행을 마쳐야 배당요구를 할 수 있으므로, 가압류 대상인 선박에 대하여 이미 경매신청채권자 등에 의하여 선행 감수·보존처분이 되어 있다고 하더라도 별도로 가압류집행을 하여야 하고, 그러한 집행을 하지 아니한 채 선행 감수·보존처분을 원용하거나 가압류명령만으로 적법한 배당요구가 있었다고 할 수 없다(대판 2011. 9. 8. 2009다49896).

그 밖에 상세한 내용은 선박에 대한 강제집행 부분(Ⅲ 제4장 제1절 7. 나. 감수(監守)·보존처분)을 참조.

292 라. 선박의 지분에 대한 가압류

(1) 선박의 지분이 가압류의 대상이 될 때에는 선박을 가압류하는 방법에 따르지 아니하고 그 밖의 재산을 가압류하는 방법에 의한다(민집 291조, 185조 1항).

(2) 선박의 지분에 대하여 가압류신청을 하기 위해서는 채무자가 선박의 지분을 소유하고 있다는 사실을 증명할 수 있는 선박등기사항증명서나 그 밖의 증명서를 내야하며(민집 185조 2항), 본안의 관할법원 외에 선박등기를 하는 곳을 관할하는 지방법원도 가압류할 물건이 있는 곳을 관할하는 법원으로서 관할권을 가진다(민집규 213조 1항).

(3) 선박의 지분에 대한 가압류의 집행은 발령법원의 법원사무관등이 그 가압류기입등의 촉탁을 함으로써 한다(그 문례는 선박가압류의 경우와 같다). 가압류명령 정본은 채무자 외에 선박관리자(상 764조)가 있으면 그에게도 송달하여야 하며, 선박관리자에게 송달하면 채무자에게 송달한 것과 같은 효력을 가진다(민집 185조 3항, 4항).

(4) 그 밖에 상세한 내용은 선박에 대한 강제집행 부분(Ⅲ) 제4장 제1절 11. 선박지분에 대한 집행)을 참조.

2. 항공기에 대한 가압류

가. 원칙

(1) 항공기에 대한 강제집행절차는 부동산, 동산, 선박에 관한 강제집행규정에 준하여 대법원규칙으로 정하도록 하였는데(민집 187조), 항공기에 대한 등록이 물권변동의 효력요건인 점에서(항공 9조 1항, 121조 1항) 선박등기가 대항요건인 점과 다르나, 항공기도 그 성질상 이동성을 가지고 그 운항 및 보관에 전문적 지식과 기술을 필요로 하는 등 선박과 유사한 점이 많은 것을 고려하여, 민사집행규칙은 본집행과 마찬가지로 항공기에 대한 가압류집행도 선박에 대한 가압류집행의 예에 따라 실시하도록 하였다(민집규 209조).

293 (2) 항공기에 대한 가압류는 가압류할 항공기가 있는 곳을 관할하는 지방법원 또는 본안의 관할법원이 관할한다(민집 278조).

(3) 가압류의 대상이 되는 항공기의 개념과 선박과 항공기의 용어의 차이에 관하여는 항공기에 대한 강제집행 부분(Ⅲ) 제4장 제2절 항공기에 대한 집행)을 참조.

(4) 항공기가압류도 선박가압류와 마찬가지로 가압류등기를 하는 방법이나 집행관이 항공기등록증명서(항공 12조, 121조 1항) 등을 수취하여 집행법원에 제출하는 방법으로 집

행이 이루어지게 된다. 특별한 사정이 있어 항공기에 대하여 감수·보존의 필요가 있는 경우에는 집행법원은 채권자의 신청에 따라 항공기를 감수하고 보존하기 위하여 필요한 처분을 할 수 있다(민집규 209조, 106조, 103조).

나. 선박집행과의 차이점

(1) 신청

신청서에는 국토교통부장관이 발급한 항공기등록원부 등본을 첨부하여야 하고 목적물의 특정을 위하여 위 등록원부에 기재된 등록기호, 종류, 형식, 제작자, 항공기의 제작번호, 정치장, 등록연월일 등을 명시하여야 한다.

항공기의 경우에는 선박과 달리 신청서에 기장의 이름과 현재지를 기재하지 않아도 된다.

(2) 등록의 촉탁

항공기에 대한 가압류의 집행은 부동산의 경우와 같이 등록사무 소관청인 국토교통부장관에게 그 가압류의 기입등록을 촉탁함으로써 행한다. 다만 항공기가 항공안전법 10조에 해당하는 외국항공기일 경우에는 국내에 외국항공기의 등록원부가 있을 수 없으므로 외국 선박의 경우(민집 186조)와 같이 등록촉탁의 필요가 없다.

등록촉탁서의 양식은 부동산가압류 등기촉탁서에 준하고 과세표준은 1건이라고 기재한다. 등록면허세액은 1건당 12,000원, 지방교육세액은 그 100분의 20이다(지방세 28조 1항 14호, 151조 1항 2호). 294

3. 자동차·건설기계에 대한 가압류

가. 개요

(1) 자동차·건설기계에 대한 강제집행절차는 부동산, 선박, 동산에 관한 강제집행규정에 준하여 대법원규칙으로 정한다(민집 187조).

(2) 자동차는 민법상으로는 동산으로 취급되지만, 그 권리변동에 있어서는 부동산과 유사하게 등록이 그 효력발생요건으로 되어 있고 또 그 가액도 일반적으로 고가이어서 이들을 강제집행에 있어 보통의 동산과 같이 취급하는 것은 부적절하다. 이에 따라 자동차관리법에 의하여 등록된 자동차에 대한 가압류의 집행은 원칙적으로 부동산에 대한 가압류집행의 예(강제관리의 방법은 제외)에 의하도록 하였다(민집규 210조 1항).

(3) 건설기계관리법에 의하여 등록된 건설기계에 대한 가압류의 집행에 대하여는 자동차에 대한 가압류집행의 규정들을 준용한다(민집규 211조).

(4) 그 밖에 가압류의 대상이 되는 자동차·건설기계의 개념, 자동차인도명령 등에 관하여는 자동차·건설기계에 대한 강제집행 부분(Ⅲ 제4장 제3절 자동차에 대한 집행, 제4절 건설기계에 대한 집행)을 참조.

나. 신청과 관할

(1) 신청

신청서에는 자동차·건설기계의 각 등록원부 등본을 붙여야 하고 목적물의 특정을 위하여 위 등록원부에 기재된 다음 사항을 명시하여야 한다.

295 (가) 자동차의 표시사항

등록번호, 제원관리번호, 차명, 차종, 차대번호, 원동기의 형식 및 연식, 사용본거지, 등록연월일 등.

(나) 건설기계의 표시사항

등록번호, 건설기계명, 형식, 규격, 차대일련번호, 제작국, 연식, 사용본거지, 등록연월일 등.

(2) 관할

자동차·건설기계가 있는 곳을 관할하는 지방법원이나 본안법원이 관할한다(민집 278조). 가압류신청 당시 자동차·건설기계가 있는 곳이 불확실할 때에는 등록원부에 기재된 사용본거지를 가압류할 자동차·건설기계가 있는 곳으로 해석할 수 있을 것이다(민집규 109조 1항, 130조 참조).

다. 가압류명령

통상적인 주문례는 다음과 같다.

1. 채무자 소유의 별지 기재 자동차(건설기계)를 가압류한다.
2. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

가압류법원은 채권자의 신청에 따라 자동차·건설기계를 집행관에게 인도할 것을 채무자에게 명할 수 있다(민집규 210조 2항, 211조). 민사집행규칙 111조 3항(가압류명령의

송달 또는 등록 전에 인도명령이 집행되면 그때에 가압류의 효력이 발생함), 112조(가압류 자동차의 인도), 114조(자동차를 인도받은 때의 신고), 115조(자동차의 보관방법), 117조(운행의 허가), 118조 1항(자동차의 이동)은 인도명령에 따라 집행관이 자동차·건설기계를 인도받은 경우에 준용한다(민집규 210조 3항, 211조).

그러나 신청 전의 인도명령에 관한 민사집행규칙 113조의 규정은 가압류집행에는 준용되지 않는다.

라. 집행

296

(1) 등록의 촉탁과 그 효력

가압류의 집행은 부동산의 경우와 같이 목적물의 등록사무 소관청에 그 가압류의 기입 등록을 촉탁함으로써 행한다.

등록촉탁서의 양식은 부동산가압류 등기촉탁서에 준하고 과세표준은 1건이라고 기재한다. 등록면허세액은 자동차의 경우 1건당 15,000원이고(지방세 28조 1항 3호 라목), 건설기계의 경우는 1건당 10,000원이며(지방세 28조 1항 4호 라목), 지방교육세액은 그 100분의 20이다(지방세 151조 1항 2호). 다만 자동차, 건설기계 중 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭은 지방교육세 비과세 대상이다(지방세 150조 2호, 124조, 지방세령 120조).

(2) 운행 등의 허가

인도 집행된 자동차·건설기계에 대하여는 영업상의 필요 그 밖의 상당한 이유가 있는 때에는 이해관계를 가진 자의 신청에 따라 집행법원이 운행을 허가할 수 있다(민집규 210조 3항, 117조, 211조). 이 신청은 독립한 신청사건으로 접수하지 아니하며 문서전명부에 등재하고 가압류사건기록에 가철한다(재민 91-1). 법원은 위 운행허가를 함에 있어서 운행의 기간, 장소, 방법 등에 관하여 적당한 조건을 붙일 수 있다(민집규 117조 2항). 위 운행허가결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(같은 조 3항). 자세한 것은 자동차에 대한 강제집행 부분(Ⅲ 제4장 제3절 7. 나. 운행허가)을 참조.

(3) 목적물의 현금화

가압류한 자동차·건설기계는 가압류의 성질상 현금화를 하지 못한다. 다만 자동차·건설기계를 즉시 매각하지 아니하면 값이 크게 떨어질 염려가 있거나 그 보관에 지나치게 큰 비용이 드는 경우에는 집행관은 자동차·건설기계를 매각하여 매각대금을 공탁하여야 한다(민집규

210조 3항, 211조, 민집 296조 5항 단서). 이 규정은 그 형식으로만 보면 집행관이 자동차·건설기계를 동산집행의 절차에 의하여 매각할 수 있는 것처럼 보이기도 하지만 자동차·건설기계는 부동산에 대한 집행의 예에 준하여 그 집행기관이 법원으로 정하여져 있으므로 위와 같은 매각 여부도 집행법원이 결정하여 부동산집행의 절차에 따라 매각하여야 할 것이다.

마. 공유지분에 대한 가압류

자동차·건설기계의 공유지분에 대한 가압류는 그 밖의 재산을 가압류하는 방법에 의한다(민집규 210조 4항, 129조, 민집 251조, 민집규 211조). 따라서 그 집행은 가압류명령을 채무자에게 송달하는 외에 가압류기입의 등록을 촉탁함으로써 할 것이다(민집규 175조 5항).

제3절 유체동산에 대한 가압류

1. 피보전권리와 보전의 필요성에 대한 심사

유체동산가압류는 집행관이 채무자 소유의 유체동산에 가압류표시를 하는 방법으로 집행하므로 다른 가압류에 비하여 채무자에 대한 심리적 압박감이 크다. 더구나 채무자의 영업용 집기나 생산시설인 기계 기구 등에 가압류집행이 되면 영업상의 손해는 물론 채무자의 신용이 악화되어 가압류만으로 채무자가 도산하게 되는 경우도 있다.

채권자 중에는 이러한 유체동산가압류의 실질적 위력을 이용할 목적으로 유체동산가압류신청을 하는 경우도 있으므로 유체동산가압류의 경우에는 피보전권리와 보전의 필요성에 대한 심사를 보다 신중하고 엄격히 할 필요가 있다. 따라서 일반적인 보전의 필요성 이외에 집행할 만한 채무자 소유의 부동산, 채권 등 다른 재산이 없을 뿐만 아니라, 채무자에게 부도가 발생하는 등으로 강제집행 전에 재산처분의 가능성이 크고, 다른 재산을 조사할 만한 시간이 없어 즉시 집행의 필요가 있다는 소명 등이 필요할 것이다.

유체동산가압류신청 시 가압류할 유체동산의 종류나 수량, 유체동산이 있는 장소 등을 특정할 수 있음은 물론이나, 채권자가 채무자 소유의 유체동산이 어떤 것인지를 알 수 없는 경우도 있으므로 가압류할 유체동산을 특정하지 않고 채무자의 유체동산 전체를 그 대상으로 하여 가압류를 신청하는 것도 허용하고 있는 것이 실무의 입장이다.

그러나 유체동산의 소재지가 채무자의 주거지인지, 매장인지, 공장인지 등에 따라 채무자가 입을 수 있는 피해 정도에 큰 차이가 발생할 수 있고, 가압류의 필요성 여부의 판단도 달라질 수 있으므로 유체동산의 소재지만이라도 밝히도록 함이 바람직하다.

2. 공탁과 가압류명령

가. 공탁

일반적으로 청구금액의 5분의 4를 담보로 공탁하도록 명하는 것이 보통이나, 가압류할 유체동산이 특정된 경우에는 적절하게 줄일 수 있을 것이다. 피보전권리와 보전의 필요성이 충분히 소명되고, 다른 재산도 없음이 소명된 경우에는 공탁금 전부를 보증보험증권으로 허용할 수도 있지만, 대부분의 실무례는 공탁금 중 절반 이상을 현금으로 공탁하도록 하고 있다.

나. 가압류명령

통상적인 주문례는 다음과 같다.

1. 채무자 소유의 (별지 기재) 유체동산을 가압류한다.
2. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

3. 집행절차

299

가. 개요

(1) 유체동산에 대한 가압류집행은 압류와 같은 원칙에 따라야 한다(민집 296조 1항). 유체동산가압류는 집행관에게 집행을 위임하여 집행관이 유체동산 압류의 방식에 의하여 집행한다. 그 집행위임은 채권자·채무자와 그 대리인의 표시, 가압류명령의 표시, 가압류 목적물인 유체동산이 있는 장소, 가압류 청구채권 중 일부에 관하여만 집행을 구하는 때에는 그 범위를 적은 서면에 가압류명령 정본을 붙여서 하여야 한다(민집규 212조 1항). 가압류명령에 유체동산이 특정되어 있지 않은 경우에는 집행단계에서 집행관의 점유로 구체적 집행의 대상이 되는 유체동산이 정해진다.

압류의 대상과 그 제한 및 압류의 방식에 대하여는 동산에 대한 강제집행 부분(IV) 제5

장 제1절 유체동산에 대한 강제집행)을 참조.

(2) 집행관이 유체동산을 가압류하였을 때에는 다음의 양식에 의한 조서를 작성한다[집행관사무소에 비치할 각종 문서의 양식에 관한 예규(행정예규 1200호) 부록 제2호 문서양식 2-35].

[양식] 유체동산가압류조서

○○지방법원 유체동산가압류조서	
사 건 :	20 가
채권자 :	
채무자 :	
집행권원 :	
청구금액 :	원금 원, 이자 원
집행일시 :	20 :
집행장소 :	
1. 위 집행권원에 의한 채권자의 위임에 의하여 집행장소에서 채무자를 만나 집행권원을 제시하고 가압류할 뜻을 고지한 후 를 참여시키고 별지목록 기재 물건을 가압류하였다. 2. 가압류물건은 집행관이 점유하고 봉인()의 방법으로 가압류물임을 명백히 한 후, 채권자의 승낙을 얻어 채무자에게 보관시켰다. 3. 보관자에게는 가압류물건의 점유는 집행관에게 옮겨졌으므로 누구든지 이를 처분하지 못하며 이를 처분 또는 은닉하거나 가압류표시를 훼손하는 경우에는 벌을 받을 것임을 고지하였다. 4. 이 절차는 같은 날 : 에 종료하였다. 이 조서를 현장에서 작성하여 집행참여자에게 읽어준(보여준) 즉 승인하고, 다음에 서명날인 하였다. 2000. 0. 0. 집행관 (인) 채권자 (인) 채무자 (인) 참여자 성명 (인) 주민등록번호 주소 참여자 성명 (인) 주민등록번호 주소	

- 주 1. 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그 사항을 조서에 기재한다.
- ① 집행에 착수한 후 정지한 때에는 그 사유
 - ② 집행에 저항을 받은 때에는 그 취지와 이에 대하여 한 조치
 - ③ 집행의 목적을 달성할 수 없었던 때에는 그 사유
 - ④ 집행을 속행한 때에는 그 사유
 - ⑤ 채무자가 자기 소유가 아니라는 진술을 한 압류물에 관하여는 그 취지
 - ⑥ 압류물을 보관시키면서 특별한 보관조건을 정한 때에는 그 보관조건
2. 채권자나 채무자가 아닌 제3자에게 압류물을 보관시킨 경우에는 조서 말미에 보관자의 주소·성명을 기재한 후 서명날인을 받아야 한다.

(3) 민사집행법 189조 1항은 유체동산압류의 집행에 관하여 집행관 보관을 원칙으로 하고, 다만 채권자의 승낙이 있거나 운반이 곤란한 때에는 봉인, 그 밖의 방법으로 압류물임을 명확히 하여 채무자에게 보관시킬 수 있다고 한다. 따라서 유체동산의 가압류도 집행관 보관에 의하여 집행됨이 원칙이나, 실무상 채무자 보관의 방식으로 집행이 이루어지는 경우가 많다. 유체동산가압류집행이 본압류와 다른 것은 현금화할 수 없다는 것이다(아래다.의 현금화의 경우는 예외). 따라서 배당절차도 없다.

나. 금전 및 어음·수표 등의 가압류와 공탁

301

집행관이 금전을 가압류하였을 때에는 이를 공탁하여야 한다(민집 296조 4항). 또한 집행관은 가압류집행이 된 어음, 수표 등에 관하여 채무자에 갈음하여 지급을 위한 제시 등 그 권리의 행사를 위하여 필요한 행위를 하여야 하는데(민집 212조 1항), 이때 금전을 받게 된 경우에는 민사집행법 296조 4항을 유추하여 그것도 공탁하여야 할 것이다.

그 공탁에 관하여는 별도의 서식이 없으므로, 공탁규칙 3조 2항, 공탁사무 문서양식에 관한 예규(행정예규 제1153호) 별표 제1-1호 양식에 의하여 공탁자를 집행관으로, 공탁원인을 가압류집행으로 각 기재하여 공탁할 것이다. 공탁서는 집행관이 보관하며 그 공탁물 회수청구권에 관하여 가압류의 효력이 미치는 것으로 본다. 집행관은 가압류가 본압류로 이전되면 공탁금을 가압류채권자에게 인도하고(민집 201조 1항), 가압류취소 등이 있으면 공탁금을 회수하여 가압류채무자에게 반환한다.

다. 가압류한 유체동산의 현금화와 공탁

(1) 가압류한 유체동산은 원칙적으로 현금화할 수 없다. 다만 가압류한 유체동산을 즉시 매각하지 아니하면 값이 크게 떨어질 염려가 있거나(생선, 채소와 같이 부패할 염려가 있는 경우 등) 그 보관에 지나치게 큰 비용이 드는 경우(동물의 사육료, 창고료가 많이 드는 경우 등)에는 집행관이 현금화할 수 있다(민집 296조 5항). 법원의 명령은 필요 없다. 이는 집행관의 의무이기도 하지만 당사자도 긴급히 현금화를 할 사정을 안 때에는 이를 집행관에게 알려야 한다.

가압류한 유체동산에 관하여 제3자의의 소가 제기되고 가압류의 집행정지결정이 내려진 경우라도 본 조항의 현금화는 동산을 금전으로 바꾸는 일종의 보존행위이고 가압류의 상태를 변경하는 것이 아니므로 이러한 사정이 현금화를 함에 방해가 되는 것은 아니다.

(2) 집행관은 가압류한 유체동산을 매각한 때에는 그 매각대금을 공탁하여야 한다(민집 302

296조 5항 단서). 매각대금은 가압류한 유체동산의 변형으로 볼 것이다. 공탁하게 한 취지, 공탁의 성질, 공탁금에 대한 본집행의 방법은 가압류한 금전을 공탁한 경우와 같다.

가압류의 매각대금이 공탁된 후 가압류채권자가 본안소송에서 승소의 확정판결을 받아 집행관에게 집행의 신청을 하여도 곧바로 위 공탁금에 관하여 변제를 받은 것과 같은 효력이 생기는 것은 아니고 집행관은 공탁금의 회수를 받아 배당절차를 행한다. 가압류의 현금화 후 집행의 취하, 취소 등이 있을 때는 집행관이 매각대금을 회수한 다음 가압류채무자에게 직접 반환하게 된다.

라. 가압류집행의 효력

(1) 가압류명령의 집행은 가압류의 목적물에 대하여 채무자가 매매, 증여, 질권 등의 담보권설정, 그 밖에 일체의 처분을 금지하는 효력을 생기게 한다. 만일 채무자가 처분금지를 어기고 일정한 처분행위를 하였을 경우 그 처분행위는 절대적으로 무효가 되는 것이 아니고, 가압류채권자와 처분행위 전에 집행에 참가한 자에 대한 관계에서만 상대적으로 무효가 될 뿐이다(개별상대효설). 구체적인 내용은 제1절 2. 라. 재판과 그 집행의 효력 참조.

유체동산이 가압류된 후 채무자가 처분행위를 하였을 경우에도 제3자의 선의취득은 가능하다(대판 1966. 11. 22. 66다1545, 1546). 그러나 가압류를 집행한 동산은 집행관이 점유한다는 취지의 표시를 하므로 취득자의 선의, 무과실을 인정하기 어려운 경우가 많을 것이다.

(2) 가압류의 집행은 채무자에 대하여 처분금지의 제한에 그치지 않고 그 목적달성을 위한 범위 내에서 가압류 대상의 사용·관리·수익까지 제한하는 효력이 있다. 유체동산의 가압류는 집행관이 목적물을 점유하므로 원칙적으로 채무자의 사용이 금지되나, 집행관이 채무자에게 보관시킨 경우에는 통상의 용법에 따라 사용할 수 있다.

(3) 가압류한 유체동산을 제3자가 점유하게 된 경우에는 가압류채권자가 제3자의 점유를 안 날부터 1주 이내에 법원에 가압류한 유체동산의 인도명령을 신청하면 이 명령을 근거로 하여 집행관이 가압류한 유체동산을 회수할 수 있다(민집 291조, 193조). 자세한 내용은 [IV] 제5장 제1절 3. 마. (3) 압류물의 회수와 인도명령 참조.

마. 다른 절차와의 경합

가압류된 유체동산에 대하여 인도청구의 강제집행을 하는 것과 같이 비금전집행이 가능한가에 관하여는 소극설과 적극설이 대립하고 있는데, 가압류된 동산은 집행관의 점유하

에 있는 것이 보통이므로 소극설이 타당하다.

그 밖에 자세한 것은 제8장 제1절 2. 라. (4) 다른 절차와의 경합 참조.

제4절 금전채권에 대한 가압류

제3편
제8장
제4절

1. 총설

가. 가압류할 채권(피가압류채권)의 특징

채권가압류명령의 신청에는 가압류할 채권의 종류와 액수를 밝혀야 하고(민집 291조, 225조), 특히 가압류할 채권의 일부에 대하여만 가압류명령을 신청할 때에는 그 범위를 밝혀야 한다(민집규 218조, 159조 1항 3호).

채권가압류신청에서 가압류할 채권을 특정하도록 하는 이유는 법원이 가압류할 채권의 가압류 적격을 심사할 수 있도록 해주고, 채무자와 제3채무자가 어떠한 채권에, 어느 범위에서 가압류의 효력이 미치는지를 인식할 수 있도록 해주기 위함이다.

통상 가압류할 채권의 채권자(가압류채무자), 채무자(제3채무자), 채권의 종류, 발생원인, 금액, 변제기 등을 명백히 표시하여 다른 채권과 구별되도록 한다.

장래 발생할 채권이나 조건부 채권도 현재 그 권리의 특징이 가능하고 가까운 장래에 304
발생할 것이 상당 정도 기대되는 경우에는 이를 가압류할 수 있다(대결 2001. 9. 18. 2000마5252, 대판 2009. 6. 11. 2008다7109).

가압류할 채권의 표시와 관련하여 적법한 가압류신청인지가 문제 되는 경우가 있다.

가압류할 채권의 특징을 엄격하게 요구하지 않으면 가압류명령 하나만으로 채무자의 제3채무자에 대한 모든 채권의 추심이 금지되는 사태가 발생할 수 있게 되므로 채무자에게 지나치게 가혹한 결과가 된다. 또한 채권가압류에 있어서 제3채무자는 순전히 타의에 의하여 다른 사람들 사이의 법률분쟁에 편입되어 가압류명령에서 정한 의무를 부담하는 것이므로 이러한 제3채무자를 가압류된 채권이나 그 범위를 파악함에 있어서 과도한 부담을 가지지 아니하도록 보호할 필요가 있다. 따라서 ‘가압류할 채권의 표시’에 기재된 문언은 그 문언 자체의 내용에 따라 객관적으로 엄격하게 해석하여야 하고, 문언의 의미가 불명확한 경우 그로 인한 불이익은 가압류채권자에게 부담시키는 것이 타당하다. 결국 통상의 주의력을 가진 사회평균인을 기준으로 그 문언을 이해할 때 포함 여부에 의문을 가질

수 있는 채권은 특별한 사정이 없는 한 가압류의 대상에 포함되었다고 보아서는 안 될 것이다(대판 2013. 6. 13. 2013다10628).

하지만 채권자의 입장에서 보면 가압류할 채권은 타인 간의 거래관계에서 발생한 것이고, 공시방법도 없는 점을 고려하면 채권의 발생 일자나 액수 등을 정확히 표시한다는 것도 결코 쉬운 일은 아닐 것이다.

따라서 채권자와 채무자의 이익을 조화롭게 고려하여 적어도 가압류할 채권의 종류와 액수는 밝히도록 하는 등으로 다른 채권과는 구별될 수 있는 정도로 특정하여 줄 것을 요구하여야 한다.

채권자가 가압류를 신청하면서 가압류할 채권의 대상과 범위를 특정하지 않음으로 인해 가압류명령에서 가압류할 채권이 특정되지 않은 경우에는 그 가압류명령에 의해서는 가압류의 효력이 발생하지 않는다.

먼저 채무자가 제3채무자에 대하여 여러 개의 채권을 가지고 있는 경우에는 채권자가
305 그 채권들 중 어느 채권에 대해 어느 범위에서 가압류를 신청하는지를 특정하여야 한다. 이를 특정하지 아니한 경우에는 그 가압류명령은 원칙적으로 무효이고, 그 채권들의 실제 합계액이 피보전권리액보다 오히려 적다거나 복수의 채권이 모두 하나의 계약에 기하여 발생하였거나 제3채무자가 채무자에게 그 채무를 일괄 이행하기로 약정하였다는 등의 특별한 사정이 있는 경우라야만 예외적으로 유효하다(대판 2013. 12. 26. 2013다26296).

다음으로 채무자가 수인이거나 제3채무자가 수인인 경우에는 채권자는 각 채무자나 제3채무자별로 어느 범위에서 지급이나 처분의 금지를 명하는 것인지를 가압류할 채권의 표시 자체로 명확하게 인식할 수 있도록 특정하여야 한다. 이를 특정하지 아니한 경우에는 집행의 범위가 명확하지 아니하여 그 가압류명령은 원칙적으로 무효이다. 왜냐하면 각 채무자나 제3채무자가 자신의 채권 혹은 채무 중 어느 금액 범위 내에서 가압류의 대상이 되는지를 명확히 구분할 수 없고, 그 결과 각 채무자나 제3채무자가 가압류의 대상이 아닌 부분에 대하여 권리를 행사하거나 가압류된 부분만을 구분하여 공탁을 하는 등으로 부담을 면하는 것이 불가능해지기 때문이다(설령 가압류의 대상인 수인의 채무자들의 채권 합계액이나 수인의 제3채무자들에 대한 채권 합계액이 피보전권리액을 초과하지 않더라도 그 가압류명령을 유효하다고 볼 수 없는데, 개별 채무자 및 제3채무자로서는 자신을 제외한 다른 모든 채무자들의 채권액이나 모든 제3채무자들의 채무액을 구체적으로 알고 있는 특별한 경우가 아닌 이상 자신에 대한 가압류집행의 범위를 알 수 없음은 마찬가지이기

때문이다. 대판 2014. 5. 16. 2013다52547).

실무에 나타나는 채권의 구체적 표시례는 [IV] 제5장 제2절 제1관 3. 가. (2) (마) 2) 구체적 표시례 참조. 가압류할 수 있는 금전채권의 범위와 그 제한에 관하여는 [IV] 제5장 제2절 제1관 2. 나. 피압류채권의 적격 참조.

나. 요건의 심리

사회가 현대화되면서 채권의 종류와 성격이 다양해지고 있어 자연히 채권의 종류에 따른 가압류 적격의 심리 필요성뿐 아니라, 채권의 성격에 따른 피보전권리와 보전의 필요성에 대한 심리의 필요성도 생기게 되었다. 306

일반적으로는 부동산가압류의 경우와 마찬가지로 심리하면 될 것이나, 계속적 거래관계로 인한 채권이나 금융기관계좌의 예금채권이 가압류되면 채무자의 신용에 악영향을 미쳐 거래관계가 중단되고, 자금의 흐름을 차단하여 도산의 원인이 되기도 하며, 근로자의 임금채권은 근로자의 생계수단이 되는 점을 고려하여 이러한 채권에 대한 가압류에서는 유체동산가압류에서와 마찬가지로 피보전권리와 보전의 필요성에 대한 심리를 보다 엄격하게 할 필요가 있다.

채권자가 국내의 다수 금융기관들을 망라하는 식으로 채무자와 관련 없는 금융기관들까지 제3채무자로 하여 다수의 예금채권에 대하여 가압류신청을 하는 예가 있는데, 그러한 가압류신청의 필요성이 충분히 소명되지 않는 경우에는 채무자와 관련 있는 금융기관들로만 제3채무자를 제한하도록 보정명령을 하거나 보전의 필요성에 대한 소명 부족을 이유로 신청을 기각하는 것이 실무의 경향이다.

다. 공탁

통상 담보액은 청구금액의 5분의 2로 정하나, 계속적 거래관계로 인한 채권, 예금채권, 임금채권 등의 경우에는 채무자에게 심각한 영향을 미칠 수 있음을 고려하여 가압류요건을 신중히 심리함과 아울러 공탁금액의 절반 이상을 현금공탁시키는 실무례가 많다.

라. 제3채무자에 대한 진술최고

제3채무자에게 채권을 인정하는지의 여부 등에 관하여 진술을 명하는 것에 관한 규정(민집 237조)은 가압류에도 그대로 준용되므로(민집 291조) 채권자는 그 명령을 신청할

수 있는바 집행기간과 관련하여 채권가압류의 경우에는 가압류신청과 동시에 또는 집행법원의 집행(송달) 시까지 신청을 할 수 있다.

채권자는 제3채무자 진술최고신청서를 종이기록, 전자기록을 구분하지 아니하고 전자
307 문서로 작성하여야 한다(재일 2012-1 21조). 그런데 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 2조에 따른 금융회사인 제3채무자에 대하여 진술최고를 신청하는 경우에는 같은 법 4조의2 1항 및 4항에 따라 그 제공사실을 채무자에게 통보하여야 하므로, 채권자는 해당 통보비용을 법원보관금으로 납부하여야 하고, 가압류명령 시까지 통보비용을 납부하지 않은 경우에는 제3채무자에 대한 진술최고신청을 각하한다.

제3채무자는 당사자가 아닌 집행의 대상에 불과하므로, 제3채무자가 사전포괄동의자나 전자소송의무자인 경우에도 제3채무자에 대한 진술최고신청서의 송달은 전자적 송달을 하면 안 되고 기존과 같이 우편송달 등을 하여야 한다.

제3채무자는 종이기록, 전자기록 모두 진술서를 전자소송 홈페이지에서 제출가능하므로, 이를 위해서 제3채무자에게 진술최고서와 함께 전자소송 안내서를 송달하여야 하고(재일 2012-1 60조 3호 바목), 제3채무자가 자연인인 경우에는 진술서를 등기우편으로 제출할 수 있으므로 계좌이체신청서도 동봉하여야 한다. 제3채무자가 진술서를 등기우편에 의하여 본인 비용으로 송부하면서 계좌이체신청서에 은행명칭, 계좌번호, 예금주를 기입하여 제출하면, 해당 계좌로 우편비용을 입금하여 처리하면 된다. 한편 제3채무자가 금융기관인 경우 진술최고 및 제출명령 양식[전산양식 A1847]을 사용하여야 한다(재일 2005-1 2조 5호, 3조 1항).

2. 지명채권에 대한 가압류

가. 가압류명령

(1) 지명채권을 가압류할 때에는 주문에 가압류의 목적인 채권을 가압류한다는 뜻을 선언함과 동시에 제3채무자에 대하여 채무자에게 지급하여서는 아니 된다는 명령만을 한다(민집 296조 3항). 채무자에 대하여 채권의 처분과 영수를 금지하는 명령(민집 227조 1항)을 하지 않는 점이 본압류와 다르나, 채권을 확보한다는 목적에서 보면 효력에 차이가 없다.

308 제3채무자는 보전처분의 당사자는 아니지만, 그 가압류로 직접 영향을 받게 되므로 가압류명령에 표시한다.

(2) 공무원 또는 회사 직원의 임금 또는 퇴직금채권에 대한 가압류명령을 신청하는 때에

는 채무자의 이름과 주소 외에 소속 부서, 직위, 주민등록번호 등 채무자를 특정할 수 있는 사항을 기재하도록 한다(재민 94-3). 제3채무자가 국가나 법인인 때에는 그 소관부처나 소관지점을 명시하여 업무처리의 신속을 기한다. 사립학교 교직원이 아닌 초·중등학교 교육공무원의 급여를 받을 권리 등을 가압류하고자 하는 경우 제3채무자는 특별시·광역시 및 도가 되며 그 대표자는 도지사가 아닌 교육감이 된다.

(3) 주문례

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재 채권을 가압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 채권에 관한 지급을 하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

나. 집행과 그 효력

(1) 채권가압류는 제3채무자에게 채무자에 대한 지급을 금지하는 명령이 기재된 가압류 명령 정본을 송달함으로써 집행한다. 집행법원은 가압류명령을 한 법원이 되며(민집 296조 2항), 법원은 따로 집행신청을 기다리지 않고 가압류명령과 동시에 제3채무자에게 정본을 송달한다.

가압류명령이 제3채무자에게 송달불능된 경우에는 채권자로부터 주소보정을 받아 재송달한다. 이때 채권자가 가압류의 집행기간인 2주를 지나서 주소를 보정하더라도 주소보정 명령에서 정한 기간 내의 주소보정이면 집행기간의 경과 여부를 불문하고 종전 집행의 속행으로 보아 재송달하고, 보정기간 안에 주소를 보정하지 않거나 재송달도 불능으로 된 경우에는 종결 처리하고 있다(채권압류와 달리 공시송달신청은 받아들이지 않는 것이 실무의 입장이다).

(2) 채권가압류의 효력은 제3채무자에게 정본이 송달됨으로써 발생한다(민집 291조, 227조 3항). 채권가압류명령의 경정결정이 확정된 경우에는 처음부터 경정된 가압류명령이 있었던 것과 같은 효력이 있으므로 당초의 가압류명령 정본이 제3채무자에게 송달된 때에 소급하여 경정된 가압류명령의 효력이 발생하는 것이 원칙이다. 다만 경정결정이 그 허용한계 내의 적법한 것인 경우에 있어서도 제3채무자의 입장에서 볼 때에 객관적으로 경정결정이 당초 가압류명령의 동일성에 실질적으로 변경을 가하는 것이라고 인정되는 경우에는 경정결정이 제3채무자에게 송달된 때에 비로소 경정된 가압류명령의 효력이 발생한다(대판 2005. 1. 13. 2003다29937).

(3) 제3채무자가 가압류명령을 송달받은 후 채무자에게 채권을 변제하는 등 채권을 소

멀시키는 행위를 하였거나 채권의 가치를 감소 또는 조건 성취를 방해하는 행위를 하였다면 그로써 채권자에게 대항할 수 없다.

채무자의 제3채무자에 대한 강제집행에 의한 변제의 수령도 채권가압류가 해제되지 않는 한 허용되지 않는다. 따라서 채무자가 제3채무자에 대하여 집행채권을 갖고 있는데 그 집행채권에 대하여 채권가압류가 집행되면 이는 집행장애사유에 해당하게 되고, 집행채권자인 채무자는 집행채무자인 제3채무자의 제3자에 대한 채권에 대하여 추심명령이나 전부명령을 받는 방법으로 강제집행을 할 수 없게 된다(집행채권의 현금화나 만족적 단계에 이르지 아니하는 보전적 처분인 압류명령을 받는 것은 가능하다. 대결 2000. 10. 2. 2000마5221, 대판 2016. 9. 28. 2016다205915).

그러나 채권가압류는 채무자에 대하여 채권의 처분을 금지하는 명령을 발하지 않으므로(민집 296조 3항), 가압류된 채권도 이를 양도하는 데 아무런 제한이 없다. 다만 가압류된 채권을 양수한 양수인은 그러한 가압류로 권리가 제한된 상태의 채권을 양수한다(대판 2000. 4. 11. 99다23888).

(4) 채권가압류집행 후에 채무자와 제3채무자와의 사이에 변제 이외의 방법으로 가압류된 채권을 소멸하게 하는 행위를 한 경우의 효력이 문제되는데, 채권가압류는 제3채무자에 대하여 채무자에게의 지급 금지를 명하는 것이므로 변제 이외에도 채권을 소멸 또는 감소시키는 등의 행위는 할 수 없고 그와 같은 행위로 채권자에게 대항할 수 없다(하지만

310 가압류의 처분제한 효력은 가압류채권자의 이익보호를 위하여 인정되는 것이므로 가압류채권자가 그 처분행위의 효력을 긍정하는 것은 가능하다.(대판 2007. 1. 11. 2005다47175).

기존채무에 대하여 채권가압류가 마쳐진 후 채무자와 제3채무자 사이에 준소비대차 약정이 체결된 경우, 준소비대차 약정은 가압류된 채권을 소멸시키는 것이어서 채권가압류의 효력에 반하므로 채무자와 제3채무자는 준소비대차의 성립을 가압류채권자에게 주장할 수 없게 된다(대판 2007. 1. 11. 2005다47175).

채무자와 제3채무자가 가압류된 채권의 발생원인인 법률관계를 합의하여 해제·해지하면 가압류된 채권이 소멸하게 되므로, 이러한 합의해제·해지로 가압류채권자에게 대항할 수 있는지가 문제된다.

예를 들어, 현재와 장래의 임금채권에 대한 가압류가 이루어졌어도 그 발생원인인 근로계약(이른바 ‘계속적 계약관계’에 해당)의 합의해지가 가능하다는 것에는 이론이 없으나(다만 합의해지 이전에 이미 집행이 완료된 임금채권 가압류에 대하여는 영향이 없다),

매매대금채권이 가압류된 이후에 매매계약(이른바 ‘일시적 계약관계’에 해당)을 합의해제한 경우 그 합의해제에 의하여 가압류된 채권이 소멸하였음을 이유로 하여 가압류채권자에게 대항할 수 있는가에 관하여는 견해 대립이 있다.

판례는 채권가압류에 채권의 발생원인인 법률관계에 대한 채무자의 처분까지도 구속하는 효력은 없으므로 제3채무자는 채권가압류가 있는 후라도 채권의 발생원인인 법률관계를 합의해제하고 이로 인하여 가압류된 채권이 소멸되었다는 사유를 들어 가압류채권자에게 대항할 수 있고, 다만 채무자와 제3채무자가 아무런 합리적 이유 없이 가압류된 채권의 소멸만을 목적으로 계약관계를 합의해제한다는 등의 특별한 경우는 예외라고 한다(대판 1991. 11. 12. 91다29736, 대판 2001. 6. 1. 98다17930 등). 채권가압류 후 채권의 발생원인인 계약의 당사자 지위를 이전하는 계약인수가 이루어진 경우 양수인은 가압류에 의하여 권리가 제한된 상태의 채권을 이전받게 되므로, 제3채무자는 계약인수에 의하여 그와 채무자(양도인) 사이의 계약관계가 소멸하였음을 내세워 가압류채권자에게 대항할 수 없다(대판 2015. 5. 14. 2012다41359).

제3채무자는 채무자에 대하여 가지고 있던 법률상의 지위를 그대로 채권자에게 대하여 가지게 되므로 가압류의 효력발생 당시에 제3채무자의 자동채권과 채무자의 수동채권이 상계적상에 있거나 자동채권이 가압류 당시 변제기에 달하지 아니한 경우에는 피가압류채권인 수동채권의 변제기와 동시에 또는 그보다 먼저 변제기에 도달하는 경우라면 추심명령 또는 전부명령 송달 이후에도 상계할 수 있다(대판 1987. 7. 7. 86다카2762, 대판(전) 2012. 2. 16. 2011다45521]. 311

(5) 채권가압류에 있어서 제3채무자의 채무자에 대한 지급금지는 집행보전을 위하여 인정된 것이므로 그 목적의 범위를 넘어서 채무자의 법률적 활동을 제한할 필요는 없다. 그러므로 가압류집행이 이루어졌더라도 자신의 채권에 대하여 현실적인 만족을 얻지 않는 이상 가압류채무자는 제3채무자를 상대로 이행의 소를 제기하여 집행권원을 얻을 수 있고 그 밖에 소송 외에서 어떠한 방법을 취하더라도 무방하며 단지 강제집행을 할 수 없을 뿐이다(대판 1989. 11. 24. 88다카25038, 대판 2000. 4. 11. 99다23888). 특히 가압류된 채권이 시효로 소멸할 염려가 있는 때에는 채무자가 시효중단을 위하여 소를 제기할 필요가 있다(대판 2003. 5. 13. 2003다16238).

(6) 금전채권이 압류되어도 그 채권의 이행기가 도래한 때에는 제3채무자는 그 지체책임을 면할 수 없는데, 이러한 사정은 가압류의 경우에도 마찬가지이다(대판(전) 1994. 12. 13. 93다9511. 이에 따라 민사집행법은 제3채무자로 하여금 가압류를 이유로 하여 공탁할 수

있도록 하였는데(민집 291조, 248조 1항), 공탁으로 제3채무자는 채무를 면하고 가압류의 효력은 청구채권액에 해당하는 채무자의 공탁금 출급청구권에 존속하게 된다(민집 297조).

가압류를 이유로 한 공탁은 압류를 이유로 한 공탁과 달리 그 공탁금으로부터 배당 등을 받을 수 있는 채권자의 범위를 확정하는 배당가입차단효가 없고, 배당절차를 개시하는 사유도 되지 않는다.

후에 채무자의 공탁금 출급청구권에 대한 가압류를 본압류로 이전하는 압류명령이 국가(공탁관)에 송달되면, 민사집행법 291조, 248조 1항에 따른 공탁은 같은 법 248조에 따른
312 집행공탁으로 바뀌어 공탁관은 즉시 압류명령의 발령법원에 그 사유를 신고하여야 하고, 이로써 가압류의 효력이 미치는 부분에 대한 채무자의 공탁금 출급청구권은 소멸하고, 그 부분 공탁금은 배당재단이 되어 집행법원의 배당절차에 따른 지급위탁에 의해서 출급이 이루어지게 된다(대판 2019. 1. 31. 2015다26009).

(7) 가압류의 집행절차에서는 현금화절차를 행할 수 없으므로 채권자는 가압류 상태에서 전부명령이나 추심명령을 받을 수는 없다.

(8) 채권에 대한 가압류집행의 신청이 취하되거나 가압류집행의 절차를 취소하는 결정이 확정된 때에는 법원사무관등은 가압류명령을 송달받은 제3채무자에게 그 사실을 통지하여야 한다(민집규 218조, 160조 1항). 가압류집행의 신청이 취하된 때에는 법원사무관등은 가압류명령을 송달받은 채무자에게도 그 사실을 통지한다(민집규 16조).

3. 예금채권에 대한 가압류

가. 개요

예금채권은 지명채권의 일종이므로 앞서 본 지명채권에 관한 설명이 여기에도 적용될 것이나 예금채권의 특수성 때문에 몇 가지 특별한 문제가 있다.

나. 양도금지특약과 가압류의 효력

일반적으로 예금거래 기본약관에는 예금주가 예금채권을 양도하려면 사전에 은행에 통지하고 은행으로부터 동의를 받아야 한다는 내용이 포함되어 있다.

그러나 당사자 사이에 양도금지의 특약이 있는 채권이라도 압류 및 전부명령에 따라 이전될 수 있고, 양도금지의 특약이 있는 사실에 관하여 압류채권자가 선의인가 악의인가는 전부명령의 효력에 영향이 없다는 것이 판례이다(대판 1976. 10. 29. 76다1623, 대판

2002. 8. 27. 2001다71699). 사인의 일반재산 중에서 압류금지재산을 만드는 것은 불허되어야 하고 이를 허용하면 채권자의 지위가 침해되기 때문이다.

이자채권은 원본채권인 예금채권의 종된 권리이므로 예금채권이 압류·전부되면 이자채권도 압류·전부채권자에게 이전된다. 다만 압류 당시 이미 변제기에 이른 이자채권은 원본채권인 예금채권에 대하여 독립성을 가지므로 압류의 효력이 당연히 미치지 않는다 (대판 1989. 3. 28. 88다카12803 참조).

이상의 논의는 예금채권에 대한 가압류에도 적용된다.

다. 가압류할 예금채권의 특징

예금채권을 특정하기 위해서는 예금자의 이름, 거래지점, 예금의 종류 및 계좌번호, 예금액 등을 명확히 하여야 한다. 그러나 금융실명제가 시행된 이후 금융기관은 예금자의 비밀보호를 이유로 제3자에게 예금정보를 제공하지 않고 있고, 그 결과 채권자에게 가압류할 예금채권의 특징을 위하여 위와 같은 사항을 정확하게 파악하여 기재하라고 요구한다면 예금채권에 대한 가압류는 사실상 불가능하게 될 수 있다.

따라서 예금채권의 경우에는 일반 채권보다 가압류할 채권의 특징을 완화할 필요가 있는바, 어느 정도까지 특정하면 되는지가 문제 된다.

먼저 채무자의 장래 입금될 예금에 대한 반환채권은 장래 발생될 채권인데, 이러한 장래채권을 가압류하기 위해서는 그 발생의 기초가 되는 법률관계가 존재하고 그 내용의 확정 가능성이 그 발생이 확실하여야 한다. 장래 입금될 예금에 대한 반환채권도 위 요건에 부합되면 가압류할 수 있다. 판례는 채권가압류에서 가압류할 채권에 장래 채무자의 계좌에 입금될 예금채권도 포함되느냐 여부는 가압류명령에서 정한 가압류할 채권에 그 예금채권도 포함되었는지에 따라 결정되는 것이고 이는 곧 가압류명령의 ‘가압류할 채권의 표시’에 기재된 문언의 해석에 따라 결정되는 것이 원칙인데, 가압류명령의 가압류할 채권의 표시에 ‘채무자가 각 제3채무자들에게 대하여 가지는 다음의 예금채권 중 다음에서 기재한 순서에 따라 위 청구금액에 이를 때까지의 금액’이라는 문언의 기재로써 가압류명령의 송달 이후에 새로 입금되는 예금채권까지 포함하여 가압류되었다고 보는 것은 통상의 주의력을 가진 사회평균인을 기준으로 할 때 의문을 품을 여지가 충분하므로, 이 부분 예금채권까지 가압류의 대상이 되었다고 해석할 수는 없다고 보았다(대판 2011. 2. 10. 2008다9952).

가압류할 예금채권의 종류와 관련하여 실무는 다음과 같이 기재하고 있다.

여러 종류의 예금이 있는 때에는 다음 순서에 의하여 가압류한다.

가. 보통예금, 나. 저축예금, 다. 자유저축예금, 라. 정기예금, 마. 정기적금, 바. 별단예금, 사. MMF, 아. MMDA, 자. 신탁예금, 차. 채권형예금, 카. 부금, 타. 주택청약예금, 파. 주택청약부금, 하. 주택청약저축, 거. CMA, 너. 기업자유예금, 더. 당좌예금

만약 금융기관에서 새로운 유형의 예금상품을 개발하여 성질상 위 예금종류에 포섭될 수 없는 경우라면, 위 기재만으로는 이러한 예금에 대하여 가압류의 효력이 미친다고는 볼 수 없을 것이다. 따라서 새로운 종류의 예금에 대하여도 가압류의 효력이 미치게 하기 위해서는 원칙적으로 그 예금의 종류를 특정하여 추가로 표시하여야 할 것이나, 금융기관마다 개발한 예금의 종류가 다양하여 채권자가 이를 특정하기 어려운 때도 있다. 이 경우 가압류할 채권의 표시에 ‘기타 예금’을 추가하는 방법을 고려할 수 있겠으나 실무는 특정성을 흠결한 것으로 보고 있다.

판례는 가압류명령에서 그 대상 예금채권으로 자유저축예금, 보통예금 등은 명시되고 기업자유예금은 명시되어 있지 않아도, 기업자유예금이 자유저축예금, 보통예금과 기본적인 성격이 유사하고, 가압류명령이 제3채무자에게 송달될 당시 채무자의 예금이 기업자유예금뿐이었다면 가압류명령의 효력이 명시되지 않은 위 예금계좌에도 미친다고 하였다(대판 2007. 11. 15. 2007다56425).

다음으로 은행의 본점과 지점은 법률적으로 동일한 인격체이기 때문에 지점에 입금된 예금자의 예금채권에 대한 가압류명령이 본점으로 송달되더라도 그 송달은 유효하다. 과거 실무는 가압류대상 예금채권의 특정을 위하여 은행명과 함께 취급지점명을 기재하여 예금채권을 특정하도록 하였으나, 현재는 가압류할 예금채권의 순위만 정확히 기재한다면 집행에 장애가 없어 이를 요구하지 않고, 대신 예금자인 가압류채무자의 주민등록번호나 사업자등록번호를 기재하도록 하고 있다.

- 315 예금채권에 대한 가압류에서 또 하나의 쟁점은 1개의 신청으로 1인의 채무자(예금채권자)가 수인의 제3채무자(금융기관)에 대하여 갖는 예금채권의 가압류를 신청하는 경우에 이를 허용할 것인가이다. 실무는 이를 인정하고 있다. 다만 이러한 가압류는 사실상 수건의 가압류신청에 해당하므로 제3채무자별로 청구금액을 특정함에 있어서 청구금액을 구분 또는 안분하도록 하여 과잉가압류가 되지 않도록 해야 하고, 모든 금융기관을 망라하는 식으로 채무자와 무관한 금융기관들까지 무작정 제3채무자로 하여 가압류신청을 하는 것은 허용하지 않아야 할 것이다(보정명령을 하거나 보전의 필요성에 대한 소명부족을 이유로 가압류신청을 기각하는 것이 실무의 경향임은 앞서 보았다).

위와 같은 관점에서 가압류대상이 되는 예금채권의 기재례를 예시하면 다음과 같다.

[기재례] 예금채권의 표시

가압류할 채권의 표시
금 ○○원
다만 채무자(-) ¹⁾ 가 제3채무자에 대하여 가지는 다음 예금채권 중 다음에서 기재한 순서에 따라 위 청구금액에 이를 때까지의 금액(단, 민사집행법 제291조, 제246조 제1항 제8호 및 같은 법 시행령 제7조에 의하여 가압류가 금지되는 예금을 제외한다.)
다 음
1. 압류되지 않은 예금과 압류된 예금이 있는 때에는 다음 순서에 의하여 가압류한다. 가. 선행 압류·가압류가 되지 않은 예금 나. 선행 압류·가압류가 된 예금
2. 여러 종류의 예금이 있는 때에는 다음 순서에 의하여 가압류한다. 가. 보통예금, 나. 저축예금, 다. 자유저축예금, 라. 정기예금, 마. 정기적금, 바. 별단예금, 사. MMF, 아. MMDA, 자. 신탁예금, 차. 채권형예금, 카. 부금, 타. 주택청약예금, 파. 주택청약부금, 하. 주택청약저축, 거. CMA, 너. 기업자유예금, 더. 당좌예금
3. 같은 종류의 예금이 여러 계좌 있는 때에는 계좌번호가 빠른 예금부터 가압류한다.

주 1. 채무자의 주민등록번호 또는 사업자등록번호

4. 저당권부채권, 전세권부 채권에 대한 가압류

316

가. 개요

저당권부채권에 대한 가압류절차는 기본적으로 금전채권에 대한 가압류절차와 같지만, 저당권의 피담보채권이 가압류되면 종된 권리인 저당권에도 가압류의 효력이 미치므로 그 공시방법이 필요하다는 점이 다르다.

나. 가압류명령

저당권부채권의 가압류에 있어 제3채무자는 저당권의 채무자이므로 저당권의 채무자와 저당부동산의 소유자가 다른 경우(물상보증인, 제3취득자)에는 실무상 저당부동산의 소유자도 가압류명령에 표시한다.

다. 집행

가압류명령은 채무자, 제3채무자에게 송달하는 외에 저당부동산의 소유자에게도 송달한다. 저당부동산의 소유자에 대한 송달은 가압류의 효력발생요건은 아니지만, 가압류기입등기를 위한 전제조건이기 때문이다(민집 228조 2항).

저당권부채권이 가압류된 경우 채권자의 신청에 따라 법원사무관등은 저당부동산의 소유자에게 가압류명령을 송달한 후 채무자의 승낙 없이 채권가압류사실을 등기부에 기재하도록 촉탁하여야 한다(민집 228조). 이 신청은 가압류신청과 동시에 할 수 있으나(민집 228조 1항), 가압류신청이 있는 후에 별도로 하여도 무방하다. 다만 가압류등기는 가압류의 효력발생요건이 아니고 공시의 효력만이 있으므로, 제3채무자에게 송달이 되지 않으면 가압류등기를 마쳐도 가압류의 효력이 발생하지 않는다. 가압류등기의 촉탁은 제3채무자와 저당부동산의 소유자에 대한 송달을 마친 후에 하여야 한다.

317 그 촉탁서에는 등기권리자로 가압류채권자를, 등기의무자로 저당권자(가압류채무자)를 기재하고 등기원인은 법원의 가압류명령이 된다. 위 가압류의 기입등기는 부기등기에 의한다(부등 52조 4호).

라. 가압류등기의 말소

저당권부채권에 대하여 가압류등기가 된 경우, ‘가압류된 채권이 공탁에 따라 소멸되었음을 증명하는 문서’가 제출된 때에는 법원사무관등은 신청에 따라 그 등기의 말소를 촉탁하여야 한다(민집규 213조 2항, 167조 4항 전문). 가압류신청이 취하되거나 가압류명령의 취소가 확정된 때에도 같다(민집규 213조 2항, 167조 4항 후문).

여기서 ‘가압류된 채권이 공탁에 따라 소멸되었음을 증명하는 문서’란 무엇인가. 제3채무자가 민사집행법 291조, 248조 1항에 의하여 공탁한 때에는 배당 등의 절차는 남게 되지만 가압류된 채권은 소멸하고 가압류의 효력은 실효되며, 제3채무자는 같은 법 291조, 248조 4항에 의하여 공탁의 사유를 법원에 신고하여야 하는바, 위 문서는 이러한 공탁서와 공탁신고서를 의미한다고 할 것이다.

민사집행규칙 167조 4항은 ‘압류된 채권이 변제로 소멸하였음을 증명하는 문서’가 제출된 경우에도 압류등기의 말소를 촉탁할 수 있다고 하나, 여기서 말하는 ‘변제’란 압류채권자가 추심명령을 받은 후 추심권에 의하여 제3채무자로부터 압류된 채권의 전액 또는 집행채권과 집행비용의 전액을 변제받아 채권집행이 종료하고 압류가 실효되는 경우를 말하는 것이므로, 이 부분은 추심권이 없는 가압류에 준용될 수 없다.

마. 전세권부 채권의 가압류

전세권부 채권에 대한 가압류는 첫째, 전세권이 종료된 후 발생한 전세금반환채권에 대하여 한 경우와 둘째, 존속하는 전세권에 기하여 담보되는 전세금반환채권에 대하여 전세권의 종료를 조건부 또는 기한부로 한 경우에 이를 허용한다.

채권에 대한 가압류이므로 그 집행은 전세권가압류와 달리 제3채무자에게 가압류명령 정본을 송달함으로써 한다. 가압류기입촉탁, 부기등기 등 그 밖의 점은 앞서 본 저당권부 채권에 대한 가압류절차가 준용된다(민집 228조 유추해석). 318

5. 배서가 금지된 지시채권에 대한 가압류

가. 개요

어음이나 수표, 선하증권, 화물상환증, 창고증권 등의 지시증권에 수반하는 지시채권에 대한 가압류는 그 지시증권이 배서가 금지된 것인지 아닌지에 따라 그 가압류방법이 달라진다. 배서가 금지되지 아니한 것은 유체동산가압류의 집행방법에 따라 집행관이 증권을 점유해야 한다(민집 291조, 189조 2항 3호, 1항). 배서가 금지된 것은 채권가압류의 집행방법에 따르나 이 역시 집행관이 증권을 점유해야 한다(민집 291조, 233조).

실무상 가압류할 채권을 ‘어음금채권’ 또는 ‘수표금채권’으로만 기재하여 가압류를 신청하는 경우가 종종 있으므로 이러한 경우에는 어음이나 수표의 배서금지 여부를 살펴 그에 따라 적절한 집행방법을 택하여야 한다.

여기서는 배서가 금지된 지시채권에 대한 집행절차에 대하여 본다.

나. 가압류명령

배서가 금지된 지시채권도 권리의 행사는 증권에 의하여야 하므로 집행에는 증권의 점유취득이 필수적이어서(민집 291조, 233조) 가압류명령에는 가압류의 취지 및 증권의 점유명령을 기재한다.

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재 약속어음에 기한 채권(화물상환증에 기한 별지 기재 유체동산 인도청구권)을 가압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 채무의 지급을 하여서는 아니 된다.
3. 채권자의 위임을 받은 집행관은 채무자로부터 위 약속어음의 점유를 이전받아 위 어음의 권리보전에 필요한 조치를 취하여야 한다.
4. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

319 주문 제2항은 어음·수표 등의 상환증권성에 비추어 필요 없다는 견해가 있다. 주문 제3항의 집행관에게 어음의 권리보전조치(지급을 위한 제시, 지급거절증서 작성 등)를 취하라는 문구는 당연한 것이므로 따로 기재할 필요가 없다는 견해가 있으나 가압류에서의 집행관의 점유는 압류의 경우보다 훨씬 장기간이므로 이를 명백히 밝혀 실권되는 일이 없도록 함이 좋을 것이다.

지시채권은 성질상 불가분채권이므로 채권 일부만을 가압류할 수는 없다.

다. 집행

(1) 배서가 금지된 지시채권의 가압류는 지명채권에 대한 가압류와 달리 제3채무자에게 가압류명령 정보를 송달하는 외에 집행관이 증권을 점유하여야 가압류의 효력이 생긴다(대판 1976. 3. 23. 76다198).

제3채무자에 대한 송달은 지명채권에 대한 가압류와 마찬가지로 발령법원이 집행법원이 되어 직접 행하나, 증권의 점유이전은 채권자가 위 가압류명령에 따라 집행관에게 증권의 가압류집행을 위임하여 행한다.

주의할 점은 지명채권에 대한 가압류와 달리 채권자에 대한 가압류명령 정보의 송달이 신속하게 이루어져야만 한다는 것이다. 그래야만 효율적으로 증권을 점유할 수 있기 때문이다.

(2) 집행관은 유체동산의 가압류집행과 같은 방법으로 채무자로부터 증권의 점유를 이전받아 보관한다. 증권은 집행관이 직접 보관하여야 하고 채무자에게 사용을 허가할 수 없다. 제3자가 증권을 점유하면서 제출을 거부하는 때에는 채무자의 증권인도청구권에 대하여 가압류집행을 할 수밖에 없다(민집 291조, 259조).

(3) 가압류된 지시채권이 금전채권인 경우(배서가 금지된 어음, 수표의 경우)에 본집행은 추심명령 또는 전부명령에 의하여 현금화를 함으로써 이루어진다. 하지만 추심명령이나 전부명령이 없더라도 보관 중 지급기일이 도래한 경우에는 집행관은 지급제시를 하여 어음금 등을 받은 후 집행법원에 제출하여야 한다.

가압류된 지시채권이 물건의 인도를 목적으로 하는 채권(배서가 금지된 선하증권 등 인도증권인 경우)인 경우에는, 궁극적인 만족을 얻기 위해서는 유체동산 인도청구권에 대한 집행방법에 따를 수밖에 없으므로 집행관이 증권을 점유하여 채권가압류의 효력이 발생한 이후에는 유체동산 인도청구권에 대한 강제집행절차에 따라 절차가 진행되게 된다.

(4) 그 밖에 가압류집행절차, 가압류집행의 효력 등에 관하여는 [IV] 제5장 제2절 제1관 3. 바. 지시채권의 압류 참조.

6. 다른 절차와의 경합

가. 채권가압류 간의 경합

가압류에는 압류에 관한 규정이 준용되므로(민집 291조), 가압류명령에 따라 채권 일부가 압류된 뒤 그 나머지 부분을 초과하여 다시 가압류명령이 내려지면 이중가압류가 되어 각 가압류의 효력은 그 채권의 전부에 미치게 된다(민집 235조). 채권가압류 채권자들 상호 간에는 우열이 없다. 가압류집행이 경합된 경우 그중 하나가 본압류로 이전된 때에는 다른 가압류채권자는 배당요구를 한 채권자의 지위를 가진다.

나. 채권처분금지가처분과의 경합

채권가압류와 채권의 처분금지가처분의 경합이 허용됨에는 이견이 없으나, 어느 것이 우선하는가에 관하여는 집행의 선후에 따라 효력의 우열이 정해진다는 견해(1설), 가압류가 우선한다는 견해(2설), 집행의 선후에 관계없이 효력에 우열이 없다는 견해(3설) 등의 대립이 있다.

판례는 채권자가 채무자의 금전채권에 대하여 처분금지가처분결정을 받아 그 가처분결정이 제3채무자에게 송달되고 그 후 본안소송에서 승소하여 확정되었다면, 그 가처분결정의 송달 이후에 실시된 가압류 등의 보전처분 또는 그에 기한 강제집행은 그 가처분의 처분금지 효력에 반하는 범위 내에서는 가처분채권자에게 대항할 수 없다는 것이므로(대판 2014. 6. 26. 2012다116260) 1설과 같은 입장으로 볼 수 있다.

321

다. 체납처분압류와의 경합

현행법상 체납처분절차와 민사집행절차는 별개의 절차이고 두 절차 상호 간의 관계를 조정하는 법률의 규정이 없으므로, 한쪽의 절차가 다른 쪽의 절차에 간섭할 수 없는 반면, 쌍방 절차에서 각 채권자는 서로 다른 절차에 정한 방법으로 그 다른 절차에 참여하게 된다(대판 1989. 1. 31. 88다카42, 대판 2015. 7. 9. 2013다60982 등).

따라서 체납처분절차에 의한 압류와 민사집행절차에 의한 가압류가 경합하는 경우, 세무공무원은 체납처분절차에 의하여 압류한 채권을 추심할 수 있고, 그 청산절차(배분절차)가 종결되면 그 채권에 대한 민사집행절차에 의한 가압류의 효력은 상실된다(대판 1999. 5. 14. 99다3686, 대판 2002. 12. 24. 2000다26036 등).

채납처분절차에 의한 압류와 민사집행절차에 의한 압류가 경합한 경우에 제3채무자는 민사집행법 248조 1항에 따른 집행공탁을 함으로써 면책될 수 있다는 것이 판례인바(대판 2015. 7. 9. 2013다60982), 채납처분절차에 의한 압류와 가압류가 경합하는 경우에도 그 선후를 불문하고 제3채무자는 같은 법 291조, 248조 1항에 따른 공탁을 함으로써 가압류채권자뿐 아니라 채납처분권자에 대하여도 면책될 수 있다는 견해가 유력하다.

국세징수법의 개정에는 관하여는 부동산가압류 부분을 참조.

라. 채권양도와와의 경합

채권이 양도되고 가압류도 된 경우에는 확정일자 있는 채권양도 통지가 채무자에게 도달한 시점과 채권가압류명령 정본이 제3채무자(채권양도의 채무자에 해당)에게 도달한 시점의 선후에 의하여 상호 간의 우열을 정한다[대판(전) 1994. 4. 26. 93다24223].

- 322 확정일자 있는 채권양도 통지와 채권가압류명령 정본이 제3채무자에게 동시에 도달하였다면(같은 날 도달하였는데 선후관계에 대하여 증거가 없는 경우도 마찬가지이다) 제3채무자는 양도인 또는 양수인을 피공탁자로 하는 채권자 불확지 변제공탁과 채권가압류가 있음을 이유로 한 집행공탁을 합한 혼합공탁을 함으로써 양도인, 양수인 및 가압류채권자 등 모두에 대하여 면책될 수 있다. 혼합공탁 신청서의 피공탁자란에는 양도인 또는 양수인을(가압류채권자는 피공탁자로 기재하지 않는다), 공탁근거 법령조항란에는 민법 487조 후단 및 민사집행법 291조, 248조 1항을, 공탁원인사실란에는 채권가압류명령과 확정일자 있는 채권양도 통지의 내용 및 양자가 동시에 도달하여 지급할 수 없다는 취지를 구체적으로 기재한다.

채무자가 가압류된 채권을 양도 등 처분함으로써 그 가압류채권자에게는 대항할 수 없는 사정이 있더라도, 그 처분 후에 채무자의 채권을 압류하거나 가압류한 다른 채권자에 대하여는 유효한 처분이 된다. 따라서 동일한 채권에 관하여 가압류명령과 확정일자 있는 양도통지가 동시에 제3채무자에게 도달한 경우, 채권양수인은 그 후에 압류나 가압류를 한 다른 채권자에 대해서는 이미 채권이 전부 양도되었음을 주장하여 대항할 수 있으므로 그러한 후행 압류권자 등은 더 이상 그 채권에 관한 집행절차에 참가할 수 없다(대판 2013. 4. 26. 2009다89436).

제5절 인도청구권 및 권리이전청구권에 대한 가압류

1. 유체동산의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 가압류

가. 개요

채무자의 책임재산이 될 유체동산의 인도청구권이 채무자에게 있거나 제3자가 그에 관한 권리를 채무자에게 이전할 채무를 지고 있을 때, 그 현실의 인도 또는 이전을 기다리지 않고(현실로 인도 등을 받으면 채무자가 이를 은닉, 처분할 우려가 있으므로) 그 인도청구권을 가압류할 수 있다. 실무상 사용되는 경우는 주로 매입한 상품의 인도청구권을 대상으로 하는 경우이다.

323

인도청구권이 가압류의 대상이 되는 것은 그 물건이 당초부터 채무자의 소유이거나 인도를 받음으로써 채무자의 소유로 되는 경우에 국한하고 그 외 임차권 등을 근거로 한 인도청구권 등의 경우에는 채무자가 목적물을 인도받더라도 책임재산이 될 수 없으므로 가압류의 대상이 되지 않는다.

또한 목적물을 제조, 가공하여 인도할 청구권은 단순한 물건의 인도가 아니고 작위를 목적으로 하는 청구권이므로, 위 방법에 따를 것이 아니고 민사집행법 291조, 251조(그 밖의 재산권에 대한 집행)에 의하여 가압류하여야 한다.

유체동산 인도청구권의 목적물, 압류할 청구권의 표시 등에 관하여는 [IV] 제5장 제2절 제2관 2. 가. 총설, 나. 집행의 대상적격, 다. 압류 참조.

나. 주문례

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재 유체동산 인도청구권을 가압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에 대하여 위 유체동산을 인도하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

다. 집행

지명채권의 가압류와 같이 발령법원이 집행법원이 되어 제3채무자에게 가압류명령 정본을 송달함으로써 집행한다.

유체동산 인도청구권의 본압류와 같이 법원은 제3채무자로 하여금 그 유체동산을 집행

관에게 인도할 것을 명할 수 있고 이때에는 채권자의 위임을 받은 집행관이 그 인도를 받아 보관하게 된다는 견해도 있으나(민집 291조에 따른 민집 243조의 준용 여부에 관한 문제), 단순히 채권의 보전만을 목적으로 하는 가압류에서는 목적물의 현금화준비로서의
324 의미가 있는 위와 같은 명령을 할 수 없다고 보는 것이 다수설이다.

2. 부동산 등의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 가압류

가. 개요

(1) 채무자가 제3자에 대하여 부동산의 인도청구권을 가지고 있거나 소유권이전등기청구권 등 부동산에 관한 권리이전청구권을 가지고 있는 경우의 강제집행은, 채권자가 채무자의 제3자에 대한 부동산에 관한 위와 같은 청구권을 압류하여 그 청구권의 내용을 실현해 그 부동산을 채무자의 책임재산으로 귀속시킨 후, 부동산을 현금화(매각)하거나 강제관리하는 방법으로 그 매각대금이나 수익금으로부터 채권의 변제를 받는 2단계의 집행절차에 의한다(민집 242조, 244조).

부동산 등의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 가압류는 이러한 강제집행을 보전하기 위하여 이용된다.

(2) 채무자 소유의 부동산인 이상 이를 제3자가 점유하여도 이를 목적으로 하는 강제경매, 강제관리는 가능하므로 부동산인도청구권에 대한 가압류의 필요성은 적고, 대부분 부동산의 권리이전청구권(주로 소유권이전등기청구권)에 대한 집행을 보전하기 위하여 이용된다.

(3) 여기의 부동산은 민법상의 부동산뿐만 아니라 광업권, 어업권, 선박, 항공기, 자동차·건설기계 등을 모두 포함하는 개념이다.

나. 주문례

(1) 부동산인도청구권의 가압류는 제3채무자에 대하여 채무자에게 부동산의 인도를 금지하고, 소유권이전등기청구권의 가압류는 제3채무자에 대하여 채무자에게 이전등기절차의 이행을 금지한다.

325 채무자의 분양계약을 근거로 한 권리 일체 또는 조합원의 권리 일체에 대한 가압류도 허용되는데, 이때에는 제3채무자에 대하여 소유권이전 또는 채무자의 청구에 따른 분양계약자 또는 조합원의 명의변경금지를 명한다.

(2) 부동산인도청구권 가압류

1. 채무자의 제3채무자에 대한 (20 . . . 자 임대차계약의 기간만료로 인한) 별지 기재 부동산의 인도청구권을 가압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 부동산을 인도하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

(3) 부동산소유권이전등기청구권 가압류(가등기되지 않은 경우)

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재 부동산의 소유권이전등기청구권을 가압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 부동산에 관한 소유권이전등기절차를 이행하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

(4) 부동산소유권이전등기청구권 가압류(가등기된 경우)

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재 부동산에 관한 ○○지방법원 등기와 20 . . . 접수 제00호로 마친 소유권이전청구권가등기에 기한 매매예약완결을 원인으로 하는 소유권이전등기청구권을 가압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 부동산에 관한 소유권이전등기절차를 이행하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

다. 집행과 그 효력

(1) 집행은 제3채무자에게 가압류명령 정본을 송달함으로써 한다. 채무자의 분양계약을 근거로 한 권리 일체 또는 조합원의 권리 일체에 대한 가압류집행도 제3채무자에 대하여 가압류명령 정본을 송달함으로써 한다.

소유권이전등기청구권의 가압류는 채권에 대한 것이지 등기청구권의 목적물인 부동산에 대한 것이 아니다. 가등기되지 않은 소유권이전등기청구권에 대한 가압류를 등기부에 공시할 방법은 현행법상 존재하지 않으나, 가등기된 소유권이전등기청구권(부등 88조)은 부기등기의 방법으로 가압류등기를 할 수 있는데(등기예규 1344호) 제3채무자에게 가압류명령 정본을 송달하여 집행을 마친 후 촉탁등기를 하게 된다.

가압류의 성질상 보관인을 선임하여 권리이전을 받게 하거나 추심명령을 받아 권리이전을 하게 할 수는 없고 본압류로 이전된 후에나 가능하다고 할 것이다.

(2) 가등기되지 않은 소유권이전등기청구권의 가압류는 등기부에 공시되지 않으므로, 채무자와 제3채무자 이외의 제3자에 대해서는 처분금지 효력을 주장할 수 없고, 부동산

자체의 처분을 금하는 대물적 효력이 없다. 따라서 가압류채권자가 제3채무자나 채무자로부터 이전등기를 마친 제3자에 대하여 그가 취득한 등기가 원인무효임을 주장하여 말소를 청구할 수는 없다[대판(전) 1992. 11. 10. 92다4680 등].

반면 가등기된 소유권이전등기청구권의 경우, 가압류의 기입등기를 마친 후 가등기에 기한 본등기와 이에 이어 제3자 명의의 소유권이전등기가 이루어졌다면, 가압류채권자는 제3자에 대하여 위 가압류의 처분금지 효력을 주장할 수 있다. 따라서 제3자 명의의 소유권이전등기는 가압류채권자와의 관계에서 무효이고, 가압류채권자의 신청에 의한 당해 부동산에 대한 강제집행절차에서 부동산을 매수한 매수인 명의의 소유권이전등기는 적법·유효하다(대판 1998. 8. 21. 96다29564).

한편 소유권이전등기청구권의 가압류는 채무자 명의로 소유권을 이전하여 이에 대하여 강제집행을 할 것을 전제로 하고 있으므로, 소유권이전등기청구권을 가압류하였다 하더라도 어떠한 경로로 제3채무자로부터 채무자 명의로 소유권이전등기가 마쳐졌다면 채권자는 부동산 자체를 가압류하거나 압류하면 될 것이지 그 소유권이전등기를 말소할 필요는 없다[대판(전) 1992. 11. 10. 92다4680]. 다만 그에 기하여 채무자가 당해 부동산을 다른 곳에 처분함으로써 채권자가 손해를 입게 되면 제3채무자가 손해배상책임을 질 수 있다(대판 1998. 5. 29. 96다11648, 대판 2000. 2. 11. 98다35327 등).

327 (3) 채권에 대한 가압류가 있더라도 채무자는 제3채무자를 상대로 그 이행을 구하는 소를 제기할 수 있고, 법원은 가압류되어 있음을 이유로 이를 배척할 수 없는 것이 원칙이나, 소유권이전등기청구권이 가압류된 후 채무자가 제3채무자를 상대로 소유권이전등기청구의 소를 제기한 경우에는 법원은 가압류해제를 조건으로 하여서만 청구를 인용할 수 있다. 왜냐하면 소유권이전등기를 명하는 판결은 의사의 진술을 명하는 판결로서 이것이 확정되면 채무자는 일방적으로 이전등기를 신청할 수 있고 제3채무자는 이를 저지할 방법이 없기 때문이다(대판 1999. 2. 9. 98다42615).

만일 제3채무자가 가압류해제 전에 임의로 소유권이전등기의무를 이행하고자 하면 민사집행법 244조에 의하여 보관인을 정하고 그 보관인에게 채무자의 법정대리인 지위에서 채무자 명의의 소유권이전등기를 마치도록 하면 된다.

(4) 소유권이전등기청구권에 대한 가압류가 있기 전에 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 “채무자는 소유권이전등기청구권을 양도하거나 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니 된다. 제3채무자는 채무자에게 소유권이전등기절차를 이행하여서는 아니 된다”는 소유권이전등기청구권 처분금지가처분이 있었다고 하더라도 그 가처분은 뒤에 이루어진

가압류에 우선하는 효력이 없어 그 가압류는 가처분채권자와 사이의 관계에서도 유효하다는 것이 판례이다(대판 1999. 2. 9. 98다42615, 대판 2001. 10. 9. 2000다51216).

판례는 소유권이전등기청구권에 대한 처분금지가처분과 가압류의 효력을 일반적인 채권에 대한 처분금지가처분과 가압류의 효력과는 달리 취급하고 있는 것으로 보인다.

그 밖에 자세한 내용은 [IV] 제5장 제2절 제2관 3. 부동산 등의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 집행 참조.

제6절 그 밖의 재산권에 대한 가압류

328

세3면
제8장
제6절

1. 총설

가. 가압류의 대상

그 밖의 재산권이란 그 강제집행에 민사집행법 223조 내지 250조와 98조 내지 101조를 준용하는(민집 251조 1항) 유체동산, 금전채권, 유체물의 인도나 권리이전을 목적으로 하는 채권 이외에 부동산을 목적으로 하지 아니하는 재산권을 말하는데, 유체동산에 대한 공유지분권, 특허권·실용신안권·상표권·디자인권·저작권 등의 지식재산권, 합명회사·합자회사·유한회사의 사원권, 조합원의 지분권, 골프 회원권과 같은 설비이용권, 주권발행전의 주식이나 신주인수권, 예탁유가증권, 전세권 등이 이에 해당한다.

건설업면허(대결 1994. 12. 15. 94마1802), 자동차운수사업면허권(대결 1996. 9. 12. 96마1088) 등은 강제집행의 대상으로 삼기에 부적합하므로 가압류도 허용되지 않는다.

임차인의 임차권은 임대인의 동의가 있어야 가압류집행의 대상이 될 수 있고(민 629조), 사용자의 고용계약상 노무제공을 받을 권리도 노무자의 동의가 있어야 가압류집행의 대상이 될 수 있다(민 657조).

나. 가압류절차 일반

가압류명령의 신청 시 피보전권리와 보전의 필요성을 소명하여야 함은 다른 가압류와 마찬가지로이다. 임대인의 동의가 있어야 가압류를 할 수 있는 임차인의 임차권에 대한 가압류신청 시에는 그 동의를 존재를 증명하는 자료를 제출하여야 한다.

그 밖의 재산권에 대한 가압류는 금전채권의 압류에 관한 규정(민집 223조에서 227조)

을 준용하여 관할 집행법원이 가압류명령을 한다(민집 291조, 251조).

- 329 가압류명령은 채무자에게 송달하여야 하며, 제3채무자가 있을 때에는 그 제3채무자에게도 송달하여야 한다. 여기서 제3채무자는 가압류된 재산권에 관한 직접의 이해관계인을 의미한다. 물건 또는 권리의 이용권에 있어서는 그 귀속자, 설비의 이용권에 있어서는 그 경영자, 사원권에 있어서는 회사 그 밖의 사단, 조합의 지분권에 있어서는 나머지 조합원, 공유지분에 있어서는 다른 공유자 등이 제3채무자가 된다. 제3채무자가 없는 재산권으로서는 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권, 저작권, 상호권 등이 있다.

그 밖의 재산권에 대한 가압류에서도 제3채무자에 대한 진술최고를 신청할 수 있는가. 제3채무자에 대한 진술최고는 이미 발령한 가압류가 재산권의 종류에 따른 올바른 집행절차에 의하여 이루어졌는가, 과연 제3채무자가 채무자에게 가압류된 채무를 부담하고 있는가 등을 파악하여 가압류명령의 경정 또는 새로운 가압류신청을 하기 위한 준비절차로서 필요하므로 그 밖의 재산권에 대한 가압류의 경우에도 가능하다고 해석하여야 할 것이다.

가압류한 그 밖의 재산권은 본집행 시 추심명령이나 전부명령 또는 특별현금화 방법에 따라 현금화하는데, 추심명령이나 전부명령 등 통상의 방법으로는 현금화하기 어려운 경우가 많으므로 대부분 특별현금화의 방법으로 현금화한다.

2. 골프 회원권, 스포츠 회원권, 콘도 회원권에 대한 가압류

가. 개요

골프 회원권 등은 그 내용에 따라 예탁금 회원제, 주주 회원제, 사단법인 회원제 등의 형태가 있는데, 회원권의 종류에 따라 가압류의 방법이 다르다.

예탁금 회원제는 예탁금반환청구권이라는 채권과 결부되어 있고, 주주회원제 또는 사단법인회원제는 주주 또는 사단법인의 사원의 지위가 결합되어 있다는 점에서 차이가 있다. 주주회원제와 사단법인회원제는 채무자의 권리내용과 제3채무자의 법인형태(주식회사인지 아니면 사단법인인지)를 통하여 구분할 수 있다.

330 나. 가압류명령

(1) 예탁금 회원제

(가) 예탁금 회원제의 골프 회원권에는 시설이용권과 예탁금반환청구권이 포함되어 있

으므로, 회원권 자체를 가압류하는 방법과 회원이 탈퇴할 때 행사할 수 있는 정지조건부채권인 예탁금반환청구권을 가압류하는 방법(대판 1989. 11. 10. 88다카19606)이 있으나 통상 전자의 방법에 따른다.

채권자는 가압류명령을 근거로 하여 집행관을 통하여 예탁금증서를 채무자로부터 인도 받을 수 있다.

(나) 주문례

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재 골프 회원권을 가압류한다.
2. 채무자는 위 골프 회원권에 대하여 예탁금의 반환을 청구하거나 매매, 양도, 질권 설정 그 밖의 일체의 처분행위를 하여서는 아니 된다.
3. 제3채무자는 위 골프 회원권에 대하여 예탁금을 반환하거나 채무자의 청구에 의하여 명의변경 그 밖의 일체의 변경절차를 하여서는 아니 된다.
4. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

제3편
제8장
제6절

(2) 주주회원제

주주회원제의 경우에는 회원이 주주가 되므로 주식에 대한 가압류의 예에 의한다.

(3) 사단법인회원제

(가) 사단법인회원제인 경우에는 회원이 당해 사단법인에 대하여 일정한 지분을 가지고 있는 것으로 보아 사원의 지분에 대한 가압류방식에 의하여야 한다. 다만 정관에서 사단법인의 지분양도가 허용되고 있어야 한다.

(나) 주문례

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재 지분을 가압류한다.
2. 채무자는 위 지분을 추심하거나 그 밖의 방법으로 처분하여서는 아니 된다.
3. 제3채무자는 채무자에 대하여 이익금의 배당, 지분의 환금, 잔여재산의 분배를 하여서는 아니 된다.
4. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

331

다. 가처분과의 경합

예탁금 회원제 골프 회원권에 대하여는 그 회원권 자체 또는 회원이 탈퇴할 때 행사할 수 있는 예탁금반환청구권에 대하여 가처분을 할 수도 있다.

골프 회원권의 양수인이 양도인에 대하여 가지는 골프 회원권 명의변경청구권 등에 기하여 하는 골프 회원권 처분금지가처분결정이 제3채무자인 골프클럽 운영회사에 먼저 송

달되고, 그 후 가처분채권자가 골프클럽 운영에 관한 회칙에서 정한 대로 회원권 양도·양수에 대한 골프클럽 운영회사의 승인을 얻었을 뿐만 아니라 본안소송에서도 승소하여 그 승소판결이 확정되었다면, 그 가처분결정의 송달 이후에 실시된 가압류 등의 보전처분 또는 그에 기한 강제집행은 그 가처분의 처분금지 효력에 반하는 범위 내에서는 가처분채권자에게 대항할 수 없다(대결 2009. 12. 24. 2007마184).

3. 주식에 대한 가압류

가. 개요

주식은 주식회사의 주주가 사원으로서 갖는 지위이며(사원권), 주권은 주식을 표창하는 유가증권인데, 양자 모두 강제집행의 대상으로서 재산적 가치를 갖는다. 주식 또는 주권에 대한 가압류절차는 주식의 양도제도 등과 관련된다.

332

주권발행 여부		가압류대상	가압류절차
주권 발행 전	6개월 경과 전	주권교부청구권	유체동산 인도청구권에 대한 가압류
	6개월 경과 후	주식 자체	그 밖의 재산권에 대한 가압류
주권 발행	채무자 점유	주권	유체동산에 대한 가압류
	예탁	유가증권공유지분	그 밖의 재산권에 대한 가압류(민집규 214조, 2편 2장 7절 3관)
주권 불발행	전자등록	전자등록주식 자체	그 밖의 재산권에 대한 가압류(민집규 214조의2, 2편 2장 7절 3관의2)

주식은 주권이 발행되었는지, 채무자가 점유하고 있는지, 예탁되었는지, 전자등록되었는지 등에 따라 가압류대상과 가압류절차가 달라진다. 그럼에도 막연히 주주를 채무자로, 발행회사를 제3채무자로 하여 가압류신청을 하는 경우가 많고, 그로 인하여 채권자의 신청대로 가압류명령이 있더라도 가압류의 효력이 발생할 수 없는 때도 있으므로 채권자의 신청이 잘못된 것으로 의심되는 경우에는 보정명령을 하는 것이 바람직하다.

나. 주권 가압류

이는 유체동산가압류의 일종이나(민집 189조 2항 3호) 편의상 함께 살펴본다. 주권이 발행된 경우에 주식의 양도는 주권의 교부를 필요로 한다(상 336조 1항). 주권의 교부로 주식을 양도받은 양수인은 주권을 회사에 제시하여 단독으로 명의개서를 청구할 수 있으므로 이 경우에는 원칙적으로 유체동산인 주권 자체가 가압류집행의 대상이 된다. 주문례는 다음과 같다.

1. 채무자 소유의 별지 기재 주권을 가압류한다.
2. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

다. 권리주에 대한 가압류의 가부

333

주식회사의 설립 시 또는 신주발행 시 주주로 될 때까지의 주식인수인의 지위를 권리주라고 하는데, 이러한 권리주의 양도는 회사에 대하여 효력이 없다(상 319조, 425조 1항). 주금납입영수증 또는 청약증거금영수증에 백지위임장을 첨부하여 권리주를 양도하는 예가 있다고 하나, 그 양도는 양도당사자 사이에 채권적 효력이 있을 뿐 회사에 대하여는 효력이 없으므로, 권리주 자체를 가압류하는 것은 불가능하다.

그러나 주식인수인은 회사에 대하여 설립등기 후 또는 납입기일 후 회사가 발행하는 주권의 교부청구권(장래의 채권)을 가지므로 민사집행법 291조, 251조, 243조에 의하여 채무자를 주식인수인, 제3채무자를 회사로 하여 주식인수인의 주권교부청구권을 가압류한 후 주권의 교부를 받게 하여 주권을 현금화하는 방법으로 강제집행을 할 수 있을 것이다.

라. 주권교부청구권 가압류 및 주권발행 전 주식 가압류

(1) 주권발행 전의 주식의 경우에는 회사성립 후 또는 신주납입기일 후 6개월을 경과하기 전과 그 후에 따라 주식양도의 효력이 달라지므로 그 가압류 방법에도 차이가 있다. 따라서 신청서에 주권이 발행되지 않았다는 취지의 기재가 있으면 채권자로 하여금 위 6개월을 경과하였는지 여부를 소명케 하고 그에 합당한 방법에 따라 신청취지를 보정하도록 명한다.

(2) 6개월을 경과하기 전의 주식

회사성립 후 또는 신주납입기일 후 6개월이 경과하기 전에는 주권발행 전의 주식의 양도는 회사에 대하여 효력이 없으므로(상 335조 3항), 주식 자체를 가압류하는 것은 불가능하고, 채무자(주주)가 회사에 대하여 가지는 주권교부청구권을 집행의 대상으로 삼아야 한다. 주문례는 다음과 같다.

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재 주권교부청구권을 가압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 주권을 교부하거나 채무자의 지시에 따라 이를 채무자 이외의 자에게 교부하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

334

(3) 6개월 경과 후의 주식

회사성립 후 또는 신주납입기일 후 6개월이 경과하고도 회사가 주권을 발행하지 않을 경우에는 주권 없이 주식을 양도할 수 있고, 주식의 양수인은 회사에 대하여 양수인 명의로 명의개서를 한 후 주권의 발행을 청구할 수 있으므로 민사집행법 291조, 251조에 의하여 그 주식 자체를 가압류하면 된다. 주문례는 다음과 같다(“채무자는 위 주식에 관하여 양도, 질권 설정 그 밖의 일체의 처분행위를 하여서는 아니 된다”라는 문구를 추가하는 경우도 있다).

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재 주식을 가압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 주식에 대한 이익배당금의 지급, 잔여재산의 분배, 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니 된다.
3. 제3채무자는 위 주식에 대하여 채무자의 청구에 의하여 명의개서를 하거나 채무자에게 주권을 교부하여서는 아니 된다.
4. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

마. 예탁유가증권에 관한 공유지분 가압류

(1) 주식거래의 빈번함과 대량화에 따라 주식의 원활한 유통을 위하여 도입된 증권대체결제제도에서는 일반투자자인 고객이 그 소유의 유가증권을 투자매매업자나 투자중개업자 등의 예탁자에게 예탁하고, 예탁자는 이를 다시 모아서 한국예탁결제원에 재예탁하게 되는데, 이러한 예탁유가증권에 대한 강제집행은 증권 자체가 아닌 예탁유가증권에 관한 공유지분을 대상으로 하므로(민집규 176조. 재예탁된 유가증권들은 한국예탁결제원에 혼장임치된 상태로 존재하므로 그 공유지분이 가압류의 목적물이 된다), 예탁유가증권에 대한 가압류는 그 밖의 재산권에 대한 가압류에 해당한다.

- 335 (2) 예탁유가증권에 관한 공유지분을 가압류하는 때에는 예탁자(투자매매업자나 투자중개업자 등)또는 한국예탁결제원에 대하여 예탁유가증권지분에 관한 계좌대체와 증권의 반환을 금지하는 명령으로 한다(민집규 214조 1항). 채무자가 일반투자자인 고객이라면 제3채무자는 예탁자(투자매매업자나 투자중개업자 등)가 되고, 채무자가 예탁자(투자매매업자나 투자중개업자 등)라면 제3채무자는 한국예탁결제원이 된다(민집규 177조).

가압류명령에는 가압류목적물의 특정을 위하여 당해 계좌를 관리하는 예탁자의 명칭 및 소재지, 그 지점명 및 소재지, 유가증권발행회사의 명칭, 유가증권의 종류, 종목 등의 사항이 기재되어야 하므로 신청서에 그 특징이 되지 않았으면 보정을 명한다.

예탁유가증권에 관한 공유지분을 가압류한 경우에도 가압류채권자는 예탁자(투자매매업자나 투자중개업자 등) 또는 한국예탁결제원으로 하여금 가압류명령의 송달을 받은 날부터 1주 안에 서면으로 민사집행규칙 178조 소정의 사항을 진술하게 할 것을 법원에 신청할 수 있다(민집규 214조 2항).

(3) 주문례는 다음과 같다.

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재 예탁유가증권에 관한 공유지분을 가압류한다.
2. 채무자는 위 예탁유가증권에 관한 공유지분에 대하여 계좌대체의 청구나 증권반환의 청구 그 밖의 일체의 처분행위를 하여서는 아니 된다.
3. 제3채무자는 위 예탁유가증권에 관한 공유지분에 대하여 계좌대체를 하거나 채무자에게 이를 반환하여서는 아니 된다.
4. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

제3면
제8장
제6절

바. 전자등록주식 가압류

(1) 2016년 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 ‘전자증권법’)이 제정되어 2019. 9. 16.부터 시행되었다(전자증권법 부칙 1조, 같은 법 시행령 부칙 2조). 전자등록 주식 제도에서는 일반투자자인 고객이 그 소유의 주식을 계좌관리기관(증권회사 등)에게 고객계좌부를 개설하여 관리하도록 하고, 계좌관리기관은 이를 다시 전자등록기관(한국예탁결제원)에게 고객계좌부를 개설하여 관리하도록 한다. 또한 일반투자자가 아닌 계좌관리기관, 법률에 따라 설립된 기금, 그 밖에 전자증권법 23조 1항에 규정된 자가 전자등록 주식의 권리자가 되려는 경우에는 전자등록기관에 계좌관리기관등 자기계좌부를 개설하여 관리한다. 주식의 전자등록은 발행인이나 권리자의 신청 또는 관공서의 촉탁에 따라 함이 원칙이나, 전자증권법에 다른 규정이 있는 경우에는 전자등록기관 또는 계좌관리기관이 직권으로 등록을 할 수 있는바(전자증권법 24조 1항), 상장주식 중 예탁수량 전부는 전자증권법의 시행과 더불어 직권으로 전자등록이 되었다(같은 법 부칙 3조 1항).

336

전자등록주식에 대한 가압류, 강제집행은 예탁유가증권에 관한 공유지분의 가압류, 강제집행과 유사한 부분이 많으나, 전자등록주식 가압류에서는 가압류의 목적물이 공유지분이 아니라 전자등록계좌부에 등록된 주식 자체라는 점과 전자등록기관 또는 계좌관리기관은 가압류한 목적물의 채무자가 아니라 단지 전자등록주식에 대하여 전자등록·변경·말소 등 업무를 수행하는 역할만 담당하므로 이들의 법률적 지위 및 역할은 통상의 제3채무자와 다르다는 점에 유의하여야 한다.

(2) 가압류절차

전자등록주식을 가압류하는 때에는 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 대하여 전자등록주식에 대하여 계좌대체와 말소를 금지하는 명령을 하게 된다(민집규 214조의2 1항). 채무자가 일반투자자인 고객이라면 금지명령의 상대방은 계좌관리기관등(증권회사 등)이 되고, 채무자가 계좌관리기관(증권회사 등)이라면 금지명령의 상대방은 전자등록기관(한국예탁결제원)이 된다.

가압류명령에는 가압류목적물의 특정을 위하여 당해 계좌를 관리하는 계좌관리기관의 명칭·소재지 및 전자등록주식의 표시를 하면 된다. 실무상 채권자가 주식 종목을 특정하여 신청하는 경우와 주식 종목을 특정하지 않고 일반적으로 신청하는 경우가 있는데, 전자의 경우에는 종목명·주식종류(보통주, 우선주 등) 등을 기재하면 되고, 후자의 경우에는 채무자가 전자등록기관 또는 계좌관리기관에 계좌개설자로서 가지는 주식을 가압류한다는 취지로 표시하면 된다.

337 전자등록주식을 가압류한 경우에도 가압류채권자는 계좌관리기관 또는 전자등록기관으로 하여금 가압류명령의 송달을 받은 날부터 1주 안에 서면으로 민사집행규칙 182조의4 소정의 사항을 진술하게 할 것을 법원에 신청할 수 있다(민집규 214조의2 2항).

(3) 주문례

1. 채무자가 계좌관리기관(또는 전자등록기관)에 대하여 가지는 별지 기재 전자등록주식을 가압류한다.
2. 계좌관리기관(또는 전자등록기관)은 위 전자등록주식에 대하여 계좌대체와 말소를 하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

4. 출자증권에 기한 조합원 지분에 대한 가압류 등

가. 개요

건설산업기본법상의 건설공제조합, 전기공사공제조합법상의 전기공사공제조합의 조합원에게 발행된 출자증권은 위 각 조합에 대한 출자지분을 표창하는 유가증권인데(대판 2017. 4. 7. 2016다35451), 출자증권의 발행과 교부 여부에 따라 가압류방법이 달라진다.

먼저 출자증권이 발행되어 조합원인 채무자가 이를 직접 점유하고 있는 경우에는 채무자의 출자증권에 기한 조합원 지분을 가압류하여야 한다(출자지분에서 파생되는 채권, 예를 들면 출자한 금원의 반환청구권만을 가압류할 수는 없다). 그 집행은 민사집행법 233조

에 따른 지시채권 가압류의 방법에 의하되, 법원의 가압류명령에 따라 집행관이 출자증권을 점유하여야 하므로(건설산업기본법 59조 4항, 전기공사공제조합법 11조 4항), 집행관이 채무자로부터 출자증권을 수취하여 보관하지 못하면 가압류의 효력은 발생하지 않는다(대판 1987. 1. 20. 86다카1456 참조). 그런데 실무상 조합원인 채무자가 출자증권을 직접 점유하는 경우는 거의 없고 대부분 조합에 질권이 설정되어 조합이 점유하고 있으므로, 무용한 가압류신청을 막기 위하여 출자증권에 기한 조합원 지분에 대한 가압류신청 시 채권자에게 채무자의 출자증권 점유를 소명하도록 하는 실무례도 있다.

다음으로 출자증권이 발행되었으나 질권의 설정 등을 이유로 조합이 조합원인 채무자에게 이를 교부하지 않고 점유하고 있는 경우에는 채권자는 채무자가 조합에 대하여 가지는 출자증권의 인도청구권(교부청구권)을 가압류할 수 있다(민집 242조, 243조). 유체물 인도청구권(교부청구권)의 가압류는 원칙적으로 금전채권의 가압류에 준해서 집행법원의 가압류명령과 그 송달로써 하는 것이므로(민집 223조, 227조, 242조, 243조, 291조), 출자증권의 인도청구권(교부청구권)에 대한 가압류명령이 제3채무자에게 송달되면 가압류집행의 효력이 생긴다(대판 2017. 4. 7. 2016다35451). 하지만 출자증권의 인도청구권(교부청구권)에 대한 본집행은 결국 집행관이 조합으로부터 출자증권을 인도받아야 가능한데, 조합은 질권을 보유한 상태에서는 그 인도를 정당하게 거부할 수 있으므로 가압류의 실효성이 크지 않을 수 있다.

출자증권을 발행하지 아니한 경우에는 출자지분환급청구권을 가압류하여야 할 것이다.

나. 심리

앞서 본 이유들로 인하여 출자증권에 기한 조합원 지분 또는 출자증권의 인도청구권(교부청구권)에 대한 가압류는 실질적인 채권확보 조치로서의 가치가 없거나 크지 않을 수 있다. 하지만 일단 가압류가 집행되면 조합의 신규보증이 이루어지지 않는 등으로 채무자의 사업 활동에 큰 지장을 초래할 수 있어 채무자에게 심리적 압박을 가하려는 목적으로 가압류신청이 이루어질 가능성이 있다. 이에 피보전권리와 보전의 필요성을 신중히 심리함과 아울러 공탁금액의 절반 이상을 현금공탁시키는 실무례가 많다.

다. 가압류절차

- (1) 통상 조합을 제3채무자로 하여 가압류명령을 한다.
- (2) 주문례

출자증권에 기한 조합원 지분에 대한 가압류명령은 다음과 같다.

1. 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 별지 기재 출자증권에 기한 조합원 지분을 가압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 지분에 관하여 이익금의 배당, 출자금의 반환, 잔여재산의 분배를 하여서는 아니 된다.
3. 채권자의 위임을 받은 집행관은 채무자로부터 위 출자증권을 수취하여 보관하여야 한다.
4. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

출자증권의 인도청구권(교부청구권)에 대한 가압류명령은 다음과 같다(“제3채무자는 채무자에게 위 출자증권에 기한 조합원 지분에 관하여 이익금의 배당, 출자금의 반환, 잔여재산의 분배를 하여서는 아니 된다.”라는 내용을 추가하는 실무례도 있다).

1. 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 별지 기재 출자증권의 인도청구권(교부청구권)을 가압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 출자증권을 인도(교부)하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

5. 사원의 지분에 대한 가압류

합명회사, 합자회사, 유한회사 사원의 지분에 대한 집행의 보전은 그 사원을 채무자로, 회사를 제3채무자로 하여 그 지분을 가압류함으로써 한다. 합명회사나 합자회사의 사원의 지분에 대한 가압류의 효력은 사원의 장래 이익의 배당 및 지분환급청구권에도 미치고(상 223조, 269조), 잔여재산분배청구권에도 미친다.

주문례는 아래와 같다.

340

1. 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 별지 기재 지분을 가압류한다.
2. 채무자는 위 지분을 추심하거나 그 밖의 방법으로 처분하여서는 아니 된다.
3. 제3채무자는 채무자에게 위 지분에 대하여 이익금의 배당 및 지분의 환급을 하여서는 아니 된다.
4. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

6. 지식재산권에 대한 가압류

가. 개요

특허권, 디자인권, 실용신안권, 상표권 및 저작재산권 등 이른바 지식재산권은 독립한 재산권으로서 민사집행법 251조에서 정한 그 밖의 재산권에 대한 가압류의 대상이 된다.

다만 특허권 등이 공유인 때에는 다른 공유자의 동의가 없으면 가압류는 가능하나 현금화를 하지 못하고(대결 2012. 4. 16. 2011마2412 참조), 특허권 등에 대한 전용실시권이 나 통상실시권에 대하여는 그 특허권자 등의 동의가 있는 경우에만 가압류할 수 있다(특허 100조 3항, 102조 5항 등 참조). 저작권격권은 일신전속적인 권리로서 가압류의 대상이 되지 않는다.

특허권 등에 대한 가압류는 채권가압류와 달리 제3채무자가 없다. 그러나 공유지분에 대한 가압류에서는 다른 공유자가, 전용실시권 등에 대한 가압류에서는 특허권자 등이 직접적 이해관계인으로서 제3채무자가 된다.

나. 가압류절차

(1) 신청

특허권 등과 같이 권리이전에 등기 또는 등록이 필요한 경우에는 신청서에 권리에 관한 등록원부의 등본이나 초본을 붙여야 한다(민집규 213조 2항, 175조 1항). 가압류될 특허권 등의 존재, 내용 등을 확인하기 위해서이다.

(2) 관할

341

특허권 등과 같이 권리이전에 등기 또는 등록이 필요한 지식재산권에 대한 가압류는 일반 채권가압류의 경우와는 달리 본안의 관할법원 외에 그 등록을 하는 곳을 관할하는 지방법원이 관할법원이 된다(민집규 213조 1항).

(3) 주문례

1. 채무자가 가지는 별지 기재 특허권을 가압류한다.
2. 채무자는 위 특허권에 관하여 매매, 양도 그 밖의 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

(4) 기압등록과 송달

가압류명령은 채무자에게 송달하여야 하나 등록관청에는 송달할 필요가 없다.

특허권, 디자인권, 실용신안권, 상표권 등은 권리처분의 제한에 관하여 등록을 하지 아니하면 효력이 생기지 아니하므로(특허 101조 1항, 디자인보호법 98조 1항, 실용신안법 28조, 상표법 96조) 가압류명령이 있으면 법원사무관등은 직권으로 등록관청에 가압류기

입등록 촉탁을 한다(민집규 213조 2항, 민집 94조). 가압류의 효력은 채무자에 대한 송달과는 관계없이 언제나 가압류등록이 된 때에 생긴다(민집규 213조 2항, 175조 3항 단서). 특허권 등에 가압류, 가처분 등 처분제한의 등록을 촉탁할 때에는 채권자로부터 등록료납부영수증 대신 매진 84,000원 상당의 통상환을 제출받아 촉탁서와 함께 우송하여야 한다(특허료 등의 징수규칙 2조 2항 4호, 3조 2항 4호 등).

저작권은 저작한 때부터 발생하고 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 않는다(저작권법 10조 2항). 다만 저작재산권의 처분제한은 등록할 수 있으며, 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(저작권법 54조). 등록되지 아니한 저작재산권의 경우에는 법원의 촉탁으로 저작권등록을 한 후 가압류기입등록을 하여야 할 것이다(저작권법 53조, 저작권법 시행령 25조, 민집규 213조 2항, 민집 94조). 저작재산권에 대한 가압류등록은 이처럼 처분제한의 효력발생요건이 아니므로 채무자에 대한 송달과 가압류기입등록 중 먼저 된 시점에 가압류의 효력이 생긴다(민집규 213조 2항, 175조 3항 본문).

7. 전세권에 대한 가압류

전세권처럼 부동산과 관련이 있으나 부동산 자체를 집행대상으로 할 수 없는 것은 그 밖의 재산권에 대한 집행방법에 따라 가압류하여야 한다. 즉 채권자는 전세권 자체를 가압류한 후 매각명령이나 양도명령 등 특별현금화명령에 따라 집행한다.

전세권 가압류를 한 경우에는 법원사무관등이 그 사유를 등기부에 기재하도록 등기관에게 촉탁하여야 한다(민집규 213조 2항, 민집 94조 1항). 전세권 가압류의 효력은 전세권이 전세기간의 만료 등으로 소멸한 후 발생한 전세금반환채권에도 미친다.

전세권의 존속기간이 만료되거나 합의해지된 경우에는 일반 금전채권인 전세금반환채권을 가압류하는 방법으로 집행함에 주의하여야 한다(대판 1999. 2. 5. 97다33997 참조).